제 1 장

서 론

Ⅰ. 연구의 목적

제2차 세계대전 이후 국제간 무역규범으로 기능해 왔던 “관세와 무역에 관한 일반협정”(General Agreement on Tariff and Trade: GATT) 체제에서는 공산품(Goods)에 한정하여 규율을 해 왔다. 하지만 세계 경제의 규모가 커지고 서비스 분야의 거래가 활발해지면서 1986년 9월 우루과이에서 열린 제8차 다자간 무역협상, 즉 이른바 “우루과이라운드”(Uruguay Round: UR)에서는 용역(Service)분야의 교역까지 다루게 되었던 것이다.[1] 이후 1995년에 세계무역기구(World Trade Organization: WTO)가 창립되었고, 2001년 11월에 카타르 도하에서 개최된 제4차 WTO 각료회의에서 제9차 다자간 무역협상인 “도하개발아젠다”(Doha Development Agenda: DDA)가 출범하였으며 여기에서는 서비스분야가 농업분야와 함께 이미 설정된 의제(Built-In-Agenda: BIA)의 하나로 DDA 협상 일정에 흡수되고 협상이 진행되어 왔던 것이다.

하지만 세계무역장벽을 한꺼번에 낮추기 위한 목적을 갖고 지난 2001년 카타르 도하에서 본격 출범한 WTO DDA 협상이 최근 최대의 난관에 봉착하게 되었다. 이는 DDA의 성격이 UR 이후 달라진 국제 통상환경을 반영하면서 더욱 시장지향적으로 바뀌고 특히 농산물의 경우 어느 정도 숨 쉴 구멍이 있었던 UR와는 달리 실질적인 무역자유화를 추구, 세계무역기구(WTO) 회원국 간에 농산물 시장 개방 폭과 보조금 감축을 둘러싼 이견차가 좁혀지지 않았기 때문이다.[2]

2004년을 기준으로 우리나라의 서비스 분야 교역규모는 896억 달러로 그 규모에 있어서는 어느 정도 만족할 만한 수준에 이르고 있다.[3] 하지만 교역수지의 측면에 있어서는 96억 달러

---

1) 우루과이 라운드 협상 출범 시 서비스 무역 자유화 문제를 협의키로 합의하였으며, 협상 타결 시 서비스 분야의 국제교역을 다루는 최초의 구속적 다자간 규범인 “서비스무역에 관한 일반협정(GATS : General Agreement on Trade in Services)”을 체결하였다.

2) 문제는 DDA 협상이 사실상 장기 동면 상태에 빠질 수밖에 없다는 것이다. WTO 회원국들이 올해 들어 수차례 목표 타결시한을 늦춰온 이유도 오는 11월 미국의 중간선거 등 주요국의 정치일정 때문에 실질적으로 협상이 장기간 공백 상태에 빠질 것이라는 관측 때문이었다. 특히 내년 7월에는 미국 부시 행정부가 확보하고 있는 신속협상권한(TPA)이 종료된다. 현 상황에서는 TPA의 연장이 어려울 것이라는 것이 일반적인 예상이고 이에 따라 앞으로 DDA 협상 재개에 수년이 소요될 것이라는 관측도 제기되고 있는바, 결국 DDA 협상은 5년 가까이 표류해온 끝에 추가 시도마저 언제 가능할 지 점치기 어려운 최대 위기에 직면하고 있다, 연합뉴스 2006년 7월 25일을 참조.

의 적자를 나타내어 독일(-591억 달러), 일본(-391억 달러), 아일랜드(-116억 달러) 다음으로 네 번째의 적자를 기록하고 있어 그 경쟁력이 매우 취약함을 알 수 있다.[4] 국제적으로 도

3) 외교통상부, 2005 WTO개황, 2005. 12, 39-40면 참조.

<표-> 서비스 분야 교역규모

(단위: 십억 US$)

순위	국명	교역규모	순위	국명	교역규모
1	미국	578.3	9	중국	133.7
2	독일	326.9	10	아일랜드	105.2
3	영국	307.9	11	캐나다	102.8
4	일본	228.9	12	벨기에	97.6
5	프랑스	205.9	13	오스트리아	95.4
6	이탈리아	162.6	14	한국	89.6
7	네덜란드	145.4	15	홍콩	83.4
8	스페인	138.2		세계	4,220.0

주 : 상업서비스(국제수지상 서비스중 정부서비스를 제외) 기준 / 자료 : WTO

4) 외교통상부, 2005 WTO개황, 2005. 12, 65면 참조.

<표-> 주요 서비스 수출입국가 (2004년)

(단위: 10억불, %)

순위	수 출 국			수 입 국		
	국 가	금 액	비 중	국 가	금 액	비 중
1	미 국	319.3	15.2	미 국	259.0	12.4
2	영 국	169.2	8.1	독 일	190.8	9.2
3	독 일	126.1	6.0	영 국	134.7	6.5
4	프 랑 스	108.4	5.2	일 본	133.6	6.4
5	일 본	93.8	4.5	프 랑 스	94.5	4.5
6	이 탈 리 아	84.6	4.0	이 탈 리 아	79.6	3.8
7	스 페 인	84.2	4.0	네 덜 란 드	72.4	3.5
8	네 덜 란 드	72.4	3.4	중 국	69.7	3.3
9	중 국	58.9	2.8	아 일 랜 드	58.2	2.8
10	홍 콩	54.0	2.6	캐 나 다	55.9	2.7
11	벨 기 에	49.5	2.4	스 페 인	53.3	2.6
12	오스트리아	47.2	2.2	한 국	49.6	2.4
13	캐 나 다	46.9	2.2	벨 기 에	48.4	2.3
14	아 일 랜 드	46.2	2.2	오스트리아	48.0	2.3
15	한 국	39.7	1.9	인 도	37.9	1.8
16	스 웨 덴	37.8	1.8	싱 가 폴	36.2	1.7
17	덴 마 크	37.5	1.8	덴 마 크	34.3	1.6
18	스 위 스	37.1	1.8	러 시 아	33.5	1.6
19	싱 가 폴	36.6	1.7	스 웨 덴	33.2	1.6
20	룩셈부르크	33.4	1.6	대 만	29.9	1.4
소계	상위20개국	1,585.0	75.4	상위20개국	1,555.0	74.6
합계	전 체	2,100.0	100.0	전 체	2,080.0	100.0

자료 : WTO, World Trade Report 2005, Appendix Table 4

하개발아젠다를 위시한 서비스 분야의 개방추세에 비추어 볼 때, 현재 우리나라의 서비스 분야 경쟁력으로는 향후 개방이 본격적으로 이루어 질 경우 국내 서비스 관련업계에 적지 않은 타격을 입힐 것으로 예상되므로 이에 대한 대비가 필요하다고 하겠다. 한편 정부는 대외무역이 GNP의 약 70%를 차지하는 국가이므로 DDA 협상에 적극적으로 참가하여 다른 나라들의 무역장벽을 억제하고 서비스 분야에서의 실질적인 시장개방 확대를 추구해 자유무역체제가 강화되는 것이 거시적으로는 유리하다는 판단 하에, 법률・회계・세무・교육・보건의료・통신・금융 등 10개 서비스분야 개방 종합대책을 마련 2005년 말까지 확정짓는다고 밝힌 바 있었다.[5)]

국제적으로 법률서비스 시장의 개방논의가 대두되게 된 것은 국제간 거래의 비약적 증가와 이에 기인한 기업들의 법률수요 증가에 기인한 측면이 매우 크다고 할 것이다. 우리나라의 경우 법률서비스 시장은 그동안 개방이 유보되어 왔으며 정부의 법률부문 개방 대책은 주로 변호사의 업무영역에 그 초점이 맞추어져 왔다.[6)] 넓은 의미의 법률서비스(Legal services)는 '법무전문직에 의한 법률 자문 및 소송대리 서비스'는 물론 '판사나 법원공무원 또는 검사 등에 의한 법의 집행'과 관련된 일체의 활동까지가 포함되는 것이다.[7)] 특히 GATS '서비스업종분류표'상의 법률서비스는 좁은 의미의 변호사에 의한 법률서비스를 비롯하여 변리사, 법무사, 행정서사 등에 의한 법률서비스 등을 포괄하는 것으로 보아야 하므로 향후 개방대상에 포함된다고 할 것이다.[8)] 한편 지식재산권 분야는 일반 법률의 경우보다 훨씬 국제화되고 표준화되어 있으므로 시장개방이 가져올 파장이 매우 크다고 할 것이다.[9)] 지난 1990년대 독일과 프랑스의 법률서비스 시장이 법률시장 개방 후 합병과 해산 등 심각한 후유증을 겪은 사례 등에 비추어 볼 때 우리나라도 지식재산권 분야에서의 법률시장 개방 시 예견되는 혼란을 미리 예방하는데 힘써야 할 것이다.

즉, 지식재산권 분야에서 대리인으로 활동하고 있는 변리사와 변호사간에 직무영역에 관한 다툼이 계속되고 있고, 이에 따라 동 분야의 분쟁해결기관인 특허심판원・특허법원 및 일반법

---

5) 2006년 2월 말 현재 분야별 구체적인 개방계획은 아직 확정되지 않고 있다. 국민일보, "10대 서비스개방 계획 표류…연말 확정 못 지키고 2월 시한도 넘겨", 2006. 2. 27 참조.

6) 종래의 각종 연구는 물론 정부간행물에서도 '법률서비스'라는 표현과 '법무서비스'라는 표현이 혼재하고 있는데 본 연구에서는 동일한 의미로 사용하기로 하되, '법률서비스'로 통일하여 사용하기로 한다.

7) 그런데 법의 '집행' 영역은 GATS 제1조 제3항 (c)호에서 "정부 권한의 행사에 의해 공급되는 서비스(a service supplied in the exercise of governmental authority)"로 간주되어 동 협정의 적용대상에서 명시적으로 제외시키고 있고[GATS 제1조 제3항 (b)호], 따라서 GATS의 서비스 무역자유화 협상의 대상이 될 수 없는 것이다. 법무부, 법무서비스 개방문제 연구, 2000. 12, 3-4면.

8) 법무부, 법무서비스 개방문제 연구, 2000. 12, 7면.

9) 2002년 11월 13일 대외경제정책연구원(KIEP)가 주최한 "WTO 도하 개발 아젠다 협상 법률서비스 분야 논의 동향과 대응방향" 연찬회 논의에서는 법률서비스에 포함되어 있는 변리사업의 경우 일반 법률서비스와 환경이 다르고 국내 업계가 취약한 상태이므로 되도록 개방을 늦추어야 한다는 지적이 있었으며, 특히 일반 법률보다 훨씬 국제화되고 표준화되어 있으므로 개방이 될 경우 외국출원을 국내에 들여오는 것에 관련된 업무도 상당 부분 잠식될 우려가 제기된 바 있다.

원에서의 대리행위 역시 문제가 되며, 또한 특허심판원과 특허법원 사이에 견해차이가 있는 심리범위에서 많은 문제소지를 갖고 있다. 그러므로 법률시장 개방에 따라 지식재산권 분야에서 문제가 될 수 있는 분쟁해결기관으로서 특허심판원과 특허법원을 먼저 다루고, 특허침해소송의 관할의 문제·심결취소소송의 심리범위·소송대리인에 관한 문제 등을 검토하고자 한다.

이를 통하여 지식재산권 분쟁해결제도의 문제점을 조기에 발견하고 개선하여 동 분야의 법률시장구조가 국제적 기준에 합당한 기반을 마련하며, 그 결과 법률소비자의 권익을 도모함은 물론 궁극적으로는 법률시장 개방에 발맞추어 지식재산권 분야의 국제적 경쟁력을 강화시키는 데 일조하고자 한다.

Ⅱ. 연구의 범위 및 방법

1. 연구의 범위

위에서 살펴본 바와 같이 국제적으로 법률시장 개방논의가 이루어지고 있으며, 이러한 추세에 따라 우리 정부도 개방에 적극적인 입장이다. 그러므로 지적재산권 분야 역시 이러한 상황에 발맞추어 그동안 제기되어 왔던 여러 가지 이슈에 대하여 문제점을 분석하고, 해외의 다양한 제도와 사례를 통해 시사점을 도출해 내어 개방에 적극 대처하여야 할 것이다.

이에 본 연구에서는 다음과 같은 이슈들을 연구의 범위로 설정하여, 각 분야별로 지적재산권의 특성을 고려함은 물론 향후 법률시장 개방되는 경우 무엇이 법률서비스 소비자의 이익에 충실한 것이며, 또한 법률서비스 공급자의 경쟁력 강화에 기여할 것인지를 합리적으로 형량하고 그에 따른 개선방안을 도출하도록 한다.

1) 법률시장 개방협상 및 각국의 개방현황 검토

지적재산권 분야의 제 문제를 분석하고 향후 개방에 대응방안을 마련하기 위해 우선 검토되어야 할 부문으로써 그간의 법률시장 개방에 관련된 다자간의 논의에 대해 살펴보는 것과 아울러 이미 법률시장을 개방한 주요 국가들의 현황을 파악하는 작업이 선행되어야 할 것이다.

그런데 최근 WTO 사무총장은 제네바에서 각료회담이 결렬된 뒤, "조건이 성숙하고 새로운 전기가 마련되기 전까지는 협상을 중단할 수밖에 없다"고 선언한 바, 우리 정부는 일단 한미 자유무역협정(FTA) 확대에 힘을 기울일 것으로 보인다. 하지만 DDA 협상이 완전히 무산된 것이 아닐 뿐만 아니라 FTA 역시 양자 간의 서비스 분야개방을 주된 목적으로 삼고 있으므로, 본 논문은 DDA가 중단되었다 할지라도 FTA가 지속되는 한 법률개방의 문제는 계속 논의되어 질 것으로 예상되어지는바, 다음과 같은 내용을 다루고자 한다.

첫째로, 법률시장 개방에 관련된 다자간의 논의에 관하여서는 "관세 및 무역에 관한 일반협정"(GATT)에서 그 논의를 출발해, Service 분야의 교역까지 다루게 된 제8차 다자간 무역협상, 즉 "우루과이라운드"(UR)와 "서비스무역에 관한 일반협정"(GATS)을 검토하며, 세계무역기구(WTO)출범 이후 첫 번째 다자간 무역협상인 "도하개발아젠다"(DDA)의 법률서비스 분야 협상의제와 논의 현황을 검토한다.[10]

둘째로, 이미 법률시장을 개방한 주요 국가의 현황과 제도, 그리고 외국변호사 및 로펌의 국

10) DDA협상과 아울러 현 정부는 FTA 역시 함께 추진하고 있는 바, 이러한 개방에 대해 찬반(贊反)의견이 개진되고 있다. 그러나 본 연구에서는 어떠한 형태로든 법률시장이 개방된다는 가정 하에 지적재산권 관련 문제를 검토하여 대응방안을 수립하고자 한다.

내진출 허용·국내 로펌과의 동업·합작 및 국내 변호사 고용 허용 등 각국의 주요 요구사항을 검토하여, 향후 우리나라 법률시장 개방에 고려될 수 있는 시사점을 도출하기로 한다.

2) 특허쟁송제도의 개선방안

첫째, 특허심판원 업무관련 문제를 검토하고자 한다. 1998년 3월 1일 개원한 특허심판원은 산업재산권의 발생·변경·소멸 및 그 효력범위에 관한 분쟁을 해결하기 위한 행정심판을 그 업무범위로 하고 있는 바, 개원한지 10년이 다가오는 시점에서 지재권 분야의 개방을 대비하기 위하여 특허심판원의 등장배경을 시작으로 해서, 주요국의 심판제도와 운용현황 및 심판의 신속성·타당성 및 전문성에 대하여 살펴보고자 한다.

둘째, 특허법원의 기능 및 위상 재정립과 관련하여, 특히 관할의 집중 내지는 확대 필요성이 꾸준히 제기되고 있다. 하지만 여러 가지 이해관계와 그에 따른 견해의 대립 때문에 별다른 진척이 되고 있지 못한 상황이다. 기업의 성쇠는 물론 국가경쟁력과도 직결되어 있는 지적재산권 분쟁해결기관인 특허법원이, 주요 선진국에서는 어떠한 조직과 방법으로 운용되고 있는가를 검토해 보고자 한다.

3) 특허소송의 심리범위 문제

심결취소소송의 심리범위에 관하여 특허심판원과 특허법원·대법원간에 견해를 달리하고 있다. 그러므로 지금까지 논의되고 제기되고 있는 다양한 견해들을 살펴보고 판례를 검토하여 종합적으로 정리하고자 한다. 또한 주요 선진국들의 심리범위에 대한 운용현황을 살펴보고, 현재의 우리나라가 취하고 있는 심리범위에 대한 입장이 적절한 것인지를 판단하고자 한다.

4) 지재권 분야의 대리인 관련 문제

첫째, 주요국의 지식재산권 분야의 특허소송에서 대리인 제도에 대한 검토하게 된다. 특허소송에서 전문성 있는 변리사의 소송대리를 금지함으로써 법률서비스의 수요자인 당사자의 권익을 침해하는 것뿐만 아니라, 소송의 지연이나 전문성이 떨어져 특허소송에 대한 국민적 신뢰도에 문제가 생긴다는 것을 설명하고자 한다. 그리고 난 후 변리사 및 변호사간 직무영역과 관련한 문제를 검토하고자 한다. 변리사와 변호사는 소위 유사직역으로써 자동자격부여와 소송대리권 인정여부 등에서 대립해 왔다. 그러므로 현행 변리사법 제2조[11], 제3조[12], 제8조의 규

11) 제2조 (업무) 변리사는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관하여 특허청 또는 법원에 대하여 하여야 할 사항의 대리 및 그 사항에 관한 감정 기타의 사무를 행함을 업으로 한다.

정[13]과 변호사법 제3조[14], 제4조[15] 규정의 해석을 둘러싼 제 견해들을 검토하여 시장개방에 대비한 직무영역의 개선방안을 도출해 내고자 한다.

둘째, 앞서 언급한 변호사와의 직무영역 조정문제와 관련됨은 물론 향후의 법률시장 개방 및 향후 도입예정인 로스쿨제도에 대비하여 변리사 선발 및 양성제도에 관하여 심층적인 검토가 요구되는 바, 변리사 시험제도의 재정비 문제가 대두된다고 하겠다.[16] 이를 위해서 지식재산권 분야에 있어 주요국의 대리인 선발·양성제도를 검토하여 이를 통해 적절한 개선방안을 마련하도록 한다.

2. 연구방법

본 연구는 다음과 같은 방법으로 수행하고자 한다.

첫째, 법률시장 개방협상과 주요국의 개방현황에 관련하여 외교통상부·법무부 등 정부부처나 유관기관의 발간자료와 On-line 자료, 그리고 관련 연구문헌들을 취합·검토한다.

둘째, 국내 지적재산권 분야의 분쟁해결시스템의 현황을 검토함에 있어서, 특히 준사법적 행정기관인 특허심판원과 아울러 외국의 지재권 관련 심판 및 소송대리인(변리사 및 변호사), 그리고 사법기관(특허법원)의 운용현황을 살펴보기 위하여 문헌자료를 살펴보고, 필요한 경우 해당 국가를 직접 방문하도록 한다.

셋째, 이에 근거하여 국내 지적재산권 심판 및 소송체계의 문제점을 제시하고, 이러한 문제들을 해결하기 위하여 외부 전문가의 청취와 자문을 통하여 개선방안을 도출하고자 한다.

---

12) 제3조 (자격) ① 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 변리사의 자격이 있다.
1. 변리사시험에 합격한 자
2. 변호사법에 의하여 변호사의 자격을 가진 자로서 변리사등록을 한 자

13) 제8조 (소송대리인이 될 자격) 변리사는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항에 관하여 소송대리인이 될 수 있다.

14) 제3조 (변호사의 직무) 변호사는 당사자 기타 관계인의 위임 또는 국가·지방자치단체 기타 공공기관(이하 "공공기관"이라 한다)의 위촉 등에 의하여 소송에 관한 행위 및 행정처분의 청구에 관한 대리행위와 일반 법률사무를 행함을 그 직무로 한다.

15) 제4조 (변호사의 자격) 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 변호사의 자격이 있다.
1. 사법시험에 합격하여 사법연수원의 소정과정을 마친 자
2. 판사 또는 검사의 자격이 있는 자

16) 최근 로스쿨 대학과 관련하여, 2006년 6월 임시국회에서 로스쿨 관련 법안이 통과되지 못함에 따라 당초 계획했던 2008년 개원이 물리적으로 어려워졌다고 한다. 서울신문, 로스쿨 2008년 문 못 연다, 2006. 7. 1, 5면.

제 2 장

법률시장 개방협상 및 각국의 개방현황

Ⅰ. 법률시장 개방협상

1. 법률시장개방 관련 협상 경과

제2차 세계대전 이후 세계경제가 회복되면서 1947년 제네바에서 미국의 주도하에 23개국이 관세장벽과 수출입 제한의 제거, 국제무역과 물자교류의 증진을 목적으로 "관세 및 무역에 관한 일반협정"(GATT: General Agreement on Tariff and Trade)을 맺어 국제간의 무역규범으로 그 기능을 해왔다.[17]

그런데 1970년대의 이른바 1, 2차 석유파동으로 인해 세계경제의 성장세가 둔화되고 실업이 증가되는 등 경제 불황이 장기화됨에 따라 각국 간에 무역마찰이 심화되어, '신보호무역주의의 확산'으로 일컬어지는 국제무역환경의 악화현상을 겪게 되었다. 주요 선진국들은 자국 산업 및 국제수지 보호를 위하여 보호무역주의에 입각한 각종 수단을 남용하기 시작하였으며, GATT체제를 우회하는 반덤핑제도[18]의 남용, 수출자율규제(Voluntary Export Restraint: VER)[19] 및 시장질서협정(Orderly Marketing Arrangement : OMA)[20] 등의 회색지대조치가 성행하게 되었다.

---

17) GATT는 1948년 1월에 정식 발효되어 1995년 WTO가 출범될 때까지 유지되어 왔고, 법적 기구(legal entity)로서의 성격은 없었으나 불완전한 제도적 형태로 인하여 발생되는 문제들을 현실적인 협정을 통하여 해결함으로써 '사실상'(de facto)의 국제기구로서의 역할도 수행하였다.

18) 반덤핑제도는 덤핑물품의 수입으로 인해 국내 산업이 피해를 보거나 볼 우려가 있을 때, 관련수입품에 대해 관세부과 등을 적절히 규제하는 제도이다.

19) 수출국이 스스로 특정상품의 수출이 과도하게 이루어지지 않도록 조절하는 것을 말한다. 수출국의 일방적인 수입제한조치가 예견될 때 이를 회피하기 위하여 자주적으로 수출의 수량가격·품질·디자인 등을 규제하는 것이다. 수입제한을 실시하기 위해서는 GATT(관세 및 무역에 관한 일반협정)를 통한 교섭이 필요하기 때문에 수입국은 수출국에 대하여 자주규제를 요구해오는 경우가 많다. 세계 각국은 서로 무역역조를 내세워 상대국에 수출자주규제를 요구하는 경향이 있는데, 특히 선진 공업국에서 개도국이나 신흥공업국에 대해 수입제한의 새로운 형태로서 이를 요구하는 사례가 늘어나고 있어 새로운 비관세 무역장벽으로 등장하고 있는 것이다.

20) 수입량을 조정하여 시장질서를 유지하기 위한 협정으로 수출상대국과 체결하는 수입수량의 규제에 관한 것을 말한다. 기업 간에 자유롭게 체결하는 수출자율규제협정(VER)과 상대되는 개념으로, 관세나 수량규제처럼 분명한 형태의 수입규제수단이 아니라는 의미에서 회색지대조치라고 부르기도 한다.

이러한 상황 속에서 GATT 규정의 모호성, 분쟁해결기능 미흡 등의 문제가 부각되었으며, 아울러 그동안 다루어오지 않은 서비스·투자·지적재산권 등 새로운 분야의 무역량이 증대되어 이에 관련한 통상마찰이 빈발하여 이를 규율할 필요성이 대두되었다.

결국 1986년 9월 15일부터 20일까지 우루과이의 휴양도시인 푼타 델 에스테(Punta del Este)의 각료회의에서의 각료선언 채택으로 제8차 다자간 무역협상인, 이른바 "우루과이라운드"(UR: Uruguay Round)가 공식출범하게 된 것이다. 여기에서는 관세인하, 비관세 장벽완화, GATT 기능강화, New Issues에 대한 규범마련 등 90년대 및 2000년대에 적용될 세계무역규범의 정립을 목표로 꾸준하고도 끈질긴 협상을 진행하였으며, 1994년 4월 12일부터 15일까지 모로코의 마라케쉬(Marrakesh)에서 열린 UR최종 협정문 서명을 위한 각료회의의 결과로써 1995년 1월 1일부터, GATT를 대체하는 새로운 다자간 국제무역기구로써 WTO가 출범하게 된 것이다[21].

GATT 체제에서의 8차례의 협상 개요와, GATT와 WTO 체제의 다른 점은 다음과 같다.[22]

<표-> GATT하의 다자간 무역협상 개요

연도(참가국 수) 장소(명칭)	협상 분야	주 요 내 용
1947(23국) 제네바(Geneva)	관세	○ 최초의 다자간 협상, 당시 세계무역의 절반가량에 해당하는 45,000건의 관세양허 교환
1949(13국) 안시(Annecy)	관세	○ 주로 신규 가입 신청국의 GATT 가입(accession)을 용이하게 처리하기 위한 다자간 협상의 성격을 띰. ○ Annecy 라운드에서는 9개국이, Torquay 라운드에서는 4개국이 추가로 GATT에 가입
1951(38국) 토르퀘이(Torquay)	관세	
1956(26국) 제네바	관세	○ GATT 운영방식개선 및 GATT조문 재검토 목표 ○ "체약국단은 때때로 관세인하협상을 주최한다."는 계획을 처음으로 조문에 명시, GATT 제2부의 일부분 수정
1960~1961(26국) 제네바 (딜론라운드)	관세	○ 유럽경제공동체(EC) 출범을 배경으로 이로 인한 무역차별 및 무역전환효과를 상쇄하기 위해 개최 - 미국과 EC 평균 10% 관세인하
1964~1967(62국) 제네바 (케네디라운드)	관세 반덤핑	○ 품목별 협상과 선형삭감방식(formula approach) 병행하여 진행, 선진국의 관세율을 평균적으로 35% 인하 - 반덤핑 및 관세평가에 대한 합의도출

21) WTO 체제의 출범과정에 대한 설명으로는, 최경수, 국제지적재산권법, 한울 아카데미, (2001), 222면 이하.

22) 외교통상부, 2005 WTO개황, 2005. 12, 8-9면.

1973~1979(102국) 제네바 (동경라운드)	관세 비관세 기본협정	○ 선진국들은 대부분 30% 이상으로 관세율 인하 ○ 정부조달, 기술 장벽, 보조금 및 상계관세, 관세평가, 수입 허가, 반덤핑 등 6개 분야에 대한 협정(code) 제정 – 개도국 특별대우 제도화
1986~1994(123국) 제네바 (우루과이라운드)	관세 비관세 규범 서비스 지재권 분쟁해결 섬유 농업 TO창설	○ 세계무역기구(WTO) 설립 – 항구적이고 강력한 국제무역기구의 설립 – 회원국의 국내법을 WTO 규정에 합치시키도록 규정 ○ 공산품 관세인하 및 비관세장벽 완화 – UR 협상이전에 비해 1/3이상 관세 인하 – VER 등 회색조치의 철폐 ○ 농산물 및 섬유류 무역의 GATT 편입 ○ 기존 GATT 규범의 강화 – 반덤핑, 보조금, 상계관세, 세이프가드 등 ○ 서비스무역에 과한 기본규범 설정 및 최초의 양허교섭 완료 ○ 지적재산권 보호 및 투자관련 조치에 관한 규범 마련 ○ 통합분쟁해결절차 및 규칙(DSU) 합의

<표-> GATT 체제와 WTO 체제의 비교

	GATT 체제	WTO 체제
성격	○ 임시적이며 잠정적	○ 영구적
시장개방 노력	○ 관세인하에 주력 ○ 비관세장벽은 동경라운드에서 철폐 노력 – 그러나 선언적인 규정정립 수준으로 실효성미흡	○ 관세 인하는 물론 특정분야에 대한 무관세 도입과 고관세율의 하향평준화를 촉진 ○ 비관세 장벽의 철폐를 강화
관할범위	○ 상품 (주로 공산품)	○ 공산품 외에 농산물, 섬유류에 대해서도 포괄
새로운 분야 협정	○ 없음	○ 서비스교역에 대한 협정 제정 ○ 지적재산권 보호를 위한 규범 제정 ○ 무역관련 투자조치에 대한 규범 도입
규범 강화	○ 보조금 정의 등이 명료하지 않음 ○ 반덤핑 조치의 남용 등 자의적 운용	○ 보조금 정의의 명료화 및 규율 강화 (금지, 상계 가능, 허용보조금 등의 구분 설정 등) ○ 반덤핑 조치의 발동기준 및 부과절차 명료화의 남용 방지 ○ 세이프가드협정, 원산지 규정, 선적전 검사협정 등의 내용을 구체화 ○ 분쟁해결 절차 강화

이러한 과정을 통해 출범하게 된 WTO 체제는 법인격을 보유하며,[23] 포괄성과 규범성이 있고,[24] 다자주의에 근거하며,[25] 자유무역과 공정무역의 조화를[26] 특징으로 하고 있다. 아울러 다음과 같은 5가지 원칙을 토대로 한다.[27]

첫째, '차별 없는 교역'을 위해 최혜국 대우(MFN: Most Favored Nation Treatment)[28]와 내국민 대우(National Treatment)[29]를 원칙으로 한다.

둘째, 관세 인하 및 비관세 조치의 완화를 통한 '교역의 자유화'를 추진한다.

셋째, '예측가능성'을 위하여 관세 및 시장개방일정 등에 대한 양허를 각 회원국들이 제시하도록 하며, 무역정책검토제도 및 각종 통보의무 부여 등을 통해 각국 관행 및 절차의 투명성을 증대시킨다.

넷째, 최혜국대우, 내국민 대우의 보장, 덤핑·보조금 등에 대한 규범의 도입을 통해 '공정한 경쟁'을 유도한다.

다섯째, '경제개발 및 개혁의 장려'를 위하여 개도국들에 대한 특별우대조치를 허용하며, 특정 의무 이행기간의 연장 및 완화, 그리고 협정 이행을 위한 기술지원 등 능력배양사업을 지원한다.

WTO 전체 회원국의 대표로 구성된 각료회의는 최고의사결정기구인 바, 2001년 11월 9일부터 13일까지 카타르 도하에서 개최된 제4차 WTO 각료회의에서 제9차 다자간 무역협상인 "도하개발아젠다"(DDA : Doha Development Agenda)가 출범하였다.[30] 이는 WTO 출범 후 첫 번째 다자간 무역협상이고 또한 개도국의 요청으로 '개발'에 중점을 두자는 의미에서 'Develop

---

23) 법인격을 보유함으로써, WTO 기능수행에 필요한 법적 능력과 특권 및 면제를 향유한다.

24) 상품무역, 서비스, 자본, 기술거래 등 국제경제활동의 주요부분을 거의 다 포괄할 뿐만 아니라, 상세하고 실효성 있는 규범체계를 마련함으로써 과거 국제경제를 지배하던 '힘'의 논리를 '규범'의 논리로 대체하였다.

25) 일방주의 또는 지역주의의 확산을 방지하고, 회원국의 국내법을 다자규범에 일치시키도록 규정함으로써 일방적 무역조치의 남용방지를 위한 제도적 장치를 마련하였다.

26) 자유무역정책을 기본으로 하되, 개도국 지원을 위한 예외를 허용하고, 시장력을 남용하는 불공정관행들을 제거하는 공정무역정책을 가미하고 있다.

27) 외교통상부, 2005 WTO개황, 2005. 12, 5-6면 참조.

28) 최혜국대우는 중세 유럽에서 각 지역 간의 교역이 활발해지면서 나타난 개념이며, 본격적으로 등장한 것은 18세기 이후 체결된 우호통상항해조약이다. 최혜국대우는 더 낮은 조건을 어느 국가나 그 국가 국민에게 제공한 경우 그 조건은 그대로 다른 국가나 그 국가 국민에 대해서도 인정한 것이라 할 수 있다.

29) 내국민대우에 관하여는 파리협약 제2조 1항이 매우 구체적으로 제시하고 있다. 즉, "동맹국 국민은 다른 모든 동맹국에서 산업재산권의 보호에 관하여, 이 협약에서 특별히 규정하는 권리를 해치지 아니하는 한, 각 동맹국의 법률이 내국민에 대하여 현재 부여하거나 장래에 부여할 이익을 향유한다. 따라서 동맹국의 국민은 내국민에게 부과하는 조건 및 방식에 따를 것을 조건으로 내국민과 동일한 보호를 받으며, 또한 권리의 침해에 대하여 내국민과 동일한 법률상의 구제를 받는다"고 규정하고 있다.

30) WTO 도하개발아젠다 협상 경과에 대한 설명으로는, WTO 도하開發아젠다(DDA) 협상 -現況과 展望-, 국가정보원 (2004. 2), 3면-6면을 참고하기 바람.

ment'가 명칭에 포함되게 되었다.

DDA의 주요 협상의제는 시장개방 관련 의제,[31] 규범 관련 의제,[32] 환경, 지적재산권, 그리고 개도국 개발문제이다. 이 가운데 서비스 분야의 개방문제는 농업 분야와 함께 WTO 협정 발효일인 1995년 1월 1일로부터 5년 후인 2000년부터 논의하기로 되어 있는 기설정 의제(BIA: Built-In-Agenda)이며,[33] 이에 따라 DDA 협상 일정에 흡수되어 현재까지 협상이 진행되어지고 있었던 것이다.

이후 제5차 각료회의는 2003년 9월 10일부터 14일까지 멕시코의 칸쿤에서 열렸는데 당초 DDA 협상의 중간 점검으로 농업, 비농산물에 대한 협상 세부원칙(modalities)에 관한 기본골격 수립이 주요 목적이었으나 실패하였고, 농업·비농산물·싱가폴 이슈 등 주요 협상 분야에서 선진국·개도국 간 입장대립이 합의도출의 걸림돌로 작용하였고, 직접적으로는 싱가폴 이슈[34]에 대한 선진국·개도국 간 의견 대립으로 전체 의제가 합의 없이 종료되었다.

가장 최근에 개최되었던 제6차 각료회의는 2005년 12월 13일부터 18일까지 홍콩에서 개최되었다. 제5차 각료회의에서 실패한 협상 세부원칙(modalities)의 수립을 목표로 하였으나 목표수준을 조절하여 2006년 말 협상종료를 위해 주요 협상분야의 점검과 정치적 지침을 제공하고자 하였으며 특히, 본 연구와 관련되는 서비스 협상의 방식을 기존의 양자(兩者) 양허협상에 추가하여 복수(複數) 양허협상방식을 도입하고,[35] 제2차 수정 양허안 제출은 2006년 7월 말, 그리고 최종 양허안 제출은 2006년 10월 말로 각각 합의한 바 있다.

하지만, 최근 WTO 사무총장의 협상중단선언으로 다시 DDA 협상이 재개될 수 있을 것인지는 불투명한 상황이며, 이로 인해 향후에는 지역주의에 기반한 FTA를 통한 개방논의가 가속화될 것으로 예측된다. 다만, FTA의 기본적인 서비스분야 개방방식은 DDA와 유사하나, DDA가 다자간 협상이라는 점과는 달리 기본적으로 양자간 협상이므로 일률적으로 설명하기 어려우므로 아래에서는 DDA의 개방협상 내용을 중심으로 설명을 하도록 한다.

---

31) 시장개방 관련 의제에는 농업부문, 서비스부문, 비농산물(공산품, 임수산물)부분이 포함된다.

32) 규범 관련 의제에는 반덤핑, 보조금·수산보조금, 지역협정, 분쟁해결, 그리고 무역원활화 부문이 포함된다.

33) UR협상 타결시 서비스 분야의 국제교역을 다루는 최초의 구속적 다자간 규범인 "서비스무역에 관한 일반협정(GATS: General Agreement on Trade in Services)"을 체결하고 1995년 1월 1일 발효되어 WTO협정의 일부가 되었고, GATS 제19조 제1항에서 5년 이내에 협상을 개시하며 그 이후로도 주기적으로 협상하도록 규정하였다.

34) 무역과 투자, 무역과 경쟁정책, 무역원활화 및 정부조달 투명성을 지칭하는 것으로, 1996년 싱가폴 각료회의에서 이들 주제들이 무역과 어떠한 관계를 지니는지에 대해 분석 작업을 진행키로 결정한 데 따라 붙여진 이름이다. 2001년 도하개발아젠다에서 그 동안의 분석 작업의 결과로 동 이슈가 정식 협상대상에 포함되었다.

35) 이는 그 동안 서비스협상의 진척이 부진하였던 원인으로 지적되어 온 개별국가 대 개별국가의 양자적 R/O(Request/Offer)방식을 보완하기 위해 도입된 것으로, 복수의 국가가 특정국 특정서비스 분야 개방을 집단적으로(collectively) 요청하는 협상방식으로 요청국(requesting countries)과 요청대상국(requested countries) 간의 집단 대 집단회의 형식으로 개최되는 방식을 의미한다.

2. 법률시장 개방부문 협상의 내용

우리나라는 우루과이라운드 당시 법률서비스에 대해서는 어떠한 시장개방 약속도 제출하지 아니하였다. 그런데 지난 1996년 “경제협력개발기구”(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD)에 가입하는 과정에서 우리나라의 법률서비스 분야가 OECD의 양대 자유화 규약과 저촉된다는 지적을 받았다.[36] 이에 따라 외국인에 대해 대한민국 변호사 자격을 취득할 기회 자체를 원천적으로 봉쇄하였던 기존 정책을 바꾸어 1996년 12월 12일 "변호사법" 개정을 통해 우리나라 변호사의 자격취득에 있어 국적제한 등을 철폐하였다.[37]

아울러 "외국인 투자 및 외자도입에 관한 법률"에 기하여 변호사업 등 법무서비스 분야를 외국인투자 제한 업종으로 규정하여 이 분야에 대한 외국인투자를 원천적으로 봉쇄하였던 '외국인투자에 관한 규정'(재경원 고시)도 개정하였다.[38] 그리하여 1997년 1월 1일부로 법률서비스 분야를 외국인투자 제한업종에서 제외함으로써 국내 변호사 자격을 취득한 외국인이 법률사무소 개설 등 국내 법률서비스 분야에 투자하는 것을 허용하였다. 그렇지만 국내변호사 자격이 없는 외국변호사나 외국로펌 등에 의한 국내진출에는 적용되지 않는다는 점에서 실질적인 시장개방의 효과는 거의 없다고 하겠다.

또한 2000년 1월 28일 "변호사법"의 개정을 통해 법무부장관은 외국변호사로서 대한민국에 공로가 있거나 기타 변호사의 자격을 부여할만한 상당한 이유가 있는 자에 대하여 변호사의 자격을 인가할 수 있고, 외국인 또는 외국법에 관한 사항에 한하여 법률사무를 행할 수 있도록 허용하였으나, 이로 인한 시장개방 효과 역시 극히 제한적이라고 판단된다.[39]

상기와 같은 자발적 조치 이외에도 국제적인 다자간의 논의로써 “서비스무역에 관한 일반협정”(General Agreement on Trade in Services: GATS)에 근거하여 DDA 서비스협상이 소위 일괄타결방식(Single Undertaking)으로 최근까지 진행되어 왔다.[40] 동 협정의 ‘서비스업종분류표’에 따르면 사업, 통신, 건설, 유통, 교육, 환경, 금융, 보건・사회, 관광, 문화・오락・스포츠, 운송 등 총 12개 분야로 서비스를 분류하고 있으며, 이 가운데 법률서비스(Legal Service)는 사업서비스(Business Services) 아래 전문직서비스(Professional Services)의 하나로 분류된

---

36) 양대 자유화 규약이란 “경상무역외거래 자유화규약"(Code of Liberalization of Current Invisible Operations)과 ”자본이동 자유화규약"(Code of Liberalization of Capital Movement)을 가리킨다.

37) 1999년 2월 5일 시행 변리사법(법률 제5815호)까지는 제3조의 자격요건에서 만20세 이상의 “국민으로서 “라는 규정을 두어 국적요건을 유지하고 있었으나, 1999년 5월 9일 시행 개정법(법률 제5826호)부터는 이를 폐지한 바 있다.

38) 동법은 1998년 9월 16일 폐지되어 외국인투자촉진법으로 대체되었다.

39) 고준성, 법무서비스시장 개방의 효과 및 영향 분석, 통상법률(통권 66호), (2005. 12), 165-170면.

40) 일괄타결방식이란 다자통상협상에서 협상 국가들이 WTO 협정문에 서명하는 경우 WTO 협정문 및 부속문서를 전체적으로 수락하여야 한다는 원칙으로, 일부수락은 불가능하며 어느 조항에 대해서도 유보를 행할 수 없다는 의미이다.

다. 아울러 동 분류표상의 법무서비스는 좁은 의미의 변호사에 의한 법률서비스는 물론 변리사, 법무사, 행정서사 등에 의한 법률서비스 등을 포괄하는 것으로 보아야 하므로 이러한 분야 역시 향후 개방대상에 포함된다고 할 것이다.[41]

동 협정 제1조 제2항에서는 서비스의 공급형태를 기준으로 소위 4가지 Mode를 다음과 같이 정의하고 있다.[42]

▢ Mode 1(국경 간 공급, cross-border supply)

공급자와 소비자가 모두 자국 안에 위치하면서 우편이나 통신 등의 매개수단을 통하여 서비스를 공급하는 것을 의미한다. 예를 들어 우리나라의 기업이 우편이나 전화 또는 e-mail과 같은 전자통신수단 등을 통해 외국에 있는 외국 법률가로부터 서비스를 제공받는 경우가 이러한 범주에 속한다.

▢ Mode 2(해외소비, consumption abroad)

서비스공급자가 자국 안에 위치하고 소비자가 공급자의 국가로 이동하여 서비스를 공급받는 것을 의미한다. 예를 들어 외국에 있는 우리나라 기업의 해외지사 등이 현지의 외국 로펌으로부터 서비스를 공급받는 경우가 이에 해당한다.

▢ Mode 3(상업적 주재, commercial presence)

서비스공급자가 소비자의 국가에 자회사나 지사를 설립하는 등 상업적으로 주재하여 서비스를 공급하는 것을 가리키는데, 예를 들면 외국로펌이 우리나라에 지사나 법률사무소를 설립하여 우리나라 기업 등에게 법률서비스를 제공하는 형태가 그러하다.

▢ Mode 4(자연인의 이동, presence of natural persons)

한 회원국의 서비스공급자인 자연인이 다른 회원국 영토내로 이동하여 서비스를 제공하는 것을 의미한다.[43] 외국인 법률가 또는 외국의 로펌에 소속된 법률가가 우리나라로 이동하여 법률서비스를 제공하는 것이 그 예이다.

DDA 협상이 개시된 이래 미국, EC, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 스위스, 일본, 중국, 싱가폴, 파키스탄, 대만 등의 국가로부터 우리나라의 법률시장 개방에 대한 '개방요구'(Request)를 받았

41) 법무부, 법무서비스 개방문제 연구, (2000. 12), 7면.

42) Mode 1, 2, 4는 "국경 간 무역"(cross-border trade)이라 하며, Mode 3은 "해외 자회사 거래"(foreign affiliate transaction)이라고도 한다. USITC, Recent Trends in U.S. Services Trade: 2004 Annual Report(Publication No.3703), June 2004, p.2-1, 각주 1 및 2.

43) 여기에서의 자연인은 서비스공급자 자신이거나, 서비스공급자에 의해 고용된 자일 수도 있다. Mary E. Footer, The International Regulation of Trade in Services Following Completion of the Uruguay Round, The International Lawyer, Vol.29, No.2, 1995, p.464.

다. 이 가운데 미국, 호주, EC(영국 등)는 국내변호사와의 제휴·합작 및 고용허용 등을 요구하고 있어 협상의 쟁점이 되고 있다. 예를 들어, 미국이 한국에 제출한 양허 요청서에 따르면 법무서비스의 Mode 1, 2 및 3에 대해 완전한 시장접근 및 내국민 대우를 양허해 줄 것을 요청하였고, 여기에는 국내로펌과의 동업 및 합작법률회사의 설립과 국내변호사의 고용허용 요구까지 포함되어 있다.

이에 따라 2003년 3월 각국이 제출한 개방요구의 내용 및 회원국들의 개방현황과 과정을 종합적으로 고려하고, 기업 등 법률서비스의 소비자와 대한변협 등 공급자들의 의견을 수렴하여 우리나라의 법률서비스 개방에 관한 1차 양허안(Initial Offer)을 작성하여 WTO에 제출한 바 있다. 우리나라의 DDA 1차 법률시장 개방안은, 제한적 면허방식(Limited Licensing Approach)에 입각하여 외국변호사가 우리나라의 국내자격을 별도로 취득하지 않고도 국내에서 자격취득국법과 국제법에 관한 자문(consultancy) 서비스를 제공할 수 있도록 하는 이른바 외국법자문사(Foreign Legal Consultant: FLC) 제도를 도입하는 것을 골격으로 한다.

그 주요 내용을 살펴보면, ⅰ) 외국변호사에게 자격취득국법 및 국제공법에 대한 법률자문을 허용하고 ⅱ) 외국로펌의 국내 지사(representative offices) 설립을 허용하며 ⅲ) 외국로펌의 국내변호사의 고용 및 국내변호사와의 동업을 금지하고 있다.[44] 따라서 개방안에 따르면 외국로펌을 전제로 하지 않은 채 우리나라에 새롭게 외국로펌을 설립하는 것은 허용되지 않으며, 자격취득국법 및 국제공법에 대하여도 '자문'이 아닌 서류 작성, 소송 대행 등은 금지되는 것이다. 그 밖에 양허안의 내용에 따르면 자격 취득국에서의 3년을 포함하여 7년 이상 법률사무에 종사하였을 것, 본국 법조계에서 좋은 평판을 가지고 있을 것, 고객에게 가한 손해를 배상할 충분한 능력이 있을 것 등을 요건으로 하고 있어 외국 변호사의 무분별한 유입에 따를 부작용을 최소화하기 위한 요건을 마련하여 두었다.[45]

2차 양허안(Revised Offer)은 2005년 5월 말에 제출하였는바, 주로 자연인의 이동(Mode 4) 가운데 1차 양허안에 포함되지 않은 계약서비스 공급자(Contractual Service Supplier)의 양허에 중점을 두었으며, 법률서비스와 관련하여서는 '대표사무소는 적절한 사업계획과 재정적 기반을 유지하여야 하며, 수익적 활동을 할 수 있다'고 하여 명확성을 제고하는데 그쳤다.

한편 2005년 12월 홍콩에서 제6차 각료회의가 개최되었는바, 서비스 협상의 방식을 기존의 양자 양허협상에 추가하여 복수 양허협상방식을 도입하여 협상의 원활화를 도모하였고, 제2차 수정 양허안 제출은 2006년 7월 말, 그리고 최종 양허안 제출은 2006년 10월 말로 각각 합의하였지만, 이미 설명한 대로 최근 협상이 중단된 상태이다.

---

44) 2005. 9. 1자 법률신문을 참조할 것.

45) 김형준, 법률시장 개방협상 현황과 향후과제, 법조. 2005. 3, 27-28면.

Ⅱ. 주요국의 법률시장 및 개방 현황

1. 법률서비스 시장의 현황

최근 발표된 OECD 보고서에 의하면 매출액을 기준으로 세계 100대 로펌 중 최상위 98개는 미국(69개)·영국(17개)·호주(7개)·캐나다(5개)의 로펌이며, 또한 변호사 수를 기준으로 한 세계 20대 로펌도 미국(10개)·영국(9개)·호주(1개)의 로펌으로 나타난 바 있다.[46] 이렇듯 국제적 법률서비스 시장에서 영미계 로펌이 법률시장을 거의 장악하고 있을 뿐만 아니라, 최근 들어 더욱 성장세를 보이고 있다. 최근 DDA 서비스 협상 등에서 미국, 영국, 호주 등이 우리나라를 포함한 법률시장 미개방국에 대한 시장개방의 거센 요구를 하고 있는 이유를 어느 정도 짐작할 수 있을 것으로 보인다.[47]

<표-> 고용변호사 수 기준 세계 상위 로펌의 현황 (2002년)

순위	로 펌 명	본사 소재지	변호사 수	본국 변호사 비율	진출국 수
1	Clifford Chance	UK	3,322	63%	19
2	Baker & McKenzie	US	3,094	83%	37
3	Freshfields Bruckhaus Deringer	UK	2,430	61%	18
4	Allen & Overy	UK	2,197	48%	20
5	Linklaters	UK	2,000	52%	22
6	Eversheds	UK	1,776	4%	6
7	Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom	US	1,653	10%	12
8	Jones, Day, Reavis & Pogue	US	1,565	18%	12
9	Lovells	UK	1,432	55%	15
10	White & Case	US	1,427	60%	24

46) OECD Trade Policy Working Paper No. 2 「Managing Request-Offer Negotiations Under the GATS: The Case of Legal Services」 참조할 것; 재인용 김형준, 전게논문, 법조 2005. 3, 22면.

47) 국제법률서비스 시장의 현황에 대하여는 김순석, 법무서비스 시장개방의 주요 쟁점, 법조 2004. 12, 8면 이하를 참고.

11	Latham & Watkins	US	1,400	17%	10
12	Sidley Austin Brown & Wood	US	1,400	11%	6
13	Holland & Knight	US	1,212	0%	1
14	Mayer, Brown, Rowe & Maw	US	1,197	26%	5
15	Minter Ellison Legal Group	Australia	1,139	5%	6

출처: The American Lawyer / Legal Business
OECD Trade Policy Working Paper No. 2 pp. 32-33(TD/TC/WP(2003)40/FINAL)

한편, 우리나라 법무 관련 서비스업 총 매출액은 2001년도 기준 2조 488억 원이며, 그 중에서 변호사업의 매출액은 약 9,672억 원에 달하고, 법무사업의 총매출액은 약 7,164억 원, 그리고 변리사업은 약 1,667억 원 정도이다.[48] 2001년도 한국은행 자료에 따른 국내총생산(GDP)이 622조 1,230억 원 상당이므로 법무 관련 서비스업이 차지하는 비율은 0.32% 정도에 불과하고, 최근 들어 국내 로펌간의 제휴·합병으로 대형화·전문화를 꾀하고 있으나, 아직 영미계 로펌 등 선진국에 비하면 경쟁력이 매우 취약한 상황이다.[49]

<표- > 우리나라 법무서비스 산업 업종별 현황

구 분	사업체 수(개)	종사자 수(명)	매출액(백만원)
사업서비스업	65,615	689,654	50,449,914
법무 및 회계관련 서비스업	14,240	82,783	3,931,547
법무관련 서비스업	8,765	43,896	2,048,821
변호사업	2,380	14,891	967,259
변리사업	296	3,650	166,717
법무사업	3,942	20,223	716,440
기타 법무관련 서비스업	2,147	5,132	198,405

48) 우리나라의 법률서비스 시장에 대한 통계는 매 5년마다 통계청에서 시행하는 '도소매업 및 서비스업 총조사' 결과에 포함되어 있는데, 가장 최근 통계는 2001년도 통계이고, 현재 2006년도 조사가 이루어지고 있다. 김형준, 법률시장 개방협상 현황과 향후과제, 법조, 2005. 3, 25-26면 참조.

49) 최재천, 대형화·전문화 이상의 노력이 필요하다 (특집Ⅱ. 법률시장개방의 대응방안), JURIST, 2003. 4, 50-54면 참조.

2. 주요국의 법률시장 개방현황

이하에서는 우리나라의 입장에서 참고할 수 있는 사례로써 법률서비스 시장을 이미 개방한 경험을 가진 국가 가운데 대륙법계 국가로서 우리나라와 유사점을 가진 독일과 일본의 경우를 통해 법률시장 개방이 가져온 시장잠식 등 부작용의 예와 장기적 준비를 통한 안정적 개방의 예를 아울러 살펴보고자 한다.

1) 독일의 경우

독일에서는 유럽연합(EU)이나 유럽경제지역(EEA) 회원국 출신 변호사들이 1977년부터 이미 보다 완화된 요건 하에서 법률 활동을 수행할 수가 있었다.[50] 즉 최소 3년 동안 유럽변호사로서 전문적인 법률 활동을 수행한 경우 원자격취득국법(原資格取得國法)의 법학교육 졸업학력을 인정받아 필기 및 구두의 적응테스트를 거쳐 영구적으로 독일에서 변호사로서 활동을 할 수 있었다.[51]

더 나아가 1998년 유럽연합이사회(EU Council)가 유럽공동체조약안에 보장된 법률사무소 설립의 권리와 국경을 넘나드는 활동을 보장하기 위하여 '설립지침'(establishment directive)을 통과시켜 2000년 3월 14일까지 회원국의 국내법에 반영되도록 하였고, 이에 독일에서는 "유럽변호사의 독일 내 활동에 관한 법률"(Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwalte in Deutschland EuRAG) 제11조 내지 제15조를 통해 위 지침이 입법화되어 유럽변호사는 2003년 3월부터 독일 내에서 원자격취득국에서 인정되는 전문직 명칭을 이용하여 어떠한 시험을 통과하지 않고서도 외국법과 국제법 관련 자문활동을 할 수 있게 되었다.

또한 1994년부터 서비스무역에 관한 협정(GATS)에 따라 WTO회원국 출신 변호사에게 제한된 범위 내에서 자격취득국법에 대한 자문을 허용하고 독일변호사와의 국제적 파트너쉽을 형성할 수 있도록 하였다.

법률시장이 개방될 경우 법률서비스 시장은 빠른 속도로 영미계 로펌에 시장잠식될 가능성이 있으며, 이는 독일·프랑스 등 비영어권의 대다수 대륙법계 국가들이 시장개방 이후 공통적으로 경험한 바가 있다. 실제로 독일은 시장개방 후 영미계 로펌들에 의하여 시장이 잠식되어 10대 로펌 중 순수한 독일로펌은 Hengeler Müller 1개만 남아있다.[52] 1990년대 중반 이후 변

---

50) 김형준, 법률시장 개방협상 현황과 과제, 인권과 정의, 2005. 2, 87-88면.

51) Directive 89/48/EEC상의 관련규정이 '독일 내 유럽변호사의 활동에 관한 법률' 제16조 내지 제24조를 통하여 입법화되었다.

52) 더욱이 상위 3대 로펌(Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Punder 및 Linklaters Oppenhoff & Redler)은 모두 영국로펌에 인수, 합병되었다. 또한 변호사 수가 200명에 이르는 독일 10대 로펌 중 하나였던 Gaedertz는 당해 로펌의 지방 법률사무소가 영미로펌들에 의해 분리 인수되면서 결국 해체되어 공중분해되는

호사 수가 10년 사이에 2배 이상 급증하여 현재 12만 명 선으로 변호사들의 10% 정도가 부업을 가지고 있으며 2002년도에는 16%가 자격증을 반납하는 등 매우 어려움을 겪고 있다.[53]

유럽계 로펌의 경우 지역통합 진전 등으로 영국로펌을 중심으로 EU 역내 M&A가 증가하였고 특히 Clifford Chance, Freshfields 등이 이를 활용하여 세계적 로펌으로 부상하였고, 실질적으로 독일, 프랑스 등 대륙법계 국내 로펌들 대부분이 영국로펌 또는 미국계 회계법인에 의하여 해체, 흡수·합병된 상황이다.

2) 일본의 경우

일본의 경우를 살펴보면 1987년 4월 "외국변호사에의한법률사무취급에관한특별조치법"(이하 "외변법"이라 한다)에 의하여 외국법사무변호사제도가 도입되어 최초로 법률시장을 개방하였으나, 당시 일본 변호사와의 동업 및 고용을 전면 금지하고 현재 우리나라의 1차 개방안의 수준에서 문호를 열었다.[54]

1994년 6월 외변법 제3차 개정을 통하여 제한적 제휴형태인 특정공동사업의 공동경영을 허용한 바 있다.[55]

또한 1998년 5월 외변법의 제6차 개정시 특정공동사업의 목적과 허용범위를 확대하여 단계적 개방의 범위를 넓혔다.

2003년에는 외변법 제10차 개정을 통하여 2005년 4월 1일부터 일본 변호사와의 동업 및 고용을 전면적으로 허용함과 동시에 변호사법인 도입에 따라 일종의 파트너쉽인 '특정공동사업'을 '외국법공동사업'으로 대체하였다.[56] 이는 "사법제도개혁을위한재판소법등의일부를개정하는법률"(2003년 법률 제128호)에 의해 외변법 제49조가 철폐되어 외국법사무변호사와 일본변호사간의 동업, 외국법사무변호사에 의한 일본변호사의 고용이 자유화된 것이다.

경우마저 생겼다. 보다 자세한 것은 문재완, 법무서비스시장 개방의 과제, 통상법률, 2005. 4, 15-18면 참조.

53) 특히 독일 변호사업계가 영미 메가펌에 흡수·통합된 원인을 기술한 것으로는, 김순석, 법무서비스 시장개방의 주요 쟁점, 법조 (2004. 12), 44~45면.

54) 아시아 주요 국가들의 법률시장 개방에 관하여 보다 자세한 것은 신왕철, 법률시장개방에 관한 연구, 부산외국어대학교 교육대학원석사학위논문, 2004. 8, 44-106면 참조.

55) '특정공동사업'은 외국법사무변호사와 일본변호사의 파트너쉽의 자유화를 요구하는 영미의 요구에 따라 1994년에 신설된 제도로, 신설 초기에는 이를 이용하는 로펌이 없고 활용하기 어려운 규제적인 제도라는 비판이 있었으나 점차 그 이용이 활성화되었으며 Freshfields, Clifford Chance, White & Case 등 소위 글로벌 메가펌도 이를 활용하게 되었다. 김순석, 법무서비스 시장개방의 주요 쟁점, 법조, 2004. 12, 22-23면.

56) 외변법 제2조 제15호에 따르면 '외국법공동사업'은 "외국법사무변호사와 변호사 또는 변호사법인간에 조합계약 기타 계속적인 계약에 의해 법률사무를 행하는 것을 목적으로 하는 공동사업"으로 정의된다.

이와 같이 일본은 첫 시장개방에서부터 무려 약 17년에 걸쳐 10차에 걸친 법 개정을 통하여 단계적으로 시장개방을 확대하면서 문제점을 분석하고 자국 법률서비스의 경쟁력을 제고시키는 과정을 거쳐 왔기 때문에, 우리가 개방화의 길을 모색함에 있어 반드시 참고해야 할 것으로 사료된다.[57]

57) 김형준, 법률시장 개방협상 현황과 과제, 인권과 정의, 2005. 2, 89-91면.

Ⅲ. 소결

국제적으로 DDA를 위시한 개방논의가 끊임없이 이어져 왔으며, 우리정부 역시 기본적으로 개방이 거시적으로 유리하다는 판단을 견지하고 있는바, 이러한 상황에서는 DDA이든 FTA 방식이 되었던 일단 개방이 불가피한 것으로 판단된다. 하지만 이미 개방화의 길을 거친 독일과 일본의 예에서 알 수 있듯이, 개방의 범위와 단계설정은 향후 파급효과의 고려와 충분한 검토가 필요하다.[58]

특히 지적재산권 분야는 그 절차는 물론 실체적 사항까지 통일화·국제화되고 있는 추세이다.[59] 또한 다국적 기업들이 우리나라에 진출하여 활동하고 있고, 우리나라의 기업들 역시 국제거래와 관련된 다양한 활동을 하고 있는 상황에서, 지적재산권과 관련된 많은 법률문제들이 다양하게 발생할 것임은 자명한 일이다. 이러한 상황에서 국내 법률서비스 공급자의 보호만을 일방적으로 주장하는 것은 법률서비스 수요자의 필요함(needs)을 외면하는 것으로 수긍하기가 어렵다고 하겠다.

결국 법률개방화에 있어서 그 범위 및 시기에 따라 단계별로 개방을 하는 것이 바람직할 것으로 보이며, 앞으로 주어지게 되는 기간 동안 민간 차원에서는 개방에 대비한 전문화와 대형화 등 자체적인 경쟁력을 강화시키는데 힘을 써야 할 것이다. 법률개방화 가운데 특히 지적재산권분야에서, 행정부와 사법부는 대승적으로 특허심판원과 특허법원의 전문화 및 효율화를 도모하여 지재권 분쟁해결시스템의 국제적 수준으로 끌어 올리는데 노력해야 할 것이며, 대리인의 직무범위를 합리적으로 조정하고 이를 위한 선발 및 양성제도를 개선하여 민간차원의 노력

---

58) "전면개방 땐 시장기반 붕괴우려…무너진 독일, 지켜낸 일본", 내일신문, 2006. 5. 10, 19면에 따르면 정부는 한미 FTA 타결 직후부터 외국로펌이 국내에 사무소 설치하거나 국내에서 외국 법률에 대한 자문을 할 수 있게 하고, 2008년부터는 국내 법인과 업무제휴를 할 수 있도록 하며, 2011년부터는 국내 법인과 합작을 하거나 내국인 변호사를 고용할 수 있는 전면 개방형태의 3단계 전략을 다음과 같이 구상하고 있다고 한다.

<표-> 법무부의 단계적 법률시장 개방 전략

1단계(2006년)	외국법자문 및 사무소 개설 허용 〈일본의 1987년 최초 개방 수준〉
2단계(2008년)	국내변호사와 제휴 허용 〈일본의 1994년 UR 당시 개방 수준〉
3단계(2011년)	동업 고용 등 전면 개방 〈일본의 2005년 4월 개방 수준〉

59) 파리협약, WTO/TRIPs, PCT, SPLT 등 각종 국제조약 및 다자간 협정이 체결 또는 논의 중에 있으며, 미국, EU, 일본 등 소위 3극 특허청간에 긴밀한 협력과 국제무대에서의 영향력 행사에 의해서도 이러한 추세는 계속될 것으로 예상된다.

을 뒷받침하여 국제경쟁력을 갖추어야 할 것이다.

이하에서는 법률개방화에 대비하여 우리의 지적재산권 소송체계의 개선점에 대하여 보다 자세히 논하고자 한다.

제 3 장

특허쟁송제도의 개선방안

경제전쟁시대에 있어 특허제도를 적정하고 원활하게 운영하는 것은 발명가나 기업 또는 국민 모두에게 이익을 주는 것이다. 21세기는 산업재산권을 중심으로 한 지적재산권이 국가경쟁력을 좌우하는 가장 중요한 경제수단이라고 할 수 있다. 정보통신기술(IT), 생명과학기술(BT), 나노기술(NT)을 비롯한 신기술이 상호융합 발전하면서 기술혁신이 더욱 가속화 되어가고 있다. 이러한 산업재산권, 특히 특허권은 인간의 기술적 사상을 대상으로 하는 것으로서 그 권리의 대상 자체가 일반적인 소유권과 비교할 때 명확하지 않아 특허권자와 침해자 사이에 분쟁이 빈번하게 일어나고 있는 실정이다. 이러한 지적재산권 분쟁을 적정하고 신속하게 해결하는 진정한 권익구제수단이 특허쟁송제도라고 할 수 있다.[60]

본 장에서는 우선 특허심판제도가 등장하게 된 배경을 먼저 살펴보고, 특허심판의 의의를 고찰하게 된다, 그런 연후에 주요국과 비교하여 특허심판원의 기능 및 현황에 대하여 살펴봄으로써, 법률시장의 개방에 따른 우리 특허심판원의 개선방향을 찾아보고자 한다. 또한 특허심판과 특허법원간에 어떠한 쟁송체계를 갖추는 것이 바람직할 것인가에 대하여도 아울러 고찰하고자 한다.

Ⅰ. 심급구조의 변화

종래 우리나라의 특허심판은 '심판소'과 '항고심판소'에 의해 운용되어 여기에서 내려진 심결에 불복하는 당사자는 '대법원'에서의 상고심 판결을 구할 수 있었다.[61] 이러한 제도는 해방 후 우리나라 최초의 특허법인 1946년 10월 5일 제정된 군정법령 91호가 일본 1921년 법상의 제도를 그대로 답습한 것에 기인한 것이다.

이러한 상황은 특허심판소와 항고심판소가 특수한 법원인지, 법원이 아니라면 행정심판기관

60) 천효남, 특허법, 21c 법경사(2006), 91면, 특허권침해소송에 관한 분쟁해결은 사법적 판단이 필요하므로 법원의 소관사항이지만 특허권을 둘러싼 기술적 사항에 관한 분쟁은 기술전문가로 구성된 특허심판원에서 일정단계까지 관장하는 것이 분쟁의 합리적 해결에 유익할 수 있고, 민사소송절차와 매우 흡사한 제도가 심판제도라고 기술하고 있다.

61) 자세한 설명으로는 송영식·이상정·황종환, 지적소유권법, 육법사 제9판 (2005), 673면을 참조, 종래 특허심판제도는 행정청 내부에 설치된 심판소에서 법관의 자격을 갖추지 아니한 심판관이 1, 2심 모두를 심리하므로 법관에 의한 사실심리의 기회가 주어져 있지 않아 문제점을 가지고 있었던 것이다.

에 해당하고 그 심결을 행정처분이라고 보아야 할 것인지,[62] 심판관의 자격과 신분보장이 사법작용을 담당하기에 충분한 것인지, 심판절차는 공정하고 적정하게 이루어지는 지 등의 여러 가지 문제점이 제기되었다.[63] 그러는 와중에 지난 92년부터 94년에 걸쳐 특허법 제186조 제1항 등에 대한 4차례 위헌제청이 있었다.[64] 이러한 위헌제청에 대하여 헌법재판소는 종래의 특허심판제도에 대하여 헌법불합치결정을 선고함으로써 특허법이 개정되어 1998년 3월 1일 특허심판원이 개원하게 되어 동 심판원에서의 심결 등에 대한 불복의 소는 같은 시기 개원한 특허법원에 전속하는 것으로 변경되었다. 먼저 구 특허법 제186조가 어떠한 문제점을 가지고 있었는가에 대하여 살펴보기로 한다.

1. 구 특허법 제186조 제1항의 위헌법률심판

위법한 행정행위로 인하여 기본권의 침해를 받은 국민은 행정소송을 제기함으로써 기본권의 보호를 받을 수 있는데, 우리나라는 일반법원으로 하여금 행정소송을 재판케 하고 있다.[65] 그러나 행정소송의 전심절차로서 행정심판을 할 수 있도록 했지만, 행정심판에서도 사법절차가 준용되도록 함으로써 행정심판절차에서도 기본권보호의 실효를 거두도록 노력하고 있다.[66] 즉 당시에는 행정처분이나 공법상의 법률관계에 관한 분쟁에 대하여는 원칙적으로 전심절차로서의 행정심판을 거친 다음 고등법원을 1심으로 하는 행정소송을 제기할 수 있었다.

그러나 구 특허법에 의하면, 특허청의 거절사정, 보정각하결정, 심결 및 항고심결 등은 행정

62) 1962. 3. 15. 고지 4292 행상 8 결정을 참조.

63) 특허사건의 대법원에서 파기율이 다른 행정사건의 경우보다 매우 높게 나타나고 있는 점이 커다란 문제점으로 지적되었다. 사법연감에 의하며 1992년 대법원에서 처리된 상고사건 중 파기환송된 비율이 일반민사본안사건은 8.2%, 행정사건은 15.2%인데 반해서 특허사건은 31%에 달하고 있었다.

64) 김태윤, 특허심판원 5년의 회고와 전망, 특허심판원 개원 5주년 기념 세미나 자료집, 특허심판원, 2003. 7. 16, 12면.

<표-> 위헌법률심판 제청현황

제청일자	제청법원	사건번호	현 황
'92. 1. 11	대 법 원	92헌가 1, 2	상고인 본인 제청취하
'92. 7. 7	서울고등법원	92헌가 11	헌법불합치('95.9.28)
'93. 8. 25	대 법 원	93헌가 8, 9, 10	〃
'94. 1. 13	서울고등법원	94헌가 1	소 취하

65) 행정소송에 대하여는, 김철용, 행정법 I, 박영사, (2005), 552면 이하.

66) 헌법 제107조 제2항: 명령·규칙 또는 처분이 헌법이나 법률에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 대법원은 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다. 제3항: 재판의 전심절차로서 행정심판을 할 수 있다. 행정심판의 절차는 법률로 정하되, 사법절차가 준용되어야 한다.

처분의 한 형태임이 분명함에도 불구하고, 그에 대하여 고등법원에의 제소가 허용되지 아니하고 특허법이 정하는 바에 따라 항고심판의 심결과 보정각하결정에 대하여서만 그 심결이나 결정이 법령에 위반된 것을 이유로 하는 경우에 한하여 대법원에 상고할 수 있도록 되어 있었다.[67] 일반 행정소송에 있어서는 사실심인 고등법원의 재판과 법률심인 대법원의 재판의 형식을 갖추고 있는데 반하여, 특허쟁송에 있어서는 특허청의 심판과 항고심판에서 사실심이 모두 끝나고 그 다음에는 고등법원의 재판을 거침이 없이 곧 바로 법률심인 대법원의 재판을 받게 되는 것이 우리 헌법상 용인될 수 있는가에 대하여 다툼이 있었던 것이다.[68]

1) 수압을 이용, 중력을 동력으로 바꾸는 장치[69]

위헌제청신청인은 1988. 7. 7. 특허청에 "수압을 이용, 중력을 동력으로 바꾸는 장치"에 대하여 특허출원을 하였으나 거절사정을 받고 1990. 12. 28. 위 거절사정에 대한 항고심판을 청구하였으나 1991. 11. 30. 청구기각의 심결을 받자 1992. 1. 4. 대법원에 상고를 하였으나, 대법원은 신청인의 상고를 기각하였다.

한편 신청인은 위 항고 심판청구와는 별도로 1991. 10. 14. 서울고등법원에 특허청장을 상대로 위 거절사정처분의 취소를 구하는 행정소송을 제기함과 동시에 특허청의 항고심판심결에 대하여는 곧바로 대법원에 상고하도록 되어 있는 현행 특허법 제186조 제1항의 위헌 여부가 위 행정소송의 적법 여부의 전제가 된다고 주장하면서 같은 법원에 위 조항에 대한 위헌제청신청을 하였고, 위 법원은 이를 받아 들여 이 사건 위헌제청을 하게 된 것이다.

2) 낚시찌의 제조방법에 관한 사건[70]

신청인은 1985. 10. 10, 특허청에 "낚시찌"의 제조방법에 관한 발명특허출원을 하여 1988. 1. 13. 등록 제24832호로 특허되었는데, 그 후 김00이 새로운 "낚시찌" 제조방법에 관한 발명을 하였다.

---

67) 구 특허법 제186조 (상고대상) ① 항고심판의 심결을 받은 자 또는 제170조 제1항의 규정에 의하여 준용되는 제51조 제1항의 규정에 의한 각하결정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 그 심결이나 결정이 법령에 위반된 것을 이유로 하는 경우에 한하여 심결 또는 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 대법원에 상고할 수 있다. 의장법 제75조 (특허법의 준용) 특허법 제179조, 제180조, 제182조 내지 제185조의 규정은 재심에 관하여, 제186조 내지 제191조의 규정은 소송에 관하여 이를 각 준용한다.

68) 헌재 1995. 9. 28, 92헌가11, 93헌가8・9・10(병합).

69) 92 헌가 11 사건.

70) 93 헌가 8 사건.

신청인으로부터 권리의 대항을 받게 된 위 김00은 특허청에 신청인의 위 제24832호 특허발명에 관한 권리범위확인심판청구를 하였고, 특허청은 1990년 9월 2일 위 김00의 발명이 신청인의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다.

신청인은 위 심결에 불복하여 특허청항고심판소에 항고심판을 청구하였으나 1992년 9월 26일 청구기각의 심결을 받고 대법원에 상고를 제기함과 동시에 위 항고심판심결에 대한 상고제기의 근거가 되는 특허법 제186조 제1항의 위헌여부심판제청을 신청하였다. 하지만 대법원은 이를 받아들여 이 사건 위헌신청을 하였다.

3) 오일탱크 및 소음기 사건[71]

신청인은 특허청에 최00의 출원에 의한 등록 제71102호 의장 "오일탱크"와 등록 제86928호 의장 "소음기"에 대하여 각각 등록무효심판을 청구하였으나, 위 오일탱크에 대하여는 1990년 9월 21일에, 그리고 위 소음기에 대하여는 같은 달 29일에 각각 청구기각의 심결을 받고. 1992년 12월 19일 그에 대한 항고심판청구마저 모두 기각되자 대법원에 위 최00을 피상고인으로 하여 각 상고를 제기하면서 위 항고심판심결에 대한 상고제기의 근거가 되는 현행 의장법 제75조 중 특허법 제186조 제1항을 준용하는 부분과 등 특허법조항의 위헌여부심판제청을 신청하였고, 대법원은 이를 받아들여 이 사건 위헌제청을 하였다.[72]

2. 위헌론을 제기한 제청신청인들의 입장

이들은 종래 사실심을 특허심판에 전속하고 있는 특허심판제도가 위헌이라고 주장하는 근거를 헌법상의 기본권에서 찾고 있다. 간략하게 살펴보도록 한다.[73]

첫째, 특허청의 항고심판의 심결 또는 각하결정에 대하여는 곧바로 대법원에 상고하도록 되어 있는 현행 특허사건의 상고제도로 인하여 국민은 사실심재판에 관한 한 헌법 제27조 제1항에서 보장하고 있는 법관에 의한 재판을 받을 권리를 박탈당하고 있으므로 이 사건 심판대상 법률조항은 위 헌법조항에 위배된다는 것이다.[74]

---

71) 93 헌가 9·10.

72) 대법원의 위헌제청결정에 대하여, 특허청의 심판은 대법원재판의 전심절차로서 그 설치근거가 뚜렷하고 특허청의 심판을 거친 후에 대법원의 심리를 받을 수 있도록 되어 있어 법원의 심리를 거치게 되어 있는 심급구조는 사법국가주의에 반하지 아니한다는 점과 특허사건은 일반법관으로 구성된 사법부의 관할로 하는 것 보다는 특수전문지식을 가진 심판관들로 구성된 특허청심판소가 심판하는 것이 오히려 합리적이고 합목적적이라는 점에서, 특허청과 변리사업계는 격심한 반론을 제기하였다.

73) 위헌론의 근거에 대한 설명으로는 김인만, 현행특허심판제도의 위헌성에 관한 고찰, 인권과 정의, 1990. 4, 5면; 박일환, 현행특허심판제도의 재판청구권, 지적소유권에 관한 제문제(상), 24면 이하.

둘째, 심판대상 법률조항이 특허사건의 사실심은 특허청 항고심판소의 항고심판이 최종심으로 되도록 하고 있다. 그러므로 사법권의 일부가 행정기관인 특허청심판소에 귀속되어 사법권은 법원에 속한다는 헌법 제101조 제1항의 사법국가주의 내지 삼권분립의 원칙에 위배된다는 것이다.[75] 뿐만 아니라 재판의 전심절차로서만 행정심판을 할 수 있도록 한 헌법 제107조 제3항의 규정에도 위배된다는 것이다.[76]

셋째, 다른 행정처분은 고등법원에서 법관에 의한 사실심판단을 받을 수 있는데 특허사건만 법령위반에 한하여 대법원의 단심만 허용하는 것은 받아들이기 어렵다는 것이다. 즉 심판대상 법률조항은 다른 행정사건과 달리 특허사건의 당사자에게는 고등법원의 재판을 받을 수 없도록 함으로써 모든 국민은 법 앞에 평등하다는 헌법 제11조 제1항의 규정에도 위배된다는 것이다.[77]

3. 헌법재판소의 견해

1) 사법국가주의 및 재판청구권과의 관계

우리 헌법 제27조 제1항은 "모든 국민은 헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다"고 규정함으로써 모든 국민은 헌법과 법률이 정한 자격과 절차에 의하여 임명되고(헌법 제101조 제3항, 제104조, 법원조직법 제41조 내지 제43조), 물적 독립(헌법 제103조)과 인적 독립(제106조, 법원조직법 제46조)이 보장된 법관에 의하여 합헌적인 법률이 정한 내용과 절차에 따라 재판을 받을 권리를 보장하고 있다. 여기서 법관에 의한 재판을 받을 권리를 보장한다고 함은 결국 법관이 사실을 확정하고 법률을 해석·적용하는 재판을 받을 권리를 보장한다는 것을 의미한다. 그러므로 법관에 의한 사실확정과 법률의 해석적용이 기회에 접근하기 어렵도록 제약이나 장벽을 쌓아서는 아니 된다고 것이다. 만일 그러한 보장이 제대로 이루어지지 아니한다면 헌법상 보장된 재판을 받을 권리의 본질적 내용을 침해하는 것으로서 우리 헌법상 허용되지 않는다는 것이다.[78]

---

74) 헌법 제27조 (재판을 받을 권리) ① 모든 국민은 헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다.

75) 헌법 제101조 (사법권과 법원) ① 사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다.

76) 헌법 제107 (위헌법령 심판제청, 명령 등 심사, 행정심판) ③ 재판의 전심절차로서 행정심판을 할 수 있다. 행정심판의 절차는 법률로 정하되, 사법절차가 준용되어야 한다.

77) 헌법 제11조 (평등권) ① 모든 국민은 법 앞에 평등하다. 누구든지 성별·종교 또는 사회적 신분에 의하여 정치적·경제적·사회적·문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다.

78) 헌법 제37조 (국민의 자유와 권리의 존중, 제한) ② 국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다.

그런데 특허법 제186조 제1항은 특허청의 항고심판절차에 의한 항고심결 또는 보정각하결정에 대하여 불복이 있는 경우에도 법관에 의한 사실확정 및 법률적용의 기회를 주지 아니하고 단지 그 심결이나 결정이 법령에 위반된 것을 이유로 하는 경우에 한하여 곧바로 법률심인 대법원에 상고할 수 있도록 하고 있는바, 특허청의 심판절차에 의한 심결이나 보정각하결정은 특허청의 행정공무원에 의한 것으로서 이를 헌법과 법률이 정한 법관에 의한 재판이라고 볼 수 없다는 것이다.

우리 헌법은 국가권력의 남용을 방지하고 국민의 자유와 권리를 확보하기 위한 기본원리로서 채택한 3권 분립주의의 구체적 표현으로서 일체의 법률적 쟁송을 심리 재판하는 작용인 사법작용은 헌법 그 자체에 의한 유보가 없는 한 오로지 대법원을 최고법원으로 하는 법원만이 담당할 수 있고 또 행정심판은 어디까지나 법원에 의한 재판의 전심절차로서만 기능하여야 함을 의미한다.[79] 그런데 특허청의 항고심판심결이나 결정은 그 판단주체로 보아 행정심판임이 분명하고 이러한 행정심판에 대하여는 법원에 의한 사실적 측면과 법률적 측면의 심사가 가능하여야만 비로소 특허사건에 대한 사법권 내지는 재판권이 법원에 속한다고 하겠다. 하지만 특허법 제186조 제1항이 이러한 행정심판에 대한 법원의 사실적 측면과 법률적 측면에 대한 심사를 배제하고 대법원으로 하여금 특허사건의 최종심 및 법률심으로서 단지 법률적 측면의 심사만이 할 수 있도록 하고 재판의 전심절차로서만 기능해야 할 특허청의 항고심판을 사실확정에 관한 한 사실상 최종심으로 기능하게 하고 있는 것은, 일체의 법률적 쟁송에 대한 재판기능을 대법원을 최고법원으로 하는 법원에 속하도록 규정하고 있는 헌법 제101조 제1항 및 제107조 제3항에 위반된다고 하지 않을 수 없다는 입장이다.

2) 평등권과의 관계

구 특허법 제186조 제1항의 입법목적은, 특허사건만이 갖고 있는 특수성을 감안하여 고도의 전문적 기술·지식과 급변하는 기술수준에의 적응력을 갖춘 행정청 내부의 전문가로 구성된 심판기관으로 하여금 특허분쟁에 있어서의 사실판단을 신속·정확하게 하여 특허분쟁을 적정하고 신속하게 해결하고 발명가의 권리를 보다 두텁게 보호하고자 했던 측면[80]에서 헌법재판소는 동 규정의 타당성을 일면 인정하였다. 하지만 헌법재판소는,

첫째, 특허법 제186조 제1항의 차별적 수단에 의하여 특허분쟁이 당사자가 잃게 되는 권리는 분쟁의 사실적 측면에 관하여 법관에 의한 재판을 받을 권리이고, 이는 헌법상 보장된 재판

79) 참고할 조문으로는 헌법 제101조 (사법권과 법원, 법원의 자격) ① 사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다. ② 법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다.

80) 특허청과 변리사업계에 따르면, 특허사건은 그 심판대상물이 발명, 고안의 구성요건, 그 신규성이나 진보성 등의 판단 및 첨단기술의 실체파악이 없이는 사안의 정확한 판단이 불가능한 특수한 전문성을 가진 것들이어서 특허청 심판소가 심판하는 것이 적절하다는 주장을 한 바 있다.

청구권의 본질적 내용을 이루는 것으로서 이를 제한하는 차별입법은 허용될 수 없고,

둘째, 특허분쟁 역시 특허출원인, 특허권자와 행정청 또는 이해관계인과의 사이에서 발생하는 법률적 분쟁임에는 다툼의 여지가 없고, 법률적 분쟁의 해결절차인 재판제도의 요체가 독립한 중립적 기관에 의한 판단이라는 데 있는 점을 감안하면, 특허분쟁에 관한 재판의 적정성도 비단 법률적 측면뿐만 아니라 사실적 측면을 판단하는 재판기관의 독립성을 희생하고서는 실현되기 어렵고,

셋째, 현행 특허쟁송제도에 있어서와 같이 특허청 내부에서 2회의 심판을 거치게 한 다음 법원에 의한 법률적 측면에 관한 1회의 심판을 받게 하는 것이, 일반행정소송에 있어서와 같이 1회의 행정심판만을 거친 다음 고등법원 및 대법원에 의한 2회의 심판을 받게 하는 것보다 반드시 신속한 절차를 보장하는 것이라고 볼 수도 없고,

넷째, 법원에 의한 사실심리기회의 박탈은 오히려 과학발명가들의 권리보호에 역행하는 결과를 초래할 수도 있다는 점에서,

특허법 제186조 제1항이 설정하고 있는 법원에 의한 사실적 측면의 심리를 받을 권리에 있어서의 차별은, 그 차별의 수단이 재판의 적정성·신속성이라는 입법목적의 달성에 도움이 되지 아니한다고 판단하였다. 더 나아가 그러한 목적에 어느 정도 도움이 된다 하더라도 분쟁당사자에게 헌법상 보장된 재판청구권의 본질적 내용을 침해하는 것으로서 그 차별의 합리성을 인정하기 어렵고, 따라서 특허법 제186조 제1항은 평등의 원칙을 규정한 헌법 제11조 제1항에 위반된다고 주장하였다.[81]

4. 결론

이러한 상황에서 제시된 해결방법 등을 살펴보면, 항고심판소를 폐지하고 법원에 제소하도록 하는 방안, 항고심판소와 통합하여 일원화하는 방안, 심판소와 항고심판소를 존치하고 그에 불복하거나 일정한 기간 내에 심결이 이루어지지 않을 경우 고등법원에 제소하는 방안 등이 제시되었다.[82]

헌법재판소는 특허쟁송제도에 관련된 위와 같은 강한 법적안정성의 요구와 이미 확인된 입법자의 합헌적인 의사를 존중하여 입법자가 마련한 합헌적인 제도가 유효하게 시행될 수 있을 때까지는, 비록 위헌성이 내포되어 있기는 하나 현행제도를 그대로 유지하는 것이 오히려 여러

81) 헌법 제11조 (평등권) ① 모든 국민은 법 앞에 평등하다. 누구든지 성별·종교 또는 사회적 신분에 의하여 정치적·경제적·사회적·문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다.

82) 김영란, 지적소유권의 쟁송제도, 지적재산권과 국제경쟁력, 국가과학기술자문회의, 220면 참조.

가지 충격과 혼란을 방지하고 과학기술자들의 두텁게 보호하는 효과적인 방안이 될 것이라고 판단하고, 심판대상법률조항에 대하여 헌법불합치를 선언하였던 것이다.[83]

그 결과 1998년 3월 1일부터 특허심판의 심급구조를 특허청의 심판소와 항고심판소를 통합한 특허심판원이 제1심을 담당하고 항고심판소 기능 중 제2심은 사법부의 전문법원인 특허법원에서 담당하도록 하였다. 다른 행정처분은 고등법원에서 법관에 의한 사실심판단을 받을 수 있는데 반하여 특허사건 또한 법령위반에 한하여 법관으로부터 재판 받을 권리를 만족시킬 수 있게 되었다.[84] 결국 우리나라 특허분쟁에 있어 사실상 1심의 역할을 수행하는 특허심판제도는 1998년 특허심판원 및 특허법원의 설치, 특허소송제도의 개혁과 공정하고 신속한 특허심판처리를 위한 특허심판원의 그간의 지속적인 제도 개선 등의 노력으로 많은 발전이 있었다.[85]

하지만 특허심판원은 그 설립 이후 현재까지 특허심판에 관한 체계적인 기획 및 연구를 담당할 마땅할 내부조직이 없어 새롭게 변화하는 특허관련 쟁송절차를 효과적으로 운용하지 못하고 있으며, 일반국민의 입장에서도 산업재산보호와 대민 법률서비스에 대하여 다소 문제점이 나타났다. 특허심판원은 개원 이래 조직의 정체성이 확립되지 못하고 있다는 비판도 제기되고 있다.

---

83) 헌법불합치선언의 목적은 우선적으로 위헌결정의 경우 위헌적 법률 또는 법률조항이 바로 그 효력을 상실하게 되는 법률효과를 회피하고 이를 형식적으로 존속하게 하는데 있다. 하지만 이러한 헌법불합치판결에 대하여 조승형 재판관은 헌법불합치결정 제도의 남용에 대하여 비판하고 위헌임을 선언해야 한다고 주장한다.

84) 전문성, 특허심판구조의 제도적 개선방안에 대한 연구 -비교법적 고찰을 통하여-, 충남대학교대학원석사학위논문 (2001), 3~4면.

85) 산업재산권 사건을 전담하는 특허법원은 설치되었지만, 재판관도 법률판사 외에 전문기술분야에 대한 지식이 있는 중에서 선발하는 소외 기술판사의 도입을 주장하는 특허청의 주장은 받아들이지 않았다.

II. 특허심판제도에 관한 고찰

특허출원에 대한 심사과정에 있어서 특허법은 출원인에게는 의견서 제출의 기회를 주고 제3자에게는 정보제공의 기회를 줌으로써 심사관에 의한 거절결정 또는 특허결정의 적정을 꾀하고 있다. 하지만 특허가 잘못 부여되거나 까닭 없이 심사관의 하자에 의하여 특허부여가 거절되는 경우에는 일반 공중 및 출원인의 권리·이익을 해치는 상황이 발생하기도 한다. 그 때문에 특허권의 발생, 변경(정정), 소멸(무효, 취소) 등 일정 사항에 대한 다툼을 해결하기 위하여 통상의 행정소송이나 민사소송과는 다른 특별한 쟁송절차로서 특허심판제도를 마련하였다.[86] 이러한 특허심판제도는 산업재산권 출원에 대하여 심사관이 행한 처분 또는 설정등록된 산업재산권의 효력 유무 등을 특허심판원에서 특허법원의 전심절차로 행하는 쟁송절차인 것이다. 그 결과 특허가 잘못 부여되거나 까닭 없이 특허부여가 거절되는 등 심사관의 처분에 하자가 있는 경우에, 일반 공중 및 출원인의 권리·이익을 해치지 않도록 하는 것은 말할 것도 없거니와 이를 통하여 국가의 산업발달에 기여하고자 하는 것이다.[87]

1. 특허심판의 법적 성질

특허심판제도는 크게 두 가지, 즉 협의의 특허심판과 광의의 특허심판으로 나누어서 설명할 수 있다.[88] 전자의 특허심판이란 특허출원에 대하여 심사관이 한 처분 또는 설정등록된 특허권의 효력 유무 등을 다투는 분쟁에 대하여 특허심판원에서 다투는 절차를 말한다. 반면에 후자는 산업재산권심판과 같은 의미로서, 비단 특허뿐만이 아니라 실용신안, 디자인, 상표 등 모든 산업재산권 출원에 대하여 심사관이 한 처분 또는 설정등록된 산업재산권의 효력 유무 등을 다투는 분쟁을 총칭하는 쟁송절차를 의미한다. 산업재산권 출원에 대한 등록 허부의 결정은 고도의 전문적인 기술내용을 바탕으로 이루어지게 된다. 그런데 이러한 결정내용에 하자가 있는 경우에는 일반 행정심판기관 또는 법원에서 그 내용의 하자 여부를 가리는 것보다 다년간 당해 전문분야에서 심사경험과 전문성이 축적된 기관에서 이를 판단하게 하는 것이 보다 합리적이라는 것이다.[89] 특허심판은 특별한 행정심판으로서 그 법적 성질에 관한 이론으로는 사법행위설, 행정행위설 그리고 준사법적 행위설로 다투어지고 있다. 하지만 특허심판제도는 형식적으로는 특허에 관한 일정한 분쟁을 해결하기 위하여 특허심판원 심판관의 합의체에 의해 심리결정되는 행정상의 쟁송절차이나 특허법원의 전심절차로서 소송에 준하는 엄격한 절차를 거쳐 판단되는 준사법적 성격을 가진 쟁송절차이다.[90]

---

86) 송영식·이상정·황종환, 전게서, 616면.

87) 천효남, 전게서, 766면을 참고.

88) 김정자, 우리나라 특허심판제도의 발전방안에 관한 연구, 한남대학교대학원석사학위논문 (2004), 4면.

89) 전문성, 전게논문, 7면을 참조할 것.

1) 일반적 행정행위와 차이점

행정심판은 공법관계에 분쟁이 발생한 경우에 당사자의 심판제기에 의하여 행정기관이 심리하여 판단하는 행정쟁송절차이다.[91] 행정관청인 특허청에서 이루어지는 특허심판은 그 심판행위에 대하여는 우선 직무상의 독립성이 보장된다. 또한 심판관은 공무원이라는 일반적인 자격외에 특별한 법정자격요건이 요구되며, 그 업무절차와 관련하여 그 행위의 효력은 법원의 재판과 유사하다. 그리고 일반 행정행위와는 달리 심판에 대한 불복절차는 특허법원과 대법원으로 이어지는 2심제이므로, 특허심판은 실질적인 제1심의 기능을 갖는 특징이 있다.[92]

따라서 특허심판원의 심결은 판결과 같은 기속력을 가지게 되어 심판관 자신은 물론 특허청장이나 산업자원부장관도 이를 변경·취소할 수 없고, 오직 특허법원의 소송절차로만 그 불복이 가능하다. 그러므로 그 심결이 확정된 때에는 누구도 그 효력을 부인하거나 취소·변경·소멸시킬 수 없으며, 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없는 일사부재리의 효력도 발생한다.[93] 결국 특허심판은 상급기관이 지휘감독권의 일환으로 그 취소 변경을 지시 명령할 수 있는 일반적인 행정처분과는 그 성격이 다르다고 볼 수 있다.[94]

2) 사법행위와 차이점

일반적인 사법행위는 법관에 의하여 행하여지고, 직무의 독립성과 법관의 자격요건이나 신분보장 등은 헌법을 통하여 보장받는다. 하지만 특허심판은 이러한 일반적인 사법행위와 상이한 점이 많다. 특허심판은 사법기관이 아닌 특허청에서 행해지고 그 직무의 독립성과 심판관의 자격요건이나 신분보장 등이 헌법에서 보장하는 재판의 독립성이나 법관의 자격요건·신분보장 등과는 비교될 수 없으므로, 일반행정 공무원인 특허청 심판관에 의한 특허심판을 법관에 의한 재판과 완전히 동일하게 보기는 어렵다고 하겠다.[95]

또한 특허심판제도가 민사소송 절차를 많이 준용하고 있기는 하지만, 특허권의 특수성과 공익성에 따르는 독특한 절차를 채용하고 있다는 점에서, 민사소송이나 통상의 행정소송과 구별되는 특별한 행정쟁송절차로서 대법원의 최종심을 전제로 하여 특허청 심판관의 합의체에 의

90) 하홍준, 심결취소소송 관련 특허심판원과 특허법원간의 업무협력방안 연구 -심리범위를 중심으로-, 한국발명진흥회(지식재산권연구센터 2001), 18면; 천효남, 전게서, 767면: 송영식·이상정·황종환, 전게서, 616면.

91) 특히 행점심판의 존재이유에 대하여는 김철용, 행정법 I, 박영사 (2006), 516 이하를 참조할 것.

92) 김정자, 전게논문, 5면.

93) 권택수, 일사부재리의 원칙, 특허소송연구(특허법원, 1999), 147면.

94) 특허청 특허심판원, 특허심판실무개요, (2001, 9면; 전문성, 전게논문, 9면.

95) 전문성, 전게논문, 9면.

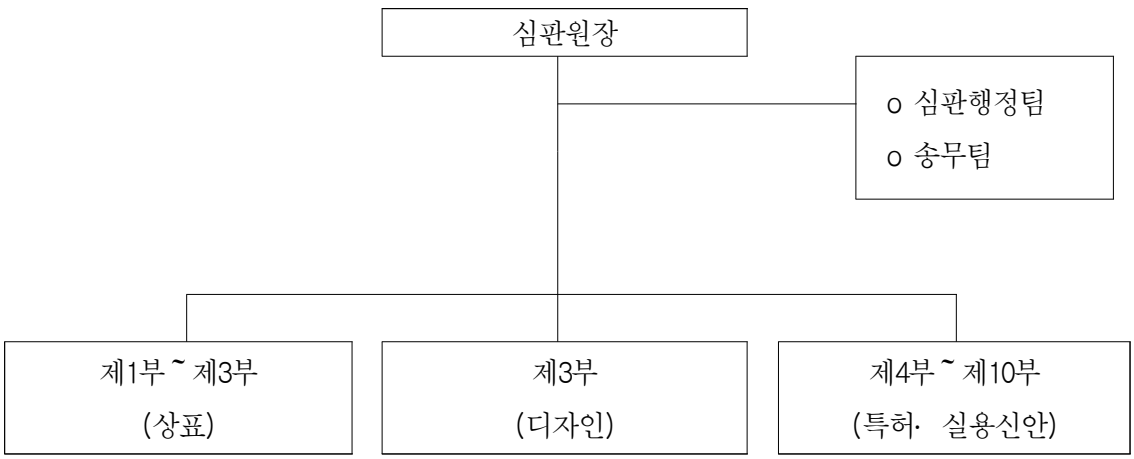
하여 행하여지는 행정심판은 행정행위와 사법행위의 중간영역에 위치하는 준사법적 행정행위라고 보는 것이 통설적 견해이다.[96] 결국 특허심판이라 함은 특허에 관한 분쟁의 해결을 목적으로 하는 쟁송으로서 행정청인 특허청의 특허출원에 대한 심사관의 부당한 거절사정의 취소 또는 무효사유를 안고 있는 특허청의 소멸에 대하여 행하여지는 행정처분의 성격을 가지나 그 실질은 준사법적 행위의 성질을 갖는 것이다.

2. 우리나라 심판원의 조직, 구성 및 심판관의 자격요건

1) 특허심판원의 조직

특허법은 특허·실용신안·디자인 및 상표에 관한 심판과 재심 및 이에 관한 조사·연구에 관한 사무를 관장하게 하기 위하여 특허청장 소속 하에 특허심판원을 설치하도록 하고 있다(특허법 제132조의 2). 특허심판원은 특허심판원장과 직접 심판업무를 담당하는 10개 심판부와 심판관련 행정사무를 담당하는 심판행정팀 및 소송업무를 담당하는 송무팀으로 구성되어 있으며, 특허심판원의 조직과 정원 및 운용에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정하도록 하고 있다.[97]

<우리나라 특허심판원조직도>



<특허심판원 심판부별 담당분야>

96) 황순효, 특허심판원의 조직과 운영의 효율에 관한 연구, 동국대학교대학원석사학위논문 (1998), 35~36면: 전문성, 전게논문, 9면; 김한상·김준학, 지식재산권법, 제일법규(2000), 298면.

97) 김정자, 우리나라 특허심판제도의 발전방안에 관한 연구, 한남대학교행정정책대학원석사학위논문(2004), 16면, 당시와 비교하여 심판행정실은 심판행정팀과 송무팀으로 나누어졌고, 13개의 심판부에서 10개의 심판부로 조정되었다.

구분		담당분야	
상표	제1부	상표·서비스표	화장품, 세제, 악기, 보험·부동산업, 요식업, 가구류
	제2부	상표·서비스표	피혁 및 그 제품, 의류, 신발, 모자, 음료, 귀금속, 보석류, 차류, 법률서비스업
	제3부	상표·서비스표	담배, 흡연용품, 통신·방송업, 고무, 보안서비스, 알콜음료
다자인	제3부	디자인	사무용품 및 판매용품, 운수·운반기계, 전기·전자 및 통신기계기구, 의복, 생활용품, 운동경기용품
특허 · 실용신안	제4부	기계·금속	냉동기계, 가열 및 연소장치, 건축, 토목기계
	제5부	기계·금속	기계요소, 일반 및 정밀기계, 금속
	제6부	화학·생명공학	농수산물, 유전공학, 의학조성물, 섬유, 식품가공, 의류
	제7부	화학·생명공학	유기화학, 고분자화학, 무기화학, 정밀화학, 도료, 생활용품, 세라믹, 고분자화합물, 무기화합물, 감광재료, 유기화합물, 치료위생
	제8부	전기·전자	엑정디스플레이, 반도체장치, 전자상거래, 정보저장장치
	제9부	전기·전자	전자상거래/컴퓨터, 반도체, 유선/무선전송시스템, 진단기기, 레이저 발생장치
	제10부	복합기술	화상통신, 송수신기, 교환국, 디지털정보의 전송, 디스플레이제어회로, 전자기량의 측정

특허심판원장은 특허심판원 운영에 관한 모든 사무를 총괄하고 소속공무원을 지휘·감독하며, 특히 중요하다고 인정되는 사건에 대하여는 스스로 그 사건의 심판장이 될 수 있다.[98]

심판업무는 심판행정팀과 송무팀으로 구분되어 업무를 실행하고 있다. 심판행정팀은 일반행정 업무와 심판지원 업무로 구분된다.[99] 전자는 관인·관인대장의 관수 및 보안, 특허심판원 소속공무원의 인사·복무 및 교육훈련, 문서의 분류·수발·통제·편찬·보존 및 증거물 등의 관리, 세입세출 예산의 편성 및 운영, 심판제도 및 법령의 운영을 다루고 있다. 반면에 후자는, 심판 및 특허소송 관련 통계작성 및 유지, 심판 관련 제증명 발급 및 민원상담, 심결문집 및 완결 심판 포대의 열람·복사제공 등의 제 업무를 담담한다.

한편 송무팀은 소송수행업무를 주로 한다. 수송수행자 지정·변경 관련 업무, 준비서면·답변서 작성 및 제출 등 소송수행업무, 특허청 패소사건에 대한 심판관 지정업무, 소송결과에 따른 소

98) 송영식·이상정·황종환, 지적소유권법(상), 513면.

99) 더 구체적인 사항은 특허심판원 홈페이지(http://www.kipo.go.kr/ipt/) 참조.

송비용의 지급 및 회수 관련 업무, 소송에 관한 검찰청·행정법무담당관실에의 보고 및 통보업무 등을 한다.

2) 특허심판원의 구성

2006년 6월을 기준으로 심판부의 구성현황을 살펴보면 10개의 상설심판부가 구성되어 있는데 제1·2·3부는 행정, 제4·5부는 기계, 제6·7부는 화학, 제8·9부는 전기, 제10부는 복합기술 분야로 구분되어 있으며, 또한 각 심판부마다 1명씩 총 10명의 심판장이 있고 67명의 심판관이 부분별로 배치되어 있는데 특히 수석 심판장 및 수석 심판관이 지정되어 있는 바 4명의 수석 심판장과 8명의 수석 심판관을 두고 있다. 보다 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.[100]

<표-> 심판부의 구성 현황

구분		심판장	심판관
행정	제1부	수석 심판장 1명	심판관 6명 (수석 심판관 1명 포함)
	제2부	심판장 1명	심판관 6명 (수석 심판관 1명 포함)
	제3부	심판장 1명	심판관 5명 (수석 심판관 1명 포함)
기계	제4부	심판장 1명	심판관 6명 (수석 심판관 1명 포함)
	제5부	수석 심판장 1명	심판관 6명
화학	제6부	수석 심판장 1명	심판관 7명 (수석 심판관 1명 포함)
	제7부	심판장 1명	심판관 6명
전기	제8부	수석 심판장 1명	심판관 9명 (수석 심판관 1명 포함)
	제9부	심판장 1명	심판관 8명 (수석 심판관 1명 포함)
복합기술	제10부	심판장 1명	심판관 8명 (수석 심판관 1명 포함)

3) 심판관 등의 자격요건

한편 현행 특허법 시행령 제8조에서는 심판관 등의 자격 기준에 대하여 규정하고 있는바 구

100) 상설심판부 구성 및 수석심판장·관 지정 현황, 특허심판원 홈페이지(http://www.kipo.go.kr/ipt/) 참조. 다만, 구체적인 인원 현황은 계속적으로 변동이 있다.

체적으로는 다음과 같다.

▢ 심판관이 될 수 있는 자

○ 특허청 또는 그 소속기관의 4급 이상의 일반직국가공무원 중

① 특허청에서 2년 이상 심사관으로 재직한 자,

② 산업행정 또는 과학기술에 관한 사무(연구를 포함한다)에 10년 이상 종사한 자로서 그 중 3년 이상 특허청 또는 그 소속기관에서 심사 또는 심판사무에 종사한 자,

③ 특허청에서 심사관으로 재직한 기간과 5급 이상의 일반직국가공무원으로서 특허심판원에서 심판업무에 직접 종사한 기간 및 특허법원에서 기술심리관으로 재직한 기간을 통산하여 2년 이상인 자 중 하나에 해당하는 자로서

○ 국제지식재산연수원에서 소정의 심판관 연수과정을 수료한 자

▢ 심판장이 될 수 있는 자

○ 특허청 또는 그 소속기관의 3급 이상의 일반직국가공무원으로서

① 특허심판원에서 2년 이상 심판관으로 재직한 자,

② 산업행정 또는 과학기술에 관한 사무(연구를 포함한다)에 15년 이상 종사한 자로서 그 중 3년 이상 특허청 또는 그 소속기관에서 심사 또는 심판사무에 종사하고 심판관 연수과정을 수료한 자 중 하나에 해당하는 자

○ 다만, 「국가공무원법」 제28조의4 제1항의 규정에 의하여 개방형직위로 지정된 심판장이 될 수 있는 자[101]는 동조 제2항의 규정에 의한 직무수행요건을 갖춘 자 또는 ① 특허심판원에서 2년 이상 심판관으로 재직한 자, 또는 ② 산업행정 또는 과학기술에 관한 사무(연구를 포함한다)에 15년 이상 종사한 자로서 그중 3년 이상 특허청 또는 그 소속기관에서 심사 또는 심판사무에 종사하고 심판관 연수과정을 수료한 자 중 하나에 해당하는 자

---

101) 2006년 5월 29일 특허청은 개방형 직위로 지정된 심판장을 모집한 바 있는데, 동 모집에서의 응시자격요건은 다음과 같다.
국가공무원법 제33조(결격사유) 각호의 1에 해당하지 않는 자로서 다음 응시자격요건 중 기준구분에 관계없이 최소한 하나를 갖춘 경우 응시할 수 있음.
○ 자격증 기준 : 공무원/민간 경력 10년 이상인 자로서 변호사, 변리사 자격증 소지 후 관련분야 경력 5년 이상인 자
○ 경력기준(공무원) : 관련분야에서 3년 이상 근무한 자로서 3급 또는 이에 상당하는 직급 이상인 자 또는 관련분야에서 5년 이상 근무한 자로서 4급 과장급 직위에 2년 이상 근무한 자
○ 법령기준 : 특허법 제143조, 제145조 및 동법 시행령 제8조의 자격요건에 해당하는 자

▢ 특허심판원장이 될 수 있는 자

○ 심판관의 자격이 있는 자

▢ 심사관・심판관・심판장 또는 특허심판원장의 자격의 직급에 해당하는 공무원으로서 변리사의 자격이 있는 자는 위와 같은 규정에도 불구하고 심사관・심판관・심판장 또는 특허심판원장이 될 수 있다.

3. 주요국의 특허심판제도

1) 미국

(1) 특허심판

미국에서의 특허쟁송은 특허재심사, 거절사정불복심판, 특허무효다툼, 특허침해소송 등으로 나눌 수 있다. 미국에서는 특허청에서 허여된 특허권 등 산업재산권에 대하여 심사를 담당하고 있는 심사관은 물론이고 일반인은 누구나 선행기술을 인용하면서 재심사와 심판을 청구할 수 있다.

재심사청구는 새로이 발견된 선행기술에 의거하여 특허청의 재심사를 청구하거나, 오래 끌고 비싼 소송에 대신하여 간편하게 특허의 유효성 여부를 판정하기 위한 것이다.[102] 재심사의 청구가 있을 경우에는 특허청장이 재심사 여부를 결정하여야 한다.[103] 재심사하기로 결정되면 경우에는 해당 권리의 등록자는 각 청구범위의 특징 그리고 청구범위와 인용하는 선행기술과의 관련성 등을 심사를 담당한 심사관에게 이를 해소할 수 있는 진술서를 제출한다.

재심사절차에서 최종 결정된 사항에 대하여는 항소심판 및 저촉심판부(Board of Appeals and Interferences)에 특허심판을 청구할 수 있다.[104] 즉 항고 및 저촉심판부(BPAI)의 심판기능으로서 심사관의 거절사정에 대하여는 특허청장 또는 특허청 항고심판부에 심판을 청구할 수 있고,[105] 특허권 상호간의 저촉여부에 대하여는 특허청 저촉심한부에 저촉심판을 할 수 있

---

102) 이해영, 미국특허법, 한빛지적소유권센터(2005), 473면, 특허권자는 특허권의 유무효성을 둘러싼 분쟁을 보다 신속히 적은 비용으로 종결지을 수 있을 뿐만 아니라 권리행사의 준비단계에서 미리 특허권의 하자를 치유할 수 있게 된다. 한국 특허법의 특허무효심판에 해당하는 기능이라고 볼 수 있다.

103) 35 U.S.C. § 303.

104) 35 U.S.C. § 306.

105) 35 U.S.C. § 134, 영미법 전통에 따라 별도 행정소송제도를 인정하지 않고 거절사정에 대해 특허청장을 상대로 지방법원에서 민사소송으로 거절취지를 구할 수 있는 길이 있으나, 20세기 이후 각종 행정위원회제도의 활성화에 따라 특허에 대한 특별행정쟁송절차를 폭 넓게 인정하고 있다. 특허청 심사관의 특허거절사정 등에 대하여는 특허청 항고심판부 등이 1차적인 특허심판기능을 담당한다.

다.[106]

불복수단으로서 특허청 항고 및 저촉심판부(BPAI)의 심결에 대하여는 연방순회항소법원(CAFC)에 항소할 수 있으나,[107] 단지 새로운 증거제출에 의한 사실 다툼이 있는 경우에는 제1심인 컬럼비아연방지방법원에 제소할 수 있고,[108] 그 판결에 불복하는 자는 연방순회항소법원에 항소할 수 있다.[109]

(2) 심판원의 조직

미국의 특허심판원(Board of Appeals and Interference; BPAI)은 미국 특허법에 근거하여 조직과 기능이 규정되고, 청장, 특허담당차장, 상표담당차장과 62명의 행정특허판사(Administrative Patent Judge)로 구성되며, 특허판사 중 1인은 수석판사(Chief Administrativ Patent Judge)로서 심판원장 역할을 하고, 다른 1인은 부수석판사(Vice chief Administrative patent Judge)로서 부원장 역할을 하며, 특허판사는 법적 지식과 과학적 지식을 겸비한 자로서 특허청장이 임명한다.[110]

각 심판부는 최소 3인의 심판원 멤버로 구성되며 청장이 지정하고, 현실적으로는 심판원장이 권한을 위임받아 지정한다. 심판원의 특허판사는 수석판사, 부수석판사 아래에 기계부(7), 전기부(14), 화학부(14), 생물부(7), 저촉부(10), 저촉부소송반(8)으로 구성되며, 특허판사의 업무시간의 약 75%는 거절불복심판에, 약 25%는 선원저촉심판에 소요된다. 심판관으로 일하기 위해서는 특허청에서 선임심사관(Primary Examination)급 이상으로 2년 이상 재직한 자로 특허변호사(Patent Attorney) 자격이 있어야 한다.[111]

2) 독일

(1) 심판제도

독일의 특허심판은 독일 특허청 내에 설치되어 있는 특허관리국(Patent Abteilung)이 이를 관장한다.[112] 독일은 심사주의와 특허부여 후의 이의신청제도를 두고 있다.[113] 특히 이의신청

---

106) 35 U.S.C. § 135.

107) 35 U.S.C. § 141.

108) 35 U.S.C. § 145.

109) 35 U.S.C. § 1295, 1982년 설립된 CAFC는 일정한 사건에 있어서 지역과 무관하게 연방전체의 관할권을 갖는 연방고등법원인 바, 특허사건에 있어서 지방법원 판결에 대한 항소심에 대하여 전속 관할권을 가진다.

110) 김정자, 전게논문, 27면.

111) 성낙인·이상정·하홍준, 특허심판원의 운영방향에 관한 연구, 한국발명진흥회 (지식재산권연구센터 1997), 40년.

에 대한 결정 등 1차적인 심판기능은 특허청 내의 특허관리국이 담당하고 있다.

독일의 심판부는 3인 이상의 심판관으로 구성되며, 이의신청에 대한 결정은 반드시 기술직 심판관 2인 이상이 포함되어야 하며, 또한 법률직 사항에 대한 결정은 반드시 법률직 심판관 1인 이상이 포함되어야 한다.[114] 특허사정에 따라 허여된 특허를 이의결정에 의하여 취소하는 심판인 특허취소[115]와 특허권자도 허여된 특허에 대하여 일정한 범위 내의 정정을 청구할 수 있는바, 정정사항에 관한 심판인 특허정정에 관련된 사항에 관한 결정 등을 한다.[116] 이러한 특허관리국의 결정에 대하여는 연방특허법원에 불복 항고할 수 있다.[117]

(2) 심판관의 자격

대학졸업자가 국가시험합격 후 5년 이상의 기술 분야 실무 경력자는 심사관 자격이 있다. 특허법원 기술판사는 이공계 대학졸업 국가시험 합격 후 5년 이상 기술분야 실무경력자로 한다. 전적으로 특허청 심사관 경력자로 선발한다.

3) 유럽특허청 (EPO)

(1) 심판제도

EPC의 규정에 따라 설립된 유럽특허기구는 EPO와 행정이사회로 구성되어 있다. EPC 제4조 3항에 따르면 유럽특허기구의 임무는 유럽특허권의 허여업무를 관리하는 것이며 유럽특허출원의 심사 및 특허허여 업무는 행정이사회의 감독 하에 EPO에서 담당하도록 되어 있다.[118]

심판소는 EPO 내 5개의 국(Directorates-General, DG) 가운데 하나로써 5개국이 담당하는 업무는 각각 다음과 같다. 조사문서부(DG 1), 심사 및 이의결정부(DG 2), 심판·항고부(DG 3), 관리부(DG 4), 법률 및 국제업무부(DG 5)로 구성되어 있다.

심판부는 기술분야와 법률분야 심판관의 합의체로 구성되는데 사건의 내용에 따라 이들의

---

112) 독일 특허법 제27조 참조.

113) 심사청구된 특허출원에 대하여만 심사부의 실체심사를 거쳐 특허를 부여하는 심사주의를 채택하고 있다. 하지만 실용신안등록출원에 대하여는 방식검사만을 행하는 무심사주의를 채택하고 있다(1987년. 7월 1일 개정). 한편 실체심사후 허여된 특허에 대하여는 누구라도 특허등록공고일로부터 3월 이내에 이의신청을 통하여 취소할 수 있도록 하고 있다.

114) 독일 특허법 제27조 제3항 참조.

115) 독일 특허법 제59조, 제61조, 제21조.

116) 독일 특허법 제27조 제1항.

117) 독일 특허법 제73조 제1항.

118) 제럴드 페트슨 (양영환 저), 유럽특허법 및 실무, 대한변리사회(2004), 93면.

구성비가 달라진다. 심판의 종류에는 특허출원 등에 대한 거절결정불복심판, 이의결정불복심판, 기타 EPC규정에 따른 제반 절차의 위반에 대한 처분불복심판이 있다. DG3의 경우 국장이 국장직과 기술심판부의 법률분야 심판관을 겸임하며 기술적인 문제가 아니고 법률적인 문제에 대한 판단이 요구되는 사건인 경우에는 심판장을 맡기도 한다. 심사부 또는 이의조사부의 거절사정이나 접수과의 결정에 불복하는 경우 항고부에 심판을 청구할 수 있다. 특히 EPO 항고부(DG 3)의 조직구조는 항고부의 행정, 문서 및 전산 지원업무를 수행하는 법률연구 및 행정부, 기술항고부 및 법률항고부의 공통사항에 대한 심리를 담당하는 확대항고부, 기계부 8, 화학부 7, 물리부 3, 전기부 2 등 20 개 항고부인 기술항고부, 그리고 절차 무효 및 불수리 처분에 대한 불복 등 EPC 법령의 법률문제 등에 대한 심판을 수행하는 법률항고부와 변리사의 자격요건, 징계문제를 다루는 징계항고부로 구성되어 있다.[119] 확대항고부는 EPC 규정의 통일적 적용보장 및 중요한 법률문제 결정 등을 위한 EPO내의 최고의 사법기구이다. 항고심판부에 의해 위탁된 법률문제 또는 2 이상의 항고심판부가 서로 다른 결정을 내린 경우에 이를 조정키 위해 특허청장이 위탁한 법률문제 등에 관한 심리는 확대항고부가 관할한다. 항고부의 심리를 속행하는 법정이 아니고, 항고부에 계류된 사건에 대한 법률해석을 하는데 그치고, 원결정에 대한 최종판단을 항고부 소관이며, 확대항고부의 합의체는 법률심판관 5인과 기술심판관 2인으로 구성된다. 항고심판부는 준사법기관으로 인정받고 있고, 이 심판부의 결정에 대한 상소는 불가능하다. 심판관의 임기는 5년이고, 재임 기간 중 중대한 이유가 없는 한 면직되지 않는다.

(2) 심판관의 자격

심판관 자격은 명문으로 규정되어 있지 않지만 유럽특허조약(EPC)의 회원국 대표로 구성된 행정이사회에서 임명하고, 기술심판관은 주로 EPO 심사관 중에서 심사과장 또는 회원국 특허법원 판사, 변리사 등을 승진 또는 심사과장 중에서 전보한다.[120] 외부(각국 특허법원 판사, 변리사)에서도 충원한다. 그리고 법률 심판관은 외부(판사, 변호사)충원을 위주로 한다.

심판관에 대한 평가는 매 5년마다 유럽특허청 간부 및 심판관들로 구성된 회의에서 이루어지는데 평가의 가장 중요한 기준은 심판관의 경력과 전문성이다. 우리나라 심판관 평가의 경우에는 상급심심결의 취소실적도 포함하고 있으나 유럽심판원에서는 상급심이 없으므로 이에 대한 평가가 없다. 한편 심판관평가를 통하여 재임용되지 못할 경우 심판관의 자격이 상실되며, 반대로 심판관 평가에서 전문성과 경력을 인정받으면 그만큼 임금 등 대우가 개선된다.[121] 심판관이 처리하는 업무는 주로 사건의 심리를 위한 것이고 심리이외의 기타 행정업무로는 심사관 임용 시 인터뷰 등 극히 예외적인 경우뿐이다.

---

119) 김정자, 전게논문, 38면.

120) 특허심판원, 유럽특허청 세미나 참석결과 보고 -유럽특허청의 심판절차-, (2002), 305면,

121) 전문성, 전게논문, 43면.

4) 일본

(1) 심판제도

일본 특허청 심판소의 특허심판은 우리나라와 유사하게, 사정계심판으로서 특허청 심사관의 거절사정에 대한 불복심판, 정정심판과, 당사자계 심판으로서 등록된 특허의 무효심판 및 정정무효심판을 담당한다. 심판부는 심판관 3인에서 5인의 합의체로 구성하여 심리하며, 합의체에서는 과반수로 결정하도록 규정하고 있다.[122] 거절사정불복심판에 있어서 조기심리제 도입하여 운용하고 있다.[123] 한편 1959년 특허법 개정을 통하여 권리범위확인심판을 폐지하면서 도입한 판정제도는 특허청의 심판관 3인이 행하는 일종의 감정제도라고 볼 수 있다. 판정은 특허청이 행하는 감정이며 법적 구속력이 없고 따라서 판정에 대하여 불복을 신청할 수도 없고, 법원에서 판정과 다른 판단을 하는 것도 자유이다.[124]

(2) 심판관의 자격

일본에서 심판관은 전문행정직으로 분류되어 복직, 봉급기준 등에 있어서 일반 행정직과 구분함으로서 전문성을 강화하고 있다.

□ 심판관의 자격요건은 특허법 시행령 제13조에 규정되어 있다. 심판관은 일반행정직 6급 이상 또는 전문행정직 3급(고참심사관) 이상의 자로 다음의 1에 해당하는 자로 한다.

1. 10년 이상 심사관으로 재직한 자

2. 산업행정 등의 사무에 통산하여 10년 이상 종사한 자로서 3년 이상 특허청 심사사무에 종사한 자

3. 산업행정 등의 사무에 12년 이상 종사한 자로서 전 2호에 규정한 자와 동등이사의 학식·경험을 가졌다고 인정되는 자

□ 전문가의 채용

의장담당심판장은 디자인 전공자로 한다.

□ 전보의 제한

심사·심판 부서에서는 지원 부서로 옮길 수 있으나 지원 부서에서 심사·심판부서로 옮기기 위해서는 전직시험을 봐야 한다.

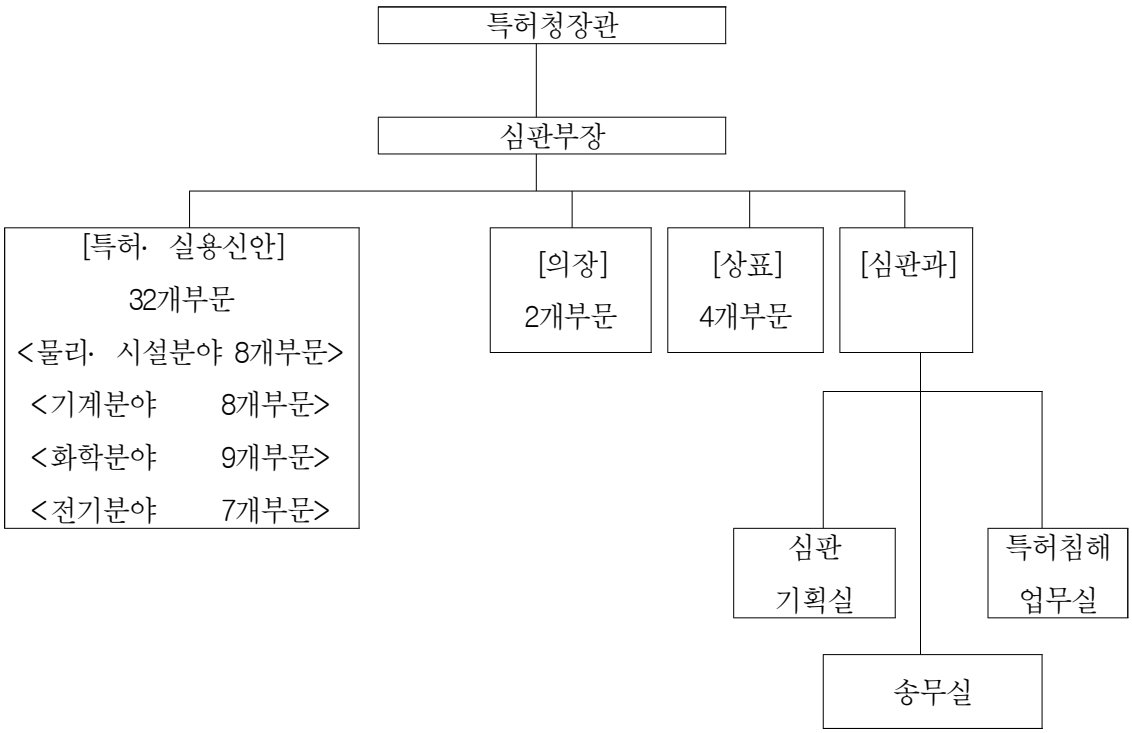
---

122) 전문성, 전게논문, 47면.

123) 일본의 조기심리제도는 조기심리대상 심판, 당사자계 심판, 이의신청관련 심판, 사정계 심판 순으로 처리한다.

124) 송영식·이상정·황종환, 전게서, 639면.

<일본 특허청 심판부>



심판부 인원은 심판부장 1명, 심판장 100명, 심판관 290명, 특허청 퇴직자로 심판관을 보조하는 심판조사원 48명으로 총 440여명이며, 심판지원인력은 심판기획실내에 제도·법령업무를 위해 심판관 7명과 심판행정업무 및 결정계 담당 74명, 무효심판사건 구술심리 등을 위한 특허침해업무실 8명, 그리고 송무실 8명으로 총 100명 이상이다.[125)]

심판부의 합의체 각 부문은 부문장(선임심판장 겸임) 1인, 심판장 2-4인, 심판관 5-13인으로 구성되며, 합의체는 과반수 찬성으로 결정한다. 심판관은 심사경력 10년 이상인 자를 특허청장이 임명하며 일단 임명한 후에는 임명권자라 하더라도 법률상 심판의 직무상 독립성을 보장하고 있다. 심판부는 심판관 3-5인의 합의부로 구성하여 심리하며, 합의체에서는 과반수로 결정하도록 규정하고 있다.

4. 개선방안

현재 특허심판원은 10개의 심판부와 심판행정팀과 송무팀인 2개의 팀으로 구성되어 있다. 특히 심판행정팀은 일반행정업무와 심판지원업무로 구분하여 다각적인 지원을 하고 있는 점은

125) 김정자, 전게논문, 41면 참조.

인정된다. 하지만 특허쟁송제도에 대하여 장·단기 발전계획 등 정책의 수립과 특허심판과 관련한 법제의 정비에 대하여 연구인력이 부족하다는 점이 문제이다. 앞으로 조직 개편이 있을 경우에 개선해야 할 것으로 사료된다.

특허법 시행령에서 특허심판원장의 자격을 심판관에 한하도록 한 것을 특허심판원의 전문성 강화 및 독립성 보장을 위해서 적합하다고 판단되며, 더 나아가 심판관의 자격을 심사관으로 2년 이상 재직한 자에서, 1년 정도를 더 늘려 심판관의 전문성을 좀 더 강화할 필요가 있다고 사료된다. 이러한 심판관의 전문성 강화를 통해 심판의 적정성, 신속성 제고 및 특허심판원 심결의 신뢰도 제고로 불복항소를 최소화하게 될 것이다.

마찬가지로 심사관의 경력에 대해서도 실체실무심사경력자로 한정할 필요가 있다. 이는 현재의 인사가 실체실무심사경력이 없는 자가 심판을 담당하면서 발생할 수 있는 업무 무경험의 현상을 방지할 필요가 있기 때문이다.

심판에 있어서 법률 분야의 전문성을 강화시켜야 할 것이다. 예를 들어 미국의 심판관은 변호사 자격 소지자를 요하고 있고,[126] EPO의 법률심판관의 경우에도 그러하다. 즉, 법률분야 전문가를 심판관으로 채용하여 기술 분야 외에도 법률 분야의 전문성을 강화하여 법원과의 결론 등에 있어 조화를 모색하는 것이 바람직할 것으로 본다. 이는 아래에서 다루게 되는 심결의 정확성 제고에도 도움이 될 것으로 판단된다.

126) 다만, 로스쿨제도를 통해 엄청나게 많은 변호사가 활동하고 있는 영미계 국가의 제도를 그대로 들여오는 것은 우리의 실정에 맞지 않고 바람직하지도 않다는 점은 명백하다.

III. 특허심판의 전문성 강화방안

특허청은 2006년 5월 1일 중앙행정기관 가운데 최초로 기업형 중앙책임운영기관으로 자리매김을 하고 이에 따라 동년 동월 3일에는 고객감동경영을 선포한 바 있는데, 이는 특허심판원에도 동일하게 적용되는 것이고 이러한 관점에서 바라본 심판관련 현황을 검토하고, 개선해야 할 점이 무엇인가를 살펴보고자 한다.

1. 우리나라의 현황

1) 심판청구 및 심판처리 현황

특허심판원 개원 이후 2004년까지의 심판청구 및 심판처리 현황을 살펴보면 청구 및 처리건수는 꾸준히 증가되어 왔음을 알 수 있다.[127] 그러나 청구건수에 대하여 처리건수가 미치지 못하고 있어 적체가 되고 있는 실정이다.

<표-> 연도별 심판청구 및 처리현황

구분	청구건수					처리건수					미처리건수
	특허	실용	디자인	상표	계	특허	실용	디자인	상표	계	
1998. 3-12	2,029	635	494	2,391	5,549	2,000 (972)	933 (225)	970 (33)	2,881	6,784 (1,230)	
1999	3,298	783	629	2,703	7,413	2,481 (1,438)	729 (183)	696 (49)	3,373	7,279 (1,670)	3,925
2000	1,994	591	508	2,787	5,880	2,413 (1,103)	550 (71)	535 (53)	2,896	6,394 (1,227)	3,411
2001	3,004	904	529	3,048	7,485	2,415 (1,190)	608 (88)	548 (72)	2,942	6,513 (1,350)	4,383
2002	3,376	887	560	3,675	8,498	3,022 (1,732)	766 (80)	458 (61)	3,168	7,414 (1,873)	5,467
2003	3,821	788	604	3,936	9,149	2,836 (1,570)	728 (13)	576 (43)	3,718	7,858 (1,626)	6,758
2004	4,798	827	572	4,582	10,779	4,051 (1,759)	876 (8)	599 (66)	4,206	9,732 (1,833)	7,805
계	22,320	5,415	3,896	23,122	54,753	19,218 (9,764)	5,190 (668)	4,382 (377)	23,184	51,974 (10,809)	

127) 심판 청구건수를 통해서 청구건수의 증감 추이를 통해 심판서비스에 대한 고객들의 수요 증감을 판단할 수 있다. 심판 처리건수는 심판서비스 수요(청구된 심판건수)에 심판원이 양적인 측면에서 충분한 심판서비스 공급(심판 처리건수)을 했는지, 그리고 심판원의 현 조직 및 인력 등이 심판서비스 제공에 충분한 것인지 여부를 판단할 수 있다.

주: 1. 1998. 3. 1. 특허법원의 설립으로 심판소와 항고심판소가 특허심판원으로 일원화됨
2. ( ) 안은 심사전치 등록결정건수임
3. 디자인·상표는 복수디자인·다류상표 기준임

아울러 2005년도 심판청구, 심판처리·미처리 현황을 살펴보면 다음과 같다.

<표-> 2005년도 심판청구 현황

구분		특허	실용	디자인	상표	합계
누계	당사자계	775	479	331	2,067	3,652
	결정계	6,366	307	153	3,803	10,629
	합계	7,141	786	484	5,870	14,281

주: 복수디자인·다류상표 제도에 따라 류기준으로 산정한 수치임.

<표-> 2005년도 심판처리 현황

구분		특허	실용	디자인	상표	합계
누계	당사자계	564	453	234	1,280	2,531
	결정계	4,170	218	100	1,992	6,480
	합계	4,734	671	334	3,272	9,011

주: 복수디자인·다류상표 제도에 따라 류기준으로 산정하고 전치등록결정건을 포함한 수치임.

<표-> 2005년도 심판미처리 현황

구분		특허	실용	디자인	상표	합계
누계	당사자계	607	314	183	1,253	2,357
	결정계	4,077	279	60	2,181	6,597
	합계	4,684	593	243	3,434	8,954

주: 복수디자인·다류상표 제도에 따라 류기준으로 산정한 수치임.

이에 따르면 2004년도 심판 청구건수는 10,779건이었는데 2005년도는 14,281건으로 급격

하게 증가하였고 특히, 특허 분야의 심판 청구건수는 4,798건에서 7,141건으로 대폭 증가하였다. 아울러 심판 처리건수는 2004년도의 9,732건에서 2005년 9,011건으로 오히려 감소한 것으로 나타났고 미처리건수도 지속적으로 증가하고 있어 이에 대한 원인분석과 대책이 필요할 것으로 생각된다.

2) 심판 처리기간

심판 처리기간을 검토해보면 2004년 말을 기준으로 특허・실용신안 12.0개월, 상표・디자인 5.4개월을 보이고 있으며 특히, 특허 및 실용신안의 경우 2003년 대비 14.3%가 단축되었다.[128] 한편 2005년도의 심판처리기간은 특허・실용신안 분야는 9.6개월로 단축된 반면, 상표・디자인의 경우는 5.8개월로 다소 늘어났다.

심사처리기간의 평균치는 2004년에는 8.2개월이었으나 2005년에는 7.8개월로 다소 감소하고 있는 추세이다. 한편 2006년에는 당사자계 6개월, 결정계 9개월, 그리고 평균 5.8개월을 예상하고 있다.

<표-> 연도별 심판처리기간 현황

연 도	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
특허・실용	15.1	7.4	8.1	10.0	9.6	11.1	14.0	12.0	9.6
상표・디자인	12.9	7.9	5.1	5.0	5.3	5.7	5.6	5.4	5.8
계	13.5	7.8	6.0	7.1	6.8	7.8	8.7	8.2	7.8

※ 처리기간산정은 심사전치 및 보정기간은 제외 / 처리기간(개월)

3) 특허법원에의 소제기 및 판결현황

특허법원 개원(1998년 3월 1일)이후 특허심판원의 심결에 대하여 소를 제기한 건수는 연평균 809건으로 소제기율이 연평균 22.7%에 이르고 있으며, 2004년의 경우는 소제기율이 19.1%로 연평균에 비해 다소 감소한 것으로 나타났다.[129]

---

128) 심판 처리기간은 심판원이 고객들에게 제공해야 하는 심판서비스 가운데 신속한 심판이라는 요청에 부응했는지 판단 가능하다. 특허법원에의 불복건수는 심판원의 심결에 대한 고객들의 불복의사를 판단할 수 있다.

129) 한편 특허법원의 판결에 대한 대법원에의 상고 및 선고 현황은 다음과 같다.

<표-> 대법원 상고제기 및 선고현황

한편 특허심판원의 심결에 대해 특허법원에서 취소한 비율(심결취소율)은 2004년 25.6%로 2002년 30.4%, 2003년 27.4%에 비하여 계속 감소 추세를 보이고 있다.[130]

<표-> 특허법원에의 소제기 및 판결현황

구 분	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
심판원심결	7,820	7,279	6,079	5,995	6,890	7,120	8,875	
소제기 가능 심결	3,559	3,823	3,204	3,069	3,293	3,605	4,580	5,754
소 제 기	685	995	797	726	840	747	873	1,085
제소율(%)	19.2	26.0	24.9	23.7	25.5	20.7	19.1	18.9
판결건수	662	911	791	796	776	752	857	938
취소판결	176	235	188	217	236	206	219	246
취소율(%)	26.6	25.8	23.8	27.3	30.4	27.4	25.6	26.2

2. 일본의 현황

일본 특허청 심판부는 신속한 심리의 실현, 심리내용의 충실, 분쟁해결능력의 강화라는 3대 과제를 실천하기 위하여 다음과 같은 시책을 시행하고 있다.

신속한 심리의 실현을 위하여 조기심리제도와 심판조사원 제도를 도입하였다. 일반적으로 침해소송과 관련하여 청구되는 무효심판은 특히 신속한 처리가 필요하기 때문에 우선적으로 심리토록 하고, 특허 후 권리의 유효성을 다투는 이의신청에 대해서도 무효심판과 마찬가지로 우선적으로 심리토록 하고 있다.

반면에 거절사정불복심판에 대해서는 일정한 조건을 만족하는 경우에 한하여 우선적인 심리를 인정하고 있다. 한편 사정계 심판사건에 있어서, 전직 심판장 또는 심사장을 역임한 퇴직

구분		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
특허법원 판결		662	911	791	796	776	752	857	
상고	건수	311	316	393	355	308	300	363	
	상고율(%)	47.0	34.7	50.0	44.6	39.7	39.9	42.4	
대법원 선고		283	241	365	461	368	283	383	
파기	건수	35	24	27	66	61	32	41	
	파기율(%)	12.4	10.0	7.4	14.3	16.6	11.3	10.7	

130) 특허법원의 판결현황의 분석을 통하여 특허법원의 인용판결(심결취소판결)은 기존의 심결을 뒤집는 것으로 심판서비스 가운데 심판의 정확성 지표로 활용이 가능하다.

공무원을 비상근 직원으로 채용하여 기술내용 파악 및 논점정리를 시킨 후, 담당심판관에게 제출토록 함으로서 심리에 대한 부담을 경감시키고 있으며, 심판조사원이 담당할 사건은 부문장이 결정한다.

심판청구의 적정화를 위하여 재판소의 판례동향을 심사하고 심판업무에 Feedback하여 상호 일관된 입장을 견지함으로써 심판청구의 건수를 줄이는 노력을 기울이고 있다. 심결취소된 것에 대해서는 수석심판장을 중심으로 당해 심판관, 담당 부문장을 중심으로 5-6명이 참가하는 판결 보고회를 개최하여 당해 심판관은 사건에 대한 내용을 설명한 후 상호 심층검토 및 분석을 하고 상고여부도 결정한다. 또한 취소판결의 경우에 상고결정에 대해서는 내부적으로 송무실장 판단 후 수석심판장에고 보고하고, 관련 부문장과 상의하며 심판부장에게 보고한 후 특허청장의 결재방식을 취하게 된다.

한편 장기 미처리사건에 대해서는 사건별로 리스트해서 당해 부문장에게 전달해주어 당해 심판관에게 신속한 처리를 유도하는 “Watch and Warning System"제도를 도입하고 있다.

다음으로 일본의 심판처리기간, 심판관 수, 심판청구건수 등 관련현황은 다음과 같다.

1) 심판처리기간

<표-> 결정계심판(거절사정불복심판 등)

(단위: 월)

	98	99	00	01	02	03	04
특허·실용	19	19	19	18	19	22	24
디자인	36	32	27	17	15	15	15
상표	29	24	19	20	24	27	26

<표-> 당사자계심판 (무효심판, 정정심판, 취소심판 등)

(단위: 월)

	98	99	00	01	02	03	04
특허·실용	12	12	12	12	10	10	8
디자인	14	10	11	11	11	9	7
상표	15	12	13	12	11	9	8

2) 심판관 인원

연도	98	99	00	01	02	03	04	05
심판관 (명)	383	389	391	393	395	396	392	389

3) 심판청구건수

(단위: 건)

	98	99	00	01	02	03	04
특허·실용	15,710	15,581	17,292	20,032	21,867	22,226	23,988
디자인·상표	7,143	7,151	6,459	6,119	5,827	5,691	5,321
계	22,853	22,732	23,751	26,151	27,694	27,917	29,309

3. 한국과 일본의 현황비교

<표-> 한국과 일본의 특허심판현황 종합비교

구분	한국	일본
기관명	특허심판원	심판부
심판조직	o 특허심판원장 o 심판장 10명 o 심판관 67명 o 심판연구관 4명 (총 81명)	o 심판부장 o 심판장 100명 o 심판관 290명 o 조사관 48명 - 조사원은 특허청(과장급)퇴직자로 구성 (총 440명)
상설심판부	10부	38부

<table>
<tr><td>지원조직</td><td colspan="5">o 심판행정팀
o 송무팀</td><td colspan="5">o 심판과 과장 1, 직원100
- 심판행정업무
-결정계 담당
- 심판기획실(실장1, 직원7)
- 특허침해업무실
- 송무실(실장, 직원7)
(총 100명 이상)
* 심판기획실에 심판관 7명 지원</td></tr>
<tr><td>심사관·심판관 비교</td><td colspan="5">1100 : 77 = 14.2 : 1
(06년 기준)</td><td colspan="5">1,325 : 390 - 3.4 : 1
(03년 기준)
* 05년 현재 심판관 수는 거의 같다.</td></tr>
<tr><td>심판청구건수</td><td colspan="5">12,751 (05년 기준)</td><td colspan="5">27,809 (02년 기준)
* 04년에는 29,309건이다</td></tr>
<tr><td>심판처리건수</td><td colspan="5">9,904</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>연간 1인당 처리건수</td><td colspan="5">o 특허·실용 : 98.6건
o 상표·의장 : 55.9건
(05년 기준)</td><td colspan="5">o 특허·실용 : 54건
o 상표·의장 : 162건
(02년 기준)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">심판관 구성
(정원기준)</td><td>권리</td><td>부</td><td>심판장</td><td>심판관</td><td>계</td><td>권리</td><td>부문</td><td>심판장</td><td>심판관</td><td>계</td></tr>
<tr><td>상표</td><td>3</td><td>3</td><td>11</td><td>17</td><td>상표</td><td>4</td><td>7</td><td>31</td><td>42</td></tr>
<tr><td>디자인
(상표)</td><td>1</td><td>1</td><td>6</td><td>8</td><td>의장</td><td>2</td><td>3</td><td>12</td><td>17</td></tr>
<tr><td>특·실</td><td>6</td><td>6</td><td>50</td><td>62</td><td>특·실</td><td>32</td><td>52</td><td>253</td><td>337</td></tr>
<tr><td>계</td><td>10</td><td>10</td><td>67</td><td>87</td><td>계</td><td>38</td><td>62</td><td>295</td><td>396</td></tr>
</table>

4. 개선방안

특허심판원은 설립당시 선진국 수준의 특허관련 심판제도를 갖추기 위하여 32개(특허 및 실용신안 19개, 의장 6개, 상표 7개)의 심판부를 구성하도록 최초로 검토되었다. 현재 심판행정팀과 송무팀 그리고 10개의 심판부로 구성되어 있는 실정이다.

현재 심판지원업무 가운데 심판제도 연구·개선, 법제연구, 판정분석과 심판편람의 연계, 심판관 연수교재 작성 등을 위하여 심판을 경험한 더 많은 인력이 필요하고, 특허심판제도에 대하여 장·단기 발전계획 등 정책의 수립과 특허심판과 관련한 법제의 정비, 심판처리의 효율화를 위한 더 많은 노력이 요구된다고 하겠다.

특허심판원에서 처리하고 있는 심판업무는 성격상 특허청 심사관의 판단에 대한 재심사의 기능을 가지고 있는 고도의 전문적이고 기술적인 업무로 이를 위하여 독립성 확보가 가장 중요한 과제라고 볼 수 있다. 특허청장의 지휘와 관계없이 인사와 예산의 독립성이 확보되어 심판의 공정성이 확보되어야 할 것이다.

특히 근무기간을 살펴보면, 특허심판원에서 심판업무를 수행하는 심판관 및 심판장의 60% 이상이 2년 미만으로 나타나고 있다. 잦은 인사교류로 인해 수반되는 인사이동은 심판관의 전문성에 커다란 장애가 된다는 것을 직시해야 한다. 전문성 제고를 위하여 각종 심판관 유인제도와 심사경력이 풍부한 심사관을 심판관으로 충원할 수 있는 제도적인 뒷받침이 있어야 할 것이다.

또한 특허청의 개청 당시와 2005년을 비교하면, 심판청구건수는 10.9배 증가하였으나 심판관수는 4.5배 증가를 보여 심판관이 절대적으로 부족한 것을 알 수 있다.

<심판관 수와 처리건수 대비표>

구 분	특허청 개청시 (1977년)	2005년	비율	비고
심판관 수	17명	77명	4.5배	
심판청구건수	1,166건	12,751	10.9배	
1인당 처리건수	62건	178	2.87배	

반면에 일본 특허청 심판관수는 390명으로서 우리나라 심판관수의 약 5배를 상회한다.

<우리나와 일본의 심판관 수와 비교표>

구 분	2006년 한국	일 본	비 고
심판관 수	77	390명(2003년 기준)	
심판청구건수	12,751,498	27,809(2002년 기준)	
1인당 처리건수(특허·실용신안)	104명	54건(2002년 기준)	
1인당 처리건수(상표·의장)	178	162(2002년 기준)	

상표·의장분야는 심판처리소요기간이 개원 당시 목표치에 근접하고 있으나 특허·실용분야는 심판원 발족 전에 비하여 개선되었으나 당초 목표에는 크게 미달되고, 최근 장기화되어 가고 있는 실정이다. 특히 산업재산권 분쟁의 신속한 해결의 필요라는 측면과, 특허나 실용신안 분야에서 심판의 신속, 전문성 강화, 신뢰도 제고를 위하여 다른 부문보다 우선적으로 인력이 충

원되어야 할 것이다. 특히 앞서 언급한 것처럼 심판에 있어서 법률 분야의 전문성을 강화시켜야 할 것이다. 즉, 법률분야 전문가를 심판관으로 채용하여 기술 분야 외에도 법률 분야의 전문성을 강화하여 법원과의 결론 등에 있어 조화를 모색하여 심결의 정확성 제고에도 도움이 될 것으로 판단된다.

IV. 특허침해소송의 관할권에 관한 문제

1. 논의 배경

산업재산권에 관한 쟁송의 종류는 크게 심결취소소송과 특허침해소송으로 나눌 수 있다.[131] 심결취소소송은 특허법 제186조제1항, 실용신안법 제56조, 디자인보호법 제75조, 상표법 제86조 제2항이 정하는 제1심사건 등 특허심판원의 심결에 대한 소 및 심판청구서, 재심청구서의 각하 결정에 관한 소에 대한 불복의 소 등을 말하며, 특허침해소송은 제3자에 의하여 특허권 등이 침해된 경우에 더 이상의 침해가 없도록 하는 침해금지청구소송이나 그 침해에 대한 손해배상청구소송, 그리고 신용회복조치청구소송 등을 말한다.[132]

현재 관할의 측면에서 심결취소소송은 특허심판원의 심결, 결정을 거친 사건에 대하여 제1심은 특허법원에서, 최종적인 제2심은 대법원에서 각각 관할함으로써 특허심판원, 특허법원, 대법원의 3단계 구조를 가지고 있고, 특허침해소송은 일반 민사소송의 경우와 같이 제1심은 지방법원합의부 또는 단독판사가 관할하고 제2심은 고등법원 또는 지방법원(또는 지원) 합의부에서, 제3심은 대법원에서 각각 관할하고 있다. 즉, 심결취소소송의 2단계는 고등법원격인 특허법원에서 관할하고 있으나, 특허침해소송의 제2심은 일반법원에서 관할하고 있다. 이와 같이 특허침해소송에 관한 제2심을 고등법원 등의 관할로 하게 된 이유는 특허침해소송이 사인간의 권리관계에 관한 분쟁을 확정하는 민사소송이기 때문에 다른 일반 민사소송과 같이 일반법원의 관할로 한 측면과 1998년 3월 1일 특허법원의 신설당시 신설법원의 관할범위를 광범위하게 설정할 경우 시행착오가 있을 것이 우려되었기 때문에 그 범위를 현행대로 한 것으로 여겨진다.[133]

그런데 특허법원의 기술전문성을 최대한 활용하여 특허침해사건 재판의 적정성·신속성을 제고하기 위해서는 특허 등에 관한 관련된 분쟁의 관할을 특허법원에 집중시키는 것이 바람직하다는 견해가 꾸준히 제기되어 왔고,[134] 이러한 연장선에서 17대 국회에서는 특허법원이 특

131) 그 외에도 서류의 불수리, 절차의 무효, 특허권 수용 등에 대한 일반행정소송이 있고, 아울러 특허권 등의 침해에 대하여는 벌칙규정에 의거 형사소송이 있으나 본 연구보고서에서는 論外로 한다,

132) 특허쟁송의 종류와 특성에 대하여는, 권혁중, 현행특허쟁송제도의 과제와 발전방안에 관한 연구, 한양대학교대학원석사학위논문 (1999), 7-11면을 참고.

133) 법정신문 1995. 4. 17, 6면 (독일특허법원의 조직·기능)에 대하여, "침해소송은 연방특허법원의 관할로 넘어오지 않았다. 이 소송들은 아직 연방특허법원이 없었을 당시에 일반민사법원의 관할에 속해 있었기 때문이다. 이 일반민사법원은 독일 각 주 들에 속해있는 법원들인데 입법절차에 있어서 독일 각 주들은 침해사건에 대한 관할을 연방특허법원으로 넘겨주는 것을 거부하였다. 이것이 커다란 단점이다."

134) 특허침해소송 관할개선추진 범국민운동본부, 특허침해소송 제2심은 특허법원에서 재판해야 한다 :特許侵害訴訟 第2審을 特許法院의 專屬管轄로 改善하기 위한 法院組織法 改正 建議, 2004. 또한 이러한 입법 움직임으로는 2002년 10월 4일 16대 국회에서 법원조직법 개정안이 발의된 바 있으나 국회 임기 만료로 자동폐기되었다.

허침해소송 사건에 대해 전속관할권을 갖도록 하는 내용의 법원조직법 개정 법률안이 2004년 11월 8일에 발의되어 계류되어 있다.[135]

이 개정안은 특허권·실용신안권·디자인권·상표권의 침해에 대한 침해금지·손해배상·부당이득반환·신용회복조치청구소송 등 이른바 "특허침해소송"에 대한 지방법원 합의부 또는 단독판사의 제1심 판결, 결정, 명령에 대한 항소 또는 항고사건의 관할을 고등법원에서 특허법원으로 이관함으로써 특허침해소송 사건의 재판에 있어서 특허법원의 기술전문성을 최대한 활용하도록 하여 특허침해소송사건에 있어 재판의 적정성 및 신속성을 제고하고 나아가 산업의 기술경쟁력을 강화하려는 취지에서 발의되었다. 법률시장 개방에 따라 사법부 차원에서의 분쟁해결시스템 혁신 필요성이 중요하게 부각되고 있고, 이는 국가경쟁력과도 직결되는 핵심과제이라 할 것이다.[136] 특히, 특허·상표 등 지식재산에 관한 거래와 그 과정에서 발생하는 분쟁은 기업의 성쇠와 직접 관련되므로, 특허법원이 향후 어떠한 기능과 역할을 담당하느냐는 현실에 미치는 영향에 있어 심히 중대한 문제라 하겠다.

2. 관할에 관한 쟁점사항

그동안 특허침해소송 등 관련사건을 특허법원에 집중하는 것이 판결의 모순방지와 특허법원의 전문성 취지에 적합하다는 의견과 민사적 구제수단과는 별개의 것이라는 취지의 의견이 제기되어 왔다. 이하에서는 특허침해소송의 항소심 관할의 변경 필요성에 대한 찬·반 의견을 살펴본다.[137]

1) 관할 변경 필요성을 인정하는 견해

---

135) 동 개정안의 「제안이유」는 다음과 같다. 특허침해소송은 특허권이 침해될 경우에 더 이상 침해되지 않도록 금지하거나 침해로 인한 손해배상 등을 청구할 수 있는 소송으로서, 특허를 받은 과학기술자나 기업을 최종적으로 보호하여주는 법적수단인 바, 특허침해소송에서는 무엇보다 먼저 특허침해여부를 가려야 하는 기술판단이 재판의 핵심쟁점이 되고 있음. 따라서 이미 1998. 3. 1.부터 특허법원을 신설하여 운영하고 있으므로, 특허침해소송의 제2심은 마땅히 특허법원의 전속관할로 함으로써 특허침해사건의 재판에 있어서 특허법원의 기술전문성을 최대한 활용하도록 하여, 특허재판이 보다 적정·신속하게 이루어지도록 하려는 것임. 이처럼 특허법원의 기술전문성을 최대한 활용하여 특허침해사건 재판의 적정성·신속성을 제고함으로써, 국가 전체의 과학기술발전을 더욱 촉진하고 산업의 기술경쟁력을 강화하는 것이, 당초 특허법원을 설립한 취지를 제대로 살리는 것임. 한편, 동 개정안의 「주요내용」은 특허침해소송, 실용신안침해소송, 의장침해소송, 상표침해소송 등 산업재산권에 대한 지방법원 합의부 또는 단독판사의 제1심 판결, 결정, 명령에 대한 항소 또는 항고사건은 이를 특허법원의 전속관할로 한다는 것이었다.

136) 우리나라에서는 사법제도개혁추진위원회를 중심으로 각계에서 활발한 논의와 개선방안이 제기되고 있다.

137) 박성득, 법원조직법 중 개정법률안(박병석의원 대표발의) 검토보고, 국회 법제사법위원회, 2004. 12, 7-13면.

(1) 특허법원의 전문성 활용

특허침해소송은 기계・금속・화학・생명공학・전기・전자 등 기술과 관련된 소송으로서 기술 분야에 대한 전문적인 지식과 경험을 필요로 한다. 특허소송전문가인 변리사를 특허침해의 경우에 소송대리를 제한하는 것은 부당하다는 지적이 있다[138]. 특허침해소송의 관건인 특허권의 해석은, 기술문제인 사실을 확정하고 이에 대해 특허법의 법리를 적용하여 법률적인 판단을 내리는 것이다.

심결취소소송은 침해소송의 선결적인 문제라고 볼 수 있는바, 심판의 대상이 동일함에도 불구하고 관할이 서로 분리되어 있음으로 인하여 문제가 발생한다는 것이다. 더욱이 이러한 특허침해소송을 기술적인 전문성이 부족한 일반법원의 법관이 담당함에 따라 전문적인 재판이 제대로 이루어지지 않고 있는 바, 이러한 문제점을 해소하기 위하여 특허침해소송을 특허법원의 전속관할로 하여야 한다는 것이다.[139]

(2) 통일적인 법해석 가능

특허침해소송이 제기된 사안이라면 소제기를 전후하여 권리범위확인심판이나 무효심판을 청구하게 되고, 이들 심판의 심결에 불복하면 심결취소소송으로 이어지게 되는 것이 상례인데, 이들 심판이나 심결취소소송은 절대다수를 변리사가 대리를 하며 특허권 등의 권리형성과정에서도 변리사가 관여하게 된다. 하지만 특허침해소송만은 변리사의 관여가 배제되고 변호사만 소송대리를 할 수 있게 되어 있는 구조는 해석의 문제에 있어서 다른 결과를 야기할 가능성이 있다는 것이다.[140]

사법국가주의로 일관하고 있는 미국이나 영국이 통상법원 이외에 별도의 전속관할법원을 설치한 이유는 판례의 통일을 위한 것이라는 점에 유의할 필요가 있다.[141] 우리의 경우도 마찬가지이다. 특허침해소송의 제2심을 각 고등법원의 관할로 할 경우에는 관할 집중이 되지 않아 관련 사건에 대하여 일반법원과 특허법원의 결론이 다르게 나올 가능성이 있고, 그렇게 될 경우 당사자 사이의 분쟁이 제대로 해결되지 않을 뿐만 아니라 불필요한 상소를 유발하게 되며, 궁극적으로 재판에 대한 불신을 초래하게 될 우려가 있다. 독일 또한 침해소송의 경우에 특허법원이 관할하고 있지 못하므로 특허해석과 특허무효선언을 별도의 기관에서 하고 있는 등의 문제점이 지적되고 있다. 결국 관할 집중을 통해 지적재산권과 관련한 판례의 통일성을 도모해야 할 것이다.

---

138) 이영필, 특허법원의 관할집중과 변리사 소송대리권, 산업재산권 제8집 (1999년 5월), 89면.

139) 박성득, 법원조직법중 개정법률안(박병석의원 대표발이) 검토보고 (2004), 2면 이하를 참고.

140) 이상정, 특허쟁송제도의 개선방안, 특허심판원 개원 5주년 기념 세미나 자료집, (2004. 7), 99면.

141) 이용우, 전게논문, 법조 2004년 1월, 130면.

(3) 특허분쟁의 신속·정확한 처리 가능

특허침해소송에서는 주로 특허권의 유·무효가 주된 쟁점이 되고, 특허의 무효는 무효심판절차를 통해서만 확정될 수 있으므로, 무효심판이 확정되지 아니한 상태에서는 특허침해소송에서 선결문제로 특허의 무효를 판단할 수 없는 문제가 있다. 따라서 일반법원으로서는 특허법원의 결론이 나올 때까지 사건의 심리를 미루는 경우가 많고, 더욱이 특허무효의 항변이 있는 경우에는 특허무효 여부에 관한 판단이 나올 때까지 재판을 중지할 수밖에 없어 사건처리의 지연을 피할 수 없다.

여기서 또 하나 유의해야 할 점은, 심결취소소송이나 침해소송 모두 전문적인 지식과 경험을 필요로 하는 소송이라는 것이다. 기술을 잘 아는 변호사는 흔치 않아 기술을 쉽게 이해하지 못하는 변호사를 소송대리인으로 선임할 가능성이 많은데, 특허침해의 소송대상은 기술이므로 사실의 확인과정에서 소송당사자가 설명을 해 주더라도 쉽게 이해할 수 없으며, 또한 재판부에 소송당사자가 전달하고자 하는 사실 설명도 대리인에 의해 원활하게 이루어지지 못하는 점이다.[142]

이와 같이 특허침해소송에서 변리사의 배제로 인하여 소송의 적정, 신속하게 진행되어야 한다는 이상이 실현되기가 어려워, 그 폐해는 소송당사자에게 큰 불편과 부담으로 돌아가게 된다는 것이다.[143] 특허침해소송의 항소심 관할을 특허법원으로 집중할 경우에는 지적재산권 관련 분쟁을 신속하고 적정하게 처리함으로써 결과적으로 국민에게 보다 양질의 사법서비스를 제공할 수 있게 되는 이점이 있다.

(4) 소송경제와 효율성 측면

분쟁의 해결의 장애가 될 뿐만 아니라 국민에게 이중의 부담을 지운다고 하는 견해가 있다.[144] 특허소송은 자금과 뚜렷한 고객도 변변히 없이 자신의 발명품 하나만을 믿고 새로운 시장에서 신기술 제품을 사업화 하려는 개인발명가나 벤처형 중소기업이 소송당사자인 경우가 대부분인 것이 사실이다. 이러한 경우 경제적 약자에게 이중의 소송비용 지출을 강요하는 것은 사실상 재판받을 기회를 현저하게 제한할 뿐만 아니라, 결과적으로 신기술 개발노력을 좌절시켜 국가경쟁력 제고에도 부정적인 요인이라는 것이다.[145]

서로 관련을 가지고 있는 소송을 다른 법원에서 별도의 절차로 각자 처리하는 경우에 재판을 하는 법원이나 재판을 받는 당사자 모두에게 이득이 될 것이 없음은 자명하는 것이다. 이

---

142) 이인정, 특허쟁송제도 개선방안에 대한 고찰, 특허심판원 개원 5주년 기념 세미나 자료집, (2004. 7), 126면.

143) 이용우, 전게논문, 131면.

144) 김홍규·표호건, 산업재산권권리자를 보호하기 위한 침해의 효과적 구제방안, (1998. 3 참조)

145) 이영필, 전게논문, 산업재산권 제8집 (1999년 5월), 91면.

경우 각 법원은 각기 독자적으로 재판을 하게 됨에 따라 서로 다른 결론을 낼 수도 있게 되어 재판 사이의 모순과 저촉을 피할 수 없게 되고 불필요한 상소를 유발시키며 재판에 대한 불신을 가중시키는 결과를 초래한다고 본다.[146]

결국 특허침해소송은 대부분 심결취소소송과 그 심리대상이 동일함에도 이를 특허법원이 아닌 일반법원에서 심리하도록 하는 것은 심리의 중복을 초래하여 시간과 노력이 이중으로 소요되고, 당사자에게 과다한 비용을 지출하게 하는 단점이 있다는 견해이다.

2) 관할변경 필요성을 부정하는 견해

(1) 전담재판부 구성을 통한 전문성 확보

특허침해소송을 특허관련 전문지식을 가진 법관들로 구성된 전담재판부에서 맡도록 하고, 법원조사관으로 하여금 기술 분야의 판단에 조력하도록 한다면 굳이 특허침해소송의 관할을 특허법원으로 이관할 이유가 없다는 것이다.[147]

오히려 특허법원은 대전광역시에 소재하고 있어 특허관련 전문지식을 가진 법관들은 특허법원보다 서울지방법원이나 서울고등법원의 지적재산권 전담재판부에 근무하는 것을 더 선호할 가능성이 있으므로, 운영 여하에 따라서는 오히려 서울지방법원 또는 서울고등법원의 지적재산권 전담재판부가 더 전문성이 있는 판단을 할 수 있다는 것이다.

(2) 특허침해소송과 특허심결취소소송의 소송물 차이

특허침해소송과 특허심결취소소송은 관련사건이기는 하나 그 소송물이 동일한 것이 아니므로 양 소송의 결론이 서로 다르게 나올 수 있는 것은 제도의 성격상 당연하며, 특허침해소송의 항소심을 특허법원에서 담당한다고 하더라도 특허침해소송과 특허심결취소소송을 반드시 특허법원과 같은 재판부가 동시에 담당할 것이라는 보장이 없다.[148]

즉, 특허침해소송이 여전히 1심에 계속 중에 있는 동안에 특허심판원의 심결이 이루어지고 그 심결에 대한 취소의 소가 특허법원에 제기될 수 있고, 특허침해소송은 특허법원에 계속 중에 있지만 특허심판사건은 특허심판원 단계에서 그대로 확정되거나, 아니면 빨리 진행되어 특허법원을 거쳐 이미 대법원에 계속 중일 수도 있는 것이다. 따라서 특허침해소송의 결론과 특허심결취

---

146) 이장호, 특허소송과 특허침해소송의 일괄처리방안에 관한 연구, 특허소송연구 제1집 (1999), 175면.

147) 이러한 입장에 대한 소개는 이상정, 특허쟁송제도의 개선방안, 특허심판원 개원 5주년 기념 세미나 자료집, (2004. 7), 102면.

148) 실정법인 특허법 제132조의 2, 제186조 및 법원조직법 제28조의 4을 검토하면서 관할집중의 반대의견으로는 김용진, 특허소송의 관할집중과 반소의 허용여부 및 소송대리권의 확대문제, 산업재산권 제8호 (1999), 71면.

소소송의 결론의 저촉문제의 해결과 특허침해소송의 관할변경문제는 직접적인 관계가 없다는 것이다.

(3) 업무증대로 인한 소송경제의 역행 및 비효율

특허침해소송의 항소심을 특허법원이 관장하게 되면 오히려 특허법원의 전문성이 약화될 우려가 있다. 현재 특허법원은 적정 수의 사건을 효율적으로 잘 처리해 내고 있는데, 특허법원의 관할을 확대하여 특허침해소송까지 관할하도록 하면, 특허침해소송의 성질상 특허권의 성립 및 효력범위에 관한 문제뿐만 아니라 손해의 발생 및 그 범위라는 일반 민사소송적인 문제에 관해서도 많은 시간과 노력을 들여야 한다. 이는 특허법원이라는 별도의 전문법원을 설치한 취지에 맞지 않는 것으로서, 그 동안 잘 운영되어 온 특허법원의 전문성과 효율성을 크게 떨어뜨리는 결과가 될 수 있다는 견해이다.[149]

3. 주요국의 경우

1) 미국

(1) 연방항소법원의 탄생

1982년 연방법원개선법(Federal Court Improvement Act 1982)에 의해 연방순회항소법원(The Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC)이 설립되어 종래의 관세특허항소법원(Court of Customs and Patent Appeals: CCPA)은 폐지되었다.[150] CCPA가 내린 판결은 CAFC의 전원합의체에서 번복되지 않는 한 선례로서 구속력을 갖는다. 각 지방 연방법원 사이에서 판결의 모순, 불일치가 심심찮게 일어나, 사건 당사자가 자신에게 유리한 견해를 취하는 법원을 찾아 제소하는 이른바 “Forum Shoppping"의 현상이 나타나게 되었다.

위와 같은 폐해를 불식시키기 위하여 마침내 1982년 의회에서 동 법이 통과되었고, 이 법에 의하여 종래 관할 지역에 따라 12개로 구성되어 있던 연방항소법원에 13번째 법원인 CAFC가 새로이 설치되어, 토지관할에 따라 관할권이 분할되어 있는 다른 12개의 항소법원과는 달리 특허 및 상표 등 특정사건에 관하여 미국 연방전체에 걸친 독자적인 직무관할을 갖게 되었다.[151] 미국에서 특허사건에 관한 전속관할권을 부여하여 특허법분야에서의 국가적인 판례의 통일성을 도모하기 위하여 CAFC을 설립하게 된 것이다.[152] 종래에는 여러 곳의 연방항소법원

149) 반대의 입장에서 특허침해소송을 특허법원에서 심리하여야 하는 주된 이유를, 만약 다른 법원에서 심리한다는 것은 각 법원의 심리가 중복되게 되어 이중의 시간과 노력 및 경비가 소요되어 비경제적인 면을 비판한 견해로는 이 장호, 특허소송과 특허침해소송의 일괄처리방안에 관한 연구, 특허소송연구 제1집, 특허법원(1999), 173면.

150) 미국의 특허소송구조에 대하여는 이두형, 전게논문, 29면.

151) 홍태준, 특허심판제도에 관한 연구, 국민대학교대학원석사학위논문 (1999), 82면.

에서 동일한 문제에 대해서도 서로 상이한 판결이 내려졌다. 그러므로 특허법분야에서의 연방항소법원 간의 판례의 모순, 소송의 지연, 연방대법원에 대한 상고사건의 증가 등의 문제점을 해결하기 위한 목적에서 탄생한 것이 바로 연방항소법원인 것이다.[153]

미국에서는 특허무효를 구하는 별도의 심판은 존재하지 아니하고 특허의 무효는 연방법원의 특허침해소송에서 항변사유로서 제출될 수 있을 뿐이다. 미국 특허청(Patent and Trademark Office; PTO)의 최종적 거절사정에 대하여 불복이 있는 자는 미국 PTO 내의 항고부에 항고할 수 있고, 위 항고부의 심결에 불복하는 때에는 CAFC에 항소하거나 컬럼비아특별구 연방지방법원에 민사소송을 제기할 수 있게 된다.[154]

(2) 연방항소법원의 기능

CAFC에 항소할 것인지 아니면 컬럼비아특별구 연방지방법원에 민사소송을 제기할 것인지는 택일적이다. 즉 PTO 내의 항고부의 실결에 불복이 있는 자가 CAFC에 항소한 경우에는 컬럼비아지구 연방지방법원에 민사소송을 제기할 권리를 포기한 것으로 본다.[155] 따라서 컬럼비아지구 연방지방법원에 민사소송을 제기하기 위해서는 CAFC에 항소하지 않았다는 요건이 필요하다.[156]

한편 PTO 내의 항고부의 심결에 불복이 있는 자가 컬럼비아지구 연방지방법원에서의 민사소송을 선택하게 된 이유는, 두 법원에서 이루어지는 소송의 성질이 다르다는 점에 있다.[157] CAFC는 사후심이어서 사실심리가 이루어지지 않는 반면에, 컬럼비아지구 연방지방법원은 사실심리를 하므로 PTO 절차에서 제출되지 않았던 새로운 증거를 확보하여 사실인정을 다투기를 원하는 당사자는 당연히 컬럼비아지구 연방지방법원에 민사소송을 제기하는 방법을 선택하게 될 것이다. 결국 컬럼비아지구 연방지방법원의 판결에 대하여 불복이 있는 경우 CAFC에 항소할 수 있으므로 어느 소송수단을 택하여도 CAFC의 판단을 받을 기회가 주어지게 된다. 그러므로 CAFC는 모든 특허사건을 전속관할하는 특허법원이다.[158]

CAFC는 12명의 판사로 구성되어 있으며, 그 중 반 이상은 특허전문변호사로 충원된다.[159]

---

152) 황한식, 특허심결취소소송의 심리범위, 법조 (1997), 51면.

153) Panduit Corp. v. All States Plastic Mfg. Co., Inc., 744 F.2d 1564, 1574, 223 USPQ 465, 470(Fed. Cir. 1984). "It is, therefore, clear that one of the primary objectives of our enabling legislation is to bring about uniformity in the area of patent law."

154) 35 U. S. C. A. § 134, § 141, § 145 를 참조할 것.

155) 35 U. S. C. A. § 141.

156) 35 U. S. C. A. § 145.

157) 이 점에 대한 설명으로는 황한식, 전게논문, 53면 이하를 참고할 것.

158) 28 U.S.C. § 1295 (a)(1).

159) 한국과학기술청년회, 과학기술발전을 위한 특허제도의 개선방향, 38면.

미국 특허소송에서 하나의 특징은 특허무효를 구하는 별도의 심판제도가 존재하지 않고 특허의 무효는 특허침해소송에서 항변사유로 제출된다는 점인데, 특허침해소송은 각 관할 연방지방법원이 제1심을 담당하고 항소심은 CAFC의 전속관할로 되어 있다. 종래에는 재판부의 특성에 따라 많은 특허가 무효로서 판시되는 경향이 있었지만, CAFC는 창설 이래 많은 특허옹호(pro-patent)적 판결을 내리고 있다.[160]

(3) 기술보좌관제도

연방항소법원은 기술보좌관의 도움을 받을 수도 있고, 보다 적임자를 수탁판사로 임명하여 그로 하여금 사실조사를 하도록 위탁할 수도 있다.[161] 기술보좌관은 감정인과는 달리 소송당사자들의 질문을 대답해야 할 의무도 없고, 기술보좌간이 사실심법원에서 제출되었던 증거의 기술적 측면에 대한 검토를 하더라도 그러한 기술보좌관의 검토결과가 공식적인 소송기록에 포함될 수도 없다.[162]

2) 일본

(1) 동경고등재판소 전문부

대법원에 상고 제기된 특허사건이 증가하여 대법원의 업무부담이 가중되고 특허사건에서 당사자들이 법원에 의한 사실심리를 받을 권리를 충실히 보호해주고, 하급심법원이 특허사건을 담당해야 할 필요성이 제기되면서 새로이 제정된 헌법의 규정[163]에 의하여 1948년에 특허법과 재판소법 등을 개정하여 동경고등재판소로 하여금 특허심판에 대한 취소소송을 전속적으로 심판할 수 있도록 하였다.[164] 사정계, 당사자계를 불문하고 심판은 특허청 심판부에서 행하며 특허청 심판부의 심결에 불복하는 자는 동경고등재판소에 행정소송인 심결불복취소소송을 제기할 수 있었다. 동경고등법원에는 법원 내에 특허사건을 전담하는 3개의 전담재판부를 두고 있었다.[165] 특히 특허사건을 담당하는 전문부의 부장판사는 특허법에 관한 경험과 지식이 있는 판사로 보임되고 대부분 퇴직할 때까지 계속 동 전문부의 부장판사로 근무함으로써 동경고등재판소 전문부의 전문성을 확보해주고 있었다.[166] 종래 동경고등재판소 전문부가 담당하는

---

160) ロバート·E·レブランク외 , 米國特許訴訟戰略 I, 4면.

161) 수탁판사라 함은 특정사건에 한해서 증거조사 또는 사실판단 등을 하도록 위탁하여 그로 하여금 보고서를 제출하게 하는 제도이다.

162) 정상조, "특허법원의 운영방안", 대한변리사회, 162면.

163) 제76조 제2항 특별재판소는 설치할 수 없다. 행정기관은 종심으로 재판할 수 없다.

164) 특허청의 심결에 대한 동경고등재판소의 전속관할에 대한 설명으로는 홍태준, 전게논문, 105면.

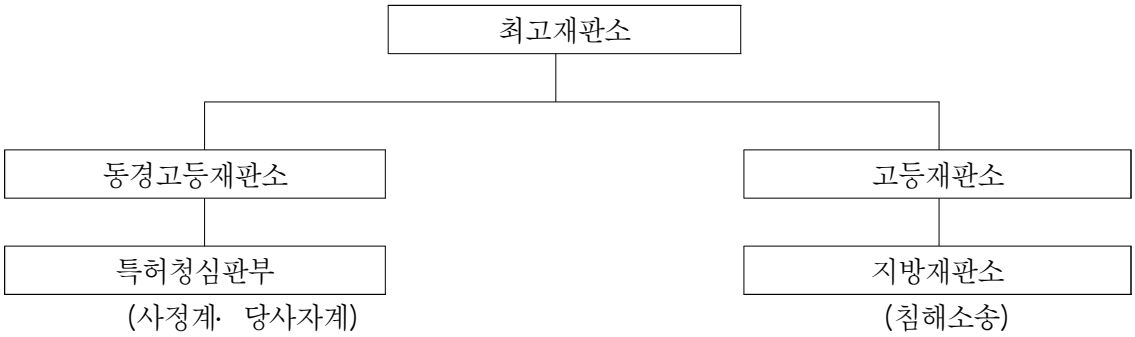
165) 3개의 전담재판부는 민사3부, 민사16부, 민사18부를 의미한다.

166) 신운환, 특별행정쟁송제도에 관한 연구, 서울대학교대학원박사학위논문(1994), 287면.,

취소소송은 특허법에 규정된 다양한 심결과 결정에 대한 취소의 소송이었다.[167] 취소소송의 대상이 되는 심결로는, 심판청구 또는 재심청구사건에서 본안에 관해서 내려진 심결이나 부적법함을 이유로 각하한 심결이 포함된다. 또한 동경고등재판소 전문부는 요지변경에 해당되는 것으로 보정신청을 각하하는 결정이라거나 심판청구서 또는 재심청구서 자체를 각하하는 결정에 대한 취소의 소송도 심판을 하였다.[168]

침해소송은 일반 민사사건과 마찬가지로 일반법원의 관할로 되어 있다. 다만 일본 민사소송법 제6조는 "특허권, 실용신안권, 회로배치이용권 또는 프로그램의 저작물에 관한 저작권"에 관한 소에 대하여는 관할법원 외에 동경지방법원 또는 대판지방법원에도 제기할 수 있도록 부가적 관할권을 인정하여, 전문성이 강한 소에 대해 부가적 경합적으로 관할권을 인정했던 것이다. 그 결과 당사자가 특허권 등에 관한 소를 양 지방법원에 제기하기 쉽도록 되어 당사자가 전문부에 의한 심리를 받을 기회가 확대되었고, 특허권 등에 관한 소를 양 지방법원에 제기하는 경향이 강해지고, 이를 통하여 사실상 관할의 집중이 도모되어 전문부를 가진 양 법원이 이러한 종류의 사건에 관한 노하우를 확보하기 쉽도록 하였던 것이었다.[169]

<종래 일본의 특허심판·소송구조>



(2) 지적재산관련 소송의 관할집중화

일본의 1921년 특허법은 항고심판과 대심원에 대한 상고제도를 규정하고 있었으나, 1948년 동경고등재판소를 전속관할로 하는 심결취소소송제도가 정해지고, 1950년 동경고등재판소를 전속관할로 하는 심결취소소송과 지적재산에 관한 침해소송의 항소사건을 집중적으로 취급하는 제5특별부가 창설되었고, 저작권과 부정경쟁방지법위반 등을 포함하는 지적재산사건에 대한 전문적 처리태세가 완성되었다.[170] 그 뒤 2003년 민사소송법이 개정되면서 특허권, 실용신안권

167) 정상조, 전게논문, 168면.

168) 일본 특허법 제178조 제1항.

169) 이상정, 특허쟁송제도의 개선방향, 특허심판원 개원 5주년 기념 세미나 자료집 (특허심판원 2003), 96면.

170) 최근 일본의 동향에 대하여는 설범식, 일본지적재산권 소송제도의 개혁 동향, 특허소송연구 제3집(특허법원 2005), 356면 이하를 참고.

등에 관한 침해소송에서 동쪽 지방은 동경(東京)지방재판소에서, 서쪽 지방은 오사카(大阪)지방재판소의 전속관할로 되었다. 그리고 개정 전에는 동경고등재판소와 오사카고등재판소로 나누어져 있던 것을 동경고등재판소로 집중함으로써, 특허청의 심결에 대한 취소소송을 담당하는 심결취소재판소와 침해소송의 항소심을 일원화하였던 것이다.[171]

침해소송의 항소심을 심결취소소송 재판소로 일원화함으로써 판례를 항소심 단계에서 조기에 통일할 수 있고 하여 산업계로 하여금 지적재산권 분쟁에 신속하게 대응할 수 있게 되었으며, 침해소송에서 무효사유의 항변이 가능한 데 따른 침해소송의 결론과 등록무효심판의 결론이 서로 모순 저촉되는 현상을 최소화할 수 있는 사법시스템을 구축하였다. 결국 특허권·실용신안권·프로그램저작권 등을 둘러싼 침해소송의 관할의 집중으로 말미암아, 그 재판소에 고도의 기술에 관한 지적재산 소송에 밝은 재판관과 기술전문가인 재판소조사관을 통하여 보다 신속하고 높은 수준의 재판의 혜택을 받았던 것이었다.[172]

(3) 지적재산고등재판소의 발족

급증하는 기술 분쟁, 기술을 알지 못하는 법정, 복잡한 소송제도, 기술이 유출되는 특허재판이라는 비판으로부터 제기된 것이 지적재산전문의 재판소 구상이다. 각 국의 특허법원 설립과 유럽연합의 지역 내 지적재산분쟁을 한 번의 소송으로 해결하기 위한 2003년 3월 공동체특허재판소설립에 대한 기본합의에 자극받아 지적재산재판소의 창설은 세계적인 조류라며 그 창설을 요구하게 되었던 것이다. 결국 2005년 4월 1일 지적재산고등재판소가 발족하였다. 동경고등재판소에서 특허소송 등을 전문으로 취급하는 18인의 재판관을 모체로 하여 출발하였다. 이러한 지적재산고등재판소에서 관할하는 사건은 사건의 성질·내용이 지적재산에 관한 사건인 한 동경고등재판소의 관할에 속하는 모든 사건에 미친다. 하지만 민사사건과 행정사건을 고려해서 설치한 것이므로 지적재산에 관한 형사사건까지 취급하지는 않는다. 지적재산고등재판소는 전국의 8곳에 있는 기존의 고등재판소와 비교하여 다음과 같은 차이점을 볼 수 있다.[173]

첫째, 8개의 고등재판소는 원칙적으로 전국을 지역마다 관할하고 민사에서 형사까지 폭넓은 사건을 취급한다. 이에 대하여 지적재산고등재판소는 전국의 모든 특허소송 등의 제2심을 혼자서 취급한다.

둘째, 지적재산고등재판소는 동경고등재판소의 일부이지만 사법행정면에서는 일단 동경고등재판소로부터 독립된 조직이다. 재판소의 최고기관은 재판관에 의한 재판관회의인데, 지적재산고등재판소는 동경고등재판소의 재판관회의와는 별도로 독립된 재판관회의를 가지며[174], 사무

171) 일본 민사소송법 제3항 참조.

172) 설범식, 전게논문, 358면.

173) 설범식, 전게논문, 362면.

174) 지적재산고등재판소설치법 제4조 제2항.

부분도 동경고재와 별도의 사무국을 두고 있다.[175]

지적재산고등재판소는 재판소법의 특칙으로서 특별히 법률에 의하여 설치한 지적재산에 관한 사건에 특화한 재판소이므로, 동경고재의 전속관할에 속하는 일정한 지적재산사건(특허권 등에 관한 소의 항소사건, 심결취소소송) 외에 저작권이나 부정경쟁방지법위반 등을 포함한 모든 지적재산사건을 포괄적으로 취급한다.[176] 지적재산고등재판소의 판결에 대하여는 최고재판소에 상고할 수 있다.

<미국 CAFC와 일본의 지적재산고등재판소 및 한국의 특허법원의 비교>[177]

	CAFC	지적재산고등재판소	특허법원
지적 사건의 점유비율	전체 담당 사건 중 약 30%가 지재사건	지적재산 사건만 100% 담당	지적재산 사건의 일부만 담당
지재사건의 종류	① 특허권, 식물품종에 관한 침해사건의 항소심 ② 특허상표청의 심결에 대한 불복사건	① 모든 특허, 실용신안, 프로그램저작권 등의 침해소송 항소심 ② 동경고등 관내의 저작권, 의장권, 부정경쟁방지법 등의 침해소송의 항소심 ③ 특허청의 심결에 대한 불복사건	특허청의 심결에 대한 불복사건
심급의 성격	법률심(예외적으로 사실심도)	사실심	사실심
법관 수	12명	18명(4개 재판부)	12명(4개 재판부)
지적재산소송의 접수건수	552건	640건	878건
기술적 보조자	Technical Adviser, Special Master	재판소조사관 11명 전문위원	기술심리관 9명

175) 지적재산고등재판소설치법 제5조.

176) 설범식, 전게논문, 363면.

177) 설범식, 전게논문, 366면 주석 45참조.

3) 독일

(1) 연방특허법원의 탄생배경

특허청 내의 무효심판부는 특허등록의 무효여부와 강제실시권의 허여여부를 심판하는 권한을 가지고 있고 항고심판부는 특허거절사정과 이의신청에 대한 결정에 대한 불복사건을 심판하는 권한을 가지고 있었다.[178] 하지만 항고심판부의 심결은 더 이상의 불복을 할 수 있는 길이 없는 최종심으로서 그 후에는 어떠한 쟁송방법도 인정하지 않았으므로 이 경우 독일 기본법 제19조 제4항과 관련하여 볼 때 항고심판부의 심결을 법원의 판결로 간주할 경우에만 가능한 것이다.[179] 하지만 항고심판부의 심결이 사법부의 판결이라는 견해는 비판을 받았다.[180]

1959년에 이르러 베를린연방행정법원은 드디어 특허청 항고심판부에 의한 심판부에 의한 심판이 독일연방기본법상의 사법적 구제절차에 해당되지 않는다고 하면서, "독일특허청의 항고심판부는 연방헌법재판소의 판례로 인정되어 온 '국가와 국민사이의 분쟁해결에 필요한 조직적인 독립성'을 갖추고 있지 않으므로 공정한 제3자로 볼 수 없기 때문에 일종의 특별행정법원이 아니며, 따라서 항고심판부의 심결은 행정행위이므로 사법적 심사의 대상이 된다"고 판결함으로써, 기본법의 규정을 통한 조직의 질서를 위하여 특허청사건의 심급을 조정할 필요성이 시급하게 되었던 것이다.[181]

베를린연방행정법원의 이러한 판결의 결과로 1961년 3월 6일에 독일연방기본법이 개정되어 연방특허법원의 설립에 관한 헌법적 근거가 마련되었고 같은 달 23일에 특허법이 개정되어 독일 특허청내의 항고심판부와 무효심판부는 연방특허법원(Bundespatentgericht)으로 분리되어 나가게 되었다.

(2) 관할의 분리

독일의 경우 1961년 연방특허법을 개정하여 연방특허법원(Bundespatentgericht)을 설립하여 특허청의 결정에 대한 항고와 특허무효소송 등 심결취소소송은 연방특허법원에서 관할하고 있다.[182] 다른 모든 특허소송물은 일반법원의 보통재판관할에 속한다.[183] 따라서 특허해석과 특

---

178) 정상조, 특허법원의 운영방안, 대한변리사회(지적재산권 논문집 제5집), 170면.

179) 홍태준, 전게논문, 60면.

180) 항고심판부의 심결에 대한 취소소송이 뮌헨의 바이에른 주 행정법원에서 제기되었으며 이에 대해 19578년 2월 27일 바이에른 주 행정법원은 중간판결을 통해 "바이에른 주 행정소송법 제22조에 따른 행정소송방법은 특허청의 항고심판부의 심결에도 해당한다"고 하여 특허청의 활동은 사법행위가 아니라 행정행위라는 견해가 확대되기 시작되었던 것이다.

181) BVerGE 8, 350; GRUR 1959, 435; 박정미, 독일 연방특허법원의 설립경위, 법적성격 및 구성, 지적재산(1994. 1), 51면에서 재인용.

182) 홍태준, 전게논문, 64-65면.

183) 독일 특허법 제139조 참조.

허무효선언을 별도의 기관에서 담당하고 있어 특허침해소송의 심리과정에서 특허의 무효여부가 문제되면 절차를 중지하고 있다. 독일의 경우에는 특허침해사건은 13개 특별민사법원이 관할하고, 특허청의 거절사정에 대한 항고, 특허의 무효선언, 특허취소소송은 연방특허법원이 관할하고 있는 점이 특징이다. 연방특허법원의 판결에 대하여는 연방최고법원에 상고할 수 있어 2심제를 취하고 있다.[184] 연방특허법원은 여러 개의 재판부로 나누어져 특허청 심사부·특허부의 결정에 대한 불복 사건뿐만 아니라 특허무효·취소 및 강제실시허여에 관한 신청, 그리고 실용신안 및 상표, 종자보호, 의장 등에 관한 유사한 사건도 그 심판권의 대상으로 한다. 연방특허법원의 무효부는 특허의 무효·취소 및 강제실시허여에 관한 신청을 심판하고, 특허항고부는 출원거절과 특허부여 등 특허청 심사부·특허부의 결정에 대한 불복사건을 심판하며, 이와 유사한 실용신안항고부, 상표항고부, 종자보호항고부가 있고 그 이외에 일반항고부는 이러한 각 부에 속하지 않는 특허청결정에 대한 불복사건을 심판한다.[185] 그러나 연방법원은 특허권, 상표권, 의장권 등에 관한 침해를 근거로 한 손해배상청구의 소송과 같은 소위 침해소송에 대한 심판권은 없다.

(3) 기술판사

연방특허법원은 법원장, 재판장, 기타의 판사들로 구성되어 있고, 판사들의 3분의 1은 독일법관법에 규정된 일반법관의 자격을 갖춘 소위 법률판사이고 3분의 2의 판사들은 과학기술을 전공한 소위 기술판사로 구성되어 있다.[186] 독일특허법원의 법관의 자격에 관해서는 독일법관법 제5조 이하에서는 법률판사에 관해서 규정하고 있고, 제120조 이하에서는 독일특허법 제65조 제2항과 관련하여 기술판사에 대해서 규정하고 있다.[187] 기술전문가가 재판부의 구성원인 판사가 판결을 내린다는 것은 큰 장점을 가지고 있으며, 다른 전문 감정인과는 달리 시간적으로나 심리범위에 있어서나 아무런 제약 없이 해당 재판부에 소속되어 있다. 연방특허법원을 설

184) 이시윤·이상정, "특허법원의 신설과 특허심판구조의 개편", 사법행정, 제422호 (1996), 18면.

185) 정상조, 전게논문, 대한변리사회, 172면.

186) 우리나라 기술판사의 도입여부에 대하여는 김정자, 전게논문, 76면 이하, 기술판사제도를 도입하여 역할에 맞는 지위와 신분보장을 마련해야 한다는 입장에 대하여. 기술판사가 있다고 하더라도 전문분야 이외의 다른 기술분야나 첨단 과학분야는 어차피 관계 전문가의 도움을 받지 않을 수 없으며 현대 과학기술이 점차 비약적으로 발전하여 기술판사가 한 때의 전문가라고 하더라도 계속 전문성을 유지하는 데는 한계가 있다고 하면서 기술판사의 도입을 반대하는 입장이 있다.

187) 독일특허법 제65조 제2항 독일특허법원은 한 명의 법원장 및 부장판사들과 여타의 판사들로 구성된다. 그들은 독일법관법에 따른 법관의 자격을 보유하거나(법률판사) 또는 어느 한 기술 분야에서의 전문가(기술판사)이어야한다. 기술판사에 대하여는 국가시험 또는 대학의 졸업시험에 합격해야만 한다는 제26조 제2항의 기준이 준용된다. 한편 독일특허법 제26조 제2항은, 기술판사의 경우 국내소재의 정규대학, 기술대학 또는 농업대학 또는 광산대학의 정규학생으로서 자연과학 또는 기술 분야에서 수학한 후, 국가시험 또는 대학졸업시험에 합격해야 하며, 그 외에 추가로 최소 5년 이상 실무적인 일을 하여야 하고, 필요한 법적인 지식을 갖춘 자이어야 한다. 외국 대학에서 공부한 경우에는 2년까지의 기간만이 수학기간으로 인정될 수 있으며, 이 경우에도 졸업시험은 국내에서 치러야 한다.

립하는데 있어서 기술판사 자리는 주로 독일 특허청의 항고심판부와 무효심판부에 소속되어 있던 인사들로 채워졌으며, 동시에 두 심판부는 해체되었다. 연방특허법원의 기술판사들은 독일 특허청의 심사관들로 채워졌으며, 다만 연방특허법원의 부장판사인 기술판사는 연방특허법원에서 다시 독일 특허청으로 자리를 옮겨 몇 년간(특허청 국장) 근무를 한 사람 중에서 임명된다.[188] 이러한 방법을 통하여 독일 특허청에서 경험을 많이 쌓고 자격을 갖춘 심사관에게 직무에 있어서 더욱 발전될 수 있는 기회와 동기를 부여하게 되고, 기술판사는 재판을 하는 데 있어서 기술 분야에 관한 실무지식과 감각을 아주 탁월하게 유지할 수 있다.

4) 영국

영국은 1977년 국제통상의 확대와 그에 알맞은 특허보호의 필요성의 증대됨에 따라 특허법을 개정하였다. 이 때 특허소송제도에 있어서도 많은 변혁을 가져와 특허에 관한 취소사건을 전문적으로 심리하기 위하여 1977년 고등법원, 형평법부의 일부로서 특허법원을 설치하여 이 특허법원이 심사관의 거절사정에 대한 불복은 물론 등록된 특허의 무효 및 침해사건까지를 심리하도록 하였다.[189] 침해소송은 일반법원에서 관할하도록 하였으며 재판부는 특허변호사 중에서 선임된 여러 명의 판사로 구성되었고 그 판사는 특허와 관련된 상당한 법률지식과 함께 기술적 문제에 관해 폭넓은 이해력을 갖고 있으며 법원에 기술적 조언을 할 전문가를 고용할 수 있도록 규정되었지만, 판사가 기술에 관한 지식을 가지고 있으므로 전문가의 역할은 사실상의 유명무실하였으며 또한 특허법원에 판결에 대하여는 특정한 경우에 한하여 공소법원에 상소할 수 있도록 되어 있었다.[190]

한편 특허법원의 심리가 기존의 민사소송절차를 따르고 있어서 매우 복잡한 사실 관계의 분쟁을 갖고 있는 특허심판에 적합하지 않아, 판결에 이르기까지 시간이 오래 걸린다는 점과 특허소송제도의 당사자주의[191]로 인하여 소송비용이 너무 많이 들어 중소기업과 개인발명가들이 특허소송제도의 이용에 비난이 제기되었다. 그 해결책으로 기존의 특허법원을 폐지하지 않는 대신 좀 더 간단한 절차를 가진 새로운 법원을 신설하기로 하고, 특허지방법원(Patent County Court: PCC)제도를 채택하여 1990년부터 시행하여 좋은 평가를 받고 있다. 영국의 경우에는 특허청의 거절결정에 대한 불복, 특허무효, 특허침해 등에 관하여는 제1심 법원의 역할을 하는 특허법원(Patents Court) 또는 특허지방법원(Patents County Court)에 소를 제기할 수 있고, 그 재판에 대한 불복이 있는 경우에는 영국에 하나 뿐인 항소법원(Court of Appeal)에 항소할

188) 전경애, 전게논문, 60면.

189) 영국에서 관할 문제에 대하여는 홍태준, 전게논문, 111면 이하를 참조.

190) 홍태준, 전게논문, 111면.

191) 근대의 소송은 당사자주의 당사자대등주의 내지는 당사자평등의 원칙에 입각하고 있다는 의미에서 이것을 당사자소송이라고 한다. 민사소송에서는 특히 변호사소송에 대하여 당사자본인소송을 뜻한다.

수 있다. 특허침해소송은 특허법원뿐만 아니라 일반법원에도 제기할 수 있고, 특허침해여부와 특허유효여부가 함께 심리되는 경우에는 특허법원, 특허지방법원 또는 일반 법원에 소를 제기할 수 있으며, 그 판결에 불복이 있는 경우에는 항소법원에 소를 제기할 수 있다.

<표-> 주요국가의 특허소송의 관할[192]

국가	심결취소소송			특허침해소송		
	전심	제1심	제2심	제1심	제2심	제3심
미국	특허청 항고부	연방순회항소법원	연방대법원	연방지방법원	연방순회항소법원	연방대법원
일본	특허청 심판소	동경고등재판소	최고재판소	오사카, 동경지방재판소	동경고등재판소 (동 재판소의 특별지부로 ' 지적재산고등재판소' 설치(2005. 4. 1))	최고재판소
독일		연방특허법원	연방대법원	13개 지방법원	해당 주의 항소법원	연방대법원
영국	특허법원, 특허지방법원	1개의 항소법원	귀족원	특허법원, 특허지방법원, 일반법원	1개의 항소법원	귀족원

4. 개선방향

법률의 개방화에 따른 문제점을 개선하기 위한 방안을 고려함에 있어, 사법국가[193]로 일관하고 있는 미국이나 일본이 별도의 특허법원을 설립한 취지에 주목할 필요가 있다. 또한 심결취소소송과 특허권침해소송은 서로 밀접하게 관련되어 있는 사항이므로 미국, 일본 및 영국 등 대부분의 국가는 항소심단계에서는 심결취소소송과 침해소송을 동일한 법원에서 심리하도록

192) 박성득, 법원조직법 중 개정법률안(박병석의원 대표발의) 검토보고, 국회 법제사법위원회, 2004. 12, 6면.

193) 사법국가란 3권 중 상대적으로 사법에 우월적 지위를 부여하고 있는 국가로써, 재판소(법원)에 위헌법령심사권이 부여되거나 행정소송을 통상의 재판소(법원)의 관할로 하고 있는 국가를 말한다.

하고 있다. 그리고 독일의 경우에는 비록 특허침해소송은 일반법원이 관할하고 있고, 특허무효소송은 일반특허법원이 관할하고 있지만 독일에서도 극복되어야 할 문제점으로 지적되고 있다.

이미 살펴본 대로, 특허권과 관련한 산업재산권 분쟁은 특허심판원을 1심으로 하는 심결취소소송과 각 지방법원을 1심으로 하는 특허권침해소송이 대표적이다. 산업재산권에 관한 분쟁은 그 특성상 고도의 기술적 지식과 전문성을 띠고 있으므로 법률적 지식을 가지고 법리를 해석하는 법원의 판사가 판단하기에는 다소 부적합한 면이 없지 않다. 특허법원의 개원으로 말미암아 산업재산권 분쟁의 신속하고 적정한 해결 및 국민의 권익구제의 충실화에 기여한 바 크다. 특허권 보호에 관한 전문법원인 특허법원의 업무영역은 권리범위확인이나 특허무효에 관한 분쟁에 대한 소송이 있을 경우 특허심판원의 전심절차를 거치게 하면서 특허심판원 심결에 대한 취소소송만을 관할하도록 하고 있다. 하지만 특허법원이 심결 등 취소소송만을 관할하며 특허침해소송 등은 아직도 일반법원이 관할하고 있어 특허권자와 이해관계인 들이 이중적인 절차로 인하여 불편을 겪고 있고, 특허해석의 불일치의 가능성이 우려되는 등 여러 가지 문제점이 나타나고 있다. 그러므로 현재의 소송관할의 이원적 구조상 동일사안에 대한 소송중복의 자원낭비와 법령해석상의 불일치 가능성, 그리고 소송경제상 신속성 저해와 회복불능의 손해발생 가능성 등을 고려하여 관할집중이 이루어짐으로써 비효율적이고 일관성이 결여되어 있는 현재의 소송절차는 개선되어야 할 것으로 사료된다.

주요 선진국의 사례를 통하여 보더라도, 우리의 특허쟁송제도가 법리의 통일적 판단과 신속하고 효율적인 권리구제를 위하여 심결취소소송이나 특허권침해소송에 대한 항소심에 대하여는 특허법원의 전속관할로 할 필요가 여겨진다. 더 나아가 첨단산업과 관련된 컴퓨터프로그램 저작권 및 반도체집적회로배치설계권의 침해소송 또한 전문기술적인 판단이 요구되므로 특허법원의 전속관할로 정비하는 것이 바람직하다고 하겠다. 이는 각 지역에 소재한 일반법원에서 행해지는 판결에서 나타나는 불일치를 해소하고, 소송당사자인 국민들의 기본권 보호를 위한 측면에서 개선해야 할 것이다.

Ⅴ. 특허심결취소소송의 심리범위

1. 논의 배경

민사소송에 있어서 심판의 대상이 되는 기본단위, 즉 소송의 객체를 소송물, 소송상의 청구 혹은 심판의 대상이라 한다.[194] 심결취소소송의 소송물은 일반 행정소송에서의 소송물이 처분의 위법성 일반인 것과 같이 심결의 위법성 일반이다. 심결의 위법성 일반이란 심결이라는 행정처분의 절차상의 위법을 의미하는데, 여기에는 심결절차의 위법과 실체상의 위법이 존재한다. 실체상의 위법이란 구체적으로는 결정계인 거절사정 불복심판청구에 대한 심결취소소송에서는 거절이유의 존재를 긍정한 심결판단의 당부이고 당사자계인 특허무효심판청구의 심결에 대한 심결취소소송에서는 심판청구인이 주장한 무효사유의 존부에 대한 심결판단의 당부이다.[195]

일반적 행정소송은 전심절차와는 심급적 연계가 없으므로 항고소송에 있어서 원고는 전심절차에서 주장하지 아니한 공격방어방법을 주장할 수 있고, 법원은 이를 심리하여 행정처분의 적법 여부를 판단할 수 있다는 것이 판례의 입장이다.[196] 하지만 특허심결취소소송이 심판과는 심급적 연계가 없고 심판의 심결이 소송과는 전혀 별개의 독립된 행정처분이므로 위의 일반론을 그대로 적용해야 하는가라는 질문이 제기된다. 또한 비록 그와 같은 관계가 없더라도 심판을 준사법적 절차를 걸쳐 행하여지는 실질적으로 전심적 성격을 가지고 있고, 사실상 제1심으로 작용하고 있는 것을 인정하는 견해도 있다. 이처럼 심리범위는 당사자가 심리의 대상으로 확정한 소송물에 대하여 심리함에 있어서 심판절차에서 제기되지 아니한 주장, 사실 및 증거를 소송절차에서 제기할 수 있는지 여부에 관한 문제로서 소송물은 심리범위의 전제가 된다.[197]

심결취소소송의 소송물은 심결의 위법성 일반이며 여기에는 절차상의 위법과 실체상의 위법이 포함되는데, 심결취소소송의 심리범위는 주로 심결의 실체상의 위법사유 중 소송에서 제기할 수 있는 범위를 정하는 것이라고 할 수 있다. 그렇다면 특허심결취소소송의 당사자는 특허심판 및 소송의 특수성에도 불구하고 심판절차에서 판단되지 아니하였던 위법사유나 증거를 소송절차에서 주장·입증할 수 있고 특허법원은 위 주장과 입증을 심리하여 심결의 적법여부를 판단할 수 있는가에 관한 물음이 제기되는 것이다.[198] 소위 이러한 문제가 특허심판의 전심·속심논쟁, 법관의 전문화의 역할문제, 특허청과 법원과의 권한분배문제 등과 관련한 특허심결취소소송의 심리범위에 관한 문제이다.[199]

---

194) 이두형, "심결취소소송의 소송물과 심리범위", 특허소송연구 제2집, 15면.

195) 이상경, 전게서, 78면.

196) 대판 1989. 2. 14. 선고 88 누 7293 판결.

197) 이두형, 전게논문, 14면.

198) 황한식, 특허심결취소소송의 심리범위, 법조 (1997. 6), 39-40면.

여기에서는 특허소송의 심리범위에 관한 국내연구를 종합분석하고, 외국의 제도를 통한 심리범위의 근거와 적정성에 관한 비교연구를 통해 법률시장 개방 측면에서 특허소송의 심리범위에 관한 개선책을 제시하고자 한다.

2. 우리나라에서 심결취소소송의 심리범위 논의

심결취소소송의 심리범위에 대하여 살펴보기 전에, 일반 행정처분에 대한 항고소송과 달리 특허심결취소송이 갖고 특수성에 대하여 살펴보기로 한다.

첫째, 특허심판원의 심판은 소송절차에 유사한 절차에 의하여 행하여지며 심결의 형식도 판결에 유사한 형식을 가지고 이유를 붙여야 한다.[200] 이를 위하여 심판절차에 민사소송법이 준용되고 심판관의 독립, 제척·기피제도, 심판비용에 대한 심결이나 결정 등에 관한 사항이 특허법에 규정되어 있다.[201]

둘째, 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다. 행정소송법 제18조 제1항에 의하면 일반적인 행정처분에 대한 취소소송은 행정심판을 거치지 아니하고 제기할 수 있음에 반하여, 특허법은 심판전치주의를 강제하고 있다.[202]

셋째, 3심제로 운영되는 일반 행정소송과 달리 특허소송은 1심급이 생략된 2심제로 운영된다. 그러므로 특허소송의 전속관할인 특허법원의 판결에 대한 불복은 단지 대법원에 대한 상고가 있는 것이다. 이러한 특허제도의 특수성을 감안하면 특허심판원의 심판은 사실상 1심의 역할을 하고 있다는 주장도 일리가 있다.[203] 이하에서는 다투어지는 학설에 대하여 살펴보기로 한다.

1) 학설

(1) 무제한설

---

199) 전경애, 특허쟁송제도의 연구 -심결취소소송의 심리범위를 중심으로-, 한남대학교대학원석사학위논문, 33면.

200) 특허법 제162조를 참고할 것.

201) 특허법 제140조 내지 제166조.

202) 행정소송법 제18조 (행정심판과의 관계) 제1항 취소소송은 법령의 규정에 의하여 당해 처분에 대한 행정심판을 제기할 수 있는 경우에도 이를 거치지 아니하고 제기할 수 있다. 다만, 다른 법률에 당해 처분에 대한 행정심판의 재결을 있는 때에는 그러하지 아니하다.

203) 이러한 취지로 특허심판의 특수성을 인정해야 한다는 입장을 피력한 견해로는 김태윤, 특허심판원 5년의 회고와 전망, 특허심판원 개원 5주년 기념 세미나 자료집(특허심판원 2003. 7), 50면.

심결취소소송의 소송물과 심리범위의 문제는 입법의 불비에서 비롯된 것이고 결국은 해석에 맡겨져 있는바, 직권탐지주의가 적용되는 심판절차에서 모든 무효사유 내지는 거절사유는 소송물로서 잠재적 심판의 대상이 되어있으며, 당사자의 입장에서 보면 모든 무효사유거절사유의 위법성일반이 소송물이 되고 법원의 입장에서 보면 심리범위가 되므로 무제한설이 타당하다고 한다.[204] 이러한 입장에 의하면, 당사자로 하여금 심판에서 판단된 사항에 대하여서 소송물로서 청구할 수 있게 하고 법원으로 하여금 심판에서 판단된 사항에 관하여 심리하도록 심판권을 제한하는 것은 사법권은 법원에 속한다는 헌법 제101조와 법관은 헌법과 법률에 의하여 양심에 따라 독립하여 심판한다는 헌법 제103조에 위배된다는 것이다.[205] 당사자는 행정관청인 특허청의 심판사항에 대하여만 불복할 수 있고 행정처분인 특허거절처분 또는 부여된 특허의 효력을 다투는 경우에 비록 다른 위법사유가 있더라도 새로운 심리청구를 거쳐 제소하지 아니하면 아니 되는 불이익을 입게 되고 이는 행정우위사상에 기초한 헌법 제27조 국민의 정당한 재판을 받을 권리를 침해하게 되므로 행정소송에서의 당사자가 행정처분의 위법성 일반을 주장할 수 있는 것과 같이 원칙으로 돌아가 무제한설을 취할 수밖에 없다고 한다.[206] 이 견해를 취하면 심결취소소송의 소송물을 심결에 존재하는 위법성일반으로 파악하여 일반 행정처분에 대한 항고소송과 마찬가지로 법원의 사실심리의 범위에 제한이 없다고 보기 때문에, 당사자는 심결에 포함되지 않았던 일체의 위법사유를 주장할 수 있고, 새로운 증거를 포함한 일체의 증거를 제출할 수 있으며, 법원도 이를 채용하여 판결의 기초로 할 수 있게 된다.[207]

하지만 이 제도는 제1심에서 당사자가 소송자료를 충분히 제출하지 않고 있다가 항소심에 와서야 소송자료를 제출함으로써 소송의 지연이 우려되고, 소송자료의 반복제출 등의 문제점이 제기될 수 있다.[208] 또한 특허제도에 있어서 이러한 입장은 특허심판원의 존재의 필요성을 위협하며 3심체의 원칙에 위배되고 심결취소소송의 의의나 성격에도 반한다는 점에서 비판을 면하기 어렵다.[209] 특히 특허와 실용신안 사건에서 전문기관인 특허심판원의 판단을 받지 못하는 당사자는 전심경유의 이익이 박탈된다는 점 또한 간과해서는 안 될 것이다. 우리나라 대법원과 특허법원, 독일의 연방특허법원은 무제한설의 입장을 취하고 있다.

(2) 한정적 제한설

---

204) 이상경, 지적재산권소송법, 82면.

205) 이두형, 심결취소송의 소송물과 심리범위, 특허소송연구 제2집, 31면을 참고할 것.

206) 이 설은 심결취소소송의 형태를 복심적 구조로 보고 있는데, 복심제란 항소심이 제1심의 소송자료와 관계없이 독자적으로 소송자료를 수집, 이를 기초로 하여 다시 한 번 심판을 되풀이하는 구조를 말한다.

207) 이상경, 전게서, 95~96면.

208) 이시윤, 신민사소송법, 박영사(2002), 13-15면.

209) 전경애, 전게논문, 34면과 63면.

이 견해에 따르면, 우리나라의 특허법원을 신설한 가장 큰 이유가 헌법상 신분이 보장된 법관에 의한 사실심 재판이 없다는 점에서의 위헌문제를 해결하기 위함이었던 것에 비추어 볼 때, 무제한설의 견해를 그대로 받아들이기는 어렵다는 입장에서 출발하고 있다.[210] 즉 특허소송에 있어서 양 당사자는 청구기초의 변경이 없는 한 변론종결시까지 심결절차에서 제출하지 않았던 새로운 주장을 할 수 있고, 새로운 증거도 제출할 수 있도록 하여야 한다는 것이다. 새로운 주장은 심결절차에서 주장하지 못하였던 데에 정당한 이유가 없는 한 이를 특허소송절차에서 주장할 수 없도록 하고, 새로운 증거도 실기한 공격방어방법에 해당하는 경우에는 특허소송절차에서 제출할 수 없도록 하는 것이 합리적이라는 것이다. 결국 무제한설을 수용하되 실기한 공격방어방법의 원리에 의하여 특허법원에서 심결절차에서 제출하지 않았던 새로운 주장과 증거의 제출이 과도하게 이루어지는 것을 막을 수 있는 장점이 있다.[211]

(3) 동일사실 및 동일증거설

심결의 이유에서 판단된 주장과 증거에 한하여 법원이 심리할 수 있다는 견해로, 특허소송의 소송물을 심결의 위법성 일반이라고 정의하더라도 특허심판원에서의 심결의 실체적 위법성은 특허심판원의 심판의 대상을 넘어서 존재할 수는 없으므로 결국 특허소송의 실체면에 있어서의 심리범위는 특허심판원의 심판의 대상에 의하여 확정되어야 한다는 것이다.[212] 특허법 제186조 제5항이 심판전치주의를 채택하고 있는 것은 법원의 부담경감을 도모하려는 기능 이외에 기술적 사항에 관하여 전문가인 심판관의 판단을 한 번은 나타내는 것에 의하여 공중의 이익에 관계하고 있는 특허권의 消長에 대하여 보다 정확하고 안정적인 판단을 하려는 기능이 있다는 것이다. 그러므로 특허심판원에서 산업재산권 분야의 전문가인 심판관에 의하여 심판이 행해지고, 그 심결의 취소를 구하는 특허소송이 법률의 전문가인 법관에 의하여 사법기관인 법원에서 행해지게 된다는 특수성에서 특허소송의 심리범위에 있어서 위 심판전치주의 가치판단을 특허심판원의 심판의 대상 내지는 특허소송의 소송물과 연계하여 법적 형량을 통하여 특허소송의 심리범위를 이론화하여야 한다는 입장이다.[213]

이러한 동일사실·동일증거설은 심결취소소송을 심판에 대한 사후심으로 보는 견해로서, 심판

---

210) 황한식, 특허심결취소소송의 심리범위, 민사소송(I), 한국사법행정학회(1998), 348면 이하.

211) 한편 동일법조설에 의하면 법조에 규정된 특별한 거절이유(특허법 제62조) 또는 무효사유(특허법 제133조)의 범위를 넘어서 심판에서 쟁점으로 되지 아니하였던 다른 법조에 규정된 거절이유 또는 무효원인에 관한 심리를 할 수 없고 동일법조의 범위 내에서라면 새로운 주장 및 새로운 증거의 제출도 인정된다는 견해인데, 이는 속심제에 해당한다. 즉 항소심이 제1심에서 수집한 소송자려를 기초로 하여 심리를 속행하되 여기에 새로운 소송자료를 보태어 제1심 판결의 당부를 재심사하는 구조이다.

212) 전병서, 전게논문, 91면 이하.

213) 이는 사후심제라고 할 수 있는데, 항소심에서는 원칙적으로 새로운 소송자료의 제출을 제한하고 제1심에서 제출된 소송자료만을 기초로 제1심 판결의 당부를 재심사하는 구조이다.

의 준사법적 절차성 및 심판전치와 심급제도에 비추어 심결에서 판단되지 아니한 특허요건을 법원에서 판단하는 것은 심결서에 이유를 붙이게 한 취지를 무의미하게 하고, 당사자의 전심경유의 이익을 박탈하는 결과가 된다는 비판을 면하기 어렵다.[214]

(4) 개별적 고찰설

당사자계 심판 중 권리범위확인심판은 사실상 당사자 간 특허권의 침해를 둘러싼 민사분쟁으로 특허법원에서의 사실심리에 어떠한 제한을 가할 합리적인 이유가 전혀 없다고 한다.[215] 무효심판의 경우 역시 특허법 제133조 제1항 제2호 및 제3호의 무권리자에 특허된 경우 및 조약에 위반된 경우 등에 대한 심판 역시 보통의 민사사건에 유사한 것으로 특허법원에서 사실심리를 제한할 합리적 이유가 없다는 것이다.

그러나 무효심판 중 신규성과 진보성이 없음을 이유로 하는 심판의 경우에는 기술적인 문제이고, 특허심판원과 특허법원의 기능과 권한을 합리적으로 분배한다는 관점에서 특허심판원의 심결에 어떠한 법적 의의와 역할을 인정하고 특허법원의 사실심리를 제한할 필요성도 있고, 특허심판원의 준사법적 절차에 의해 무효심결을 하고, 특허법 제163조에 의하면 그 무효심결이 확정되면 대세적 효력이 있어 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 재심판을 청구할 수 없게 되어, 이러한 심결의 효력과 관련하여 “동일사실 및 동일증거”를 심판에 있어서 심리판단의 대상으로 삼아야 하고, 따라서 심결의 적부를 다투는 취소소송에서의 심리범위도 이에 제한되어야 한다는 것이다.[216]

2) 판례의 입장

우린나라 법원의 몇 가지 판례에 대하여 살펴보기로 한다.

(1) 특허등록무효심결에 대한 취소소송

특허등록무효심결의 취소소송과 관련하여 대법원은, “심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적 절차적 위법성 여부라 할 것이므로 당사자는 심결에서 판단되지 아니한 처분의 위법사유 등 심결취소소송단계에서 주장 입증할 수 있다. 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초를 삼을 수 있는 것이며,

---

214) 전경애, 전게논문, 66면.

215) 송영식, 특허법원의 관할과 심리범위, 인권과 정의 (1997), 61~62 면.

216) 개별적 고찰설에 대한 자세한 설명으로는 이두형, 전게논문, 33면.

이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것은 아니다. 따라서 원심이 심판절차에 제출되지 않았던 공지기술에 관한 자료를 증거로 채택하여 심리판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 제1점에서 주장하는 바와 같은 심급에 관한 이익이아 심결취소소송의 심리범위에 대한 법리오해의 위법이 없다"라고 하여 무제한설을 지지하였다.[217]

(2) 권리범위확인심결에 대한 취소소송

권리범위확인심결의 취소소송에서 대법원은, "통상의 경우에 있어 법원이 기술내용이 다종·다양한 발명 또는 고안에 관련된 신규성 및 진보성 등의 유무를 판단함에 있어 심판절차를 거치지 아니하고 소송단계에서 이를 처리하는 것은 그 사안의 기술적 난이도 등에 비추어 곤란하거나 부적절한 면이 없지 않다 할 것이나, 우리나라 특허법원에는 소송의 심리에 관여하여 기술적 사항에 관하여 소송관계인에게 질문하고 재판의 합의에서 의견을 진술할 수 있는 전문기술적 지식을 갖고 있는 기술심리관제도를 채택하고 있으므로, 기술적 난이도를 이유로 소송단계에서 소송관계인으로 하여금 새로운 공격방어방법을 사용하지 못하도록 제한하는 것은 국민의 정당하고 신속한 재판을 받을 권리를 침해하는 결과를 가져온다 할 것이다. 또한 심판은 특허청에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하며 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부라 할 것이어서 심결취소소송의 법원은 그 사실심리에 아무런 제한 없이 스스로 심리하여 판결할 수 있다 할 것이다. 특히 이 사건과 같은 권리범위확인심판은 사실상 당사자간 실용신안권의 침해를 둘러싼 민사분쟁의 성격을 띠고 있다 할 것이므로 특허법원에서의 사실심리에 어떠한 제한을 가할 합리적인 이유가 없다 할 것이고, 원고는 심판절차에서의 주장·입증과는 관계없이 이 사건 소송에서 이 사건 등록고안이 공지되었다는 주장과 그에 대한 입증자료를 제출할 수 있다 할 것"이라고 판시하여 무제한설의 입장에 서 있음을 보여준다.[218]

(3) 거절결정에 대한 심결의 취소소송

거절결정에 대한 심결의 취소소송에서 피고인 특허청장이 거절결정 당시 거절사유로 삼지 아니한 새로운 사유를 주장한 경우 이를 허용할 것인가에 관하여 논란이 많았다. 하지만 여기서 특허청장은 거절결정 불복심판의 심결에 대한 취소소송 절차에서 새로운 거절이유의 주장 및 그 증거 제출이 허용되지 아니한다는 제한설의 입장을 취하였다. "특허법 제63조는 '심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다'고 규정하고 있다. 또한 동법 제47조 제2항 제3호, 제4호는 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서

---

217) 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000 후 1290 판결(특허등록무효심결취소소송); 대판 2002. 12. 10. 선고 2001 후 973 판결(의장등록무효 심결취소소송).

218) 특허법원 1998. 7. 3. 선고 98 허 768 판결.

를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다'고 규정하고 있고, 동 법 제47조 제항 제3호에 의하면, 특허출원인은 특허출원일로부터 1년 3개월이 경과하였더라도 거절이유통지에서 정한 의견서 제출기간 내에 또는 거절결정에 대한 심판의 청구일로부터 30일 이내에는 그 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 보정할 수 있다는 취지를 밝히고 있다. 위 규정들은 출원인에게 새로운 거절이유통지에 대하여 의견서 또는 보정서를 제출함으로써 당해 특허출원이 거절됨을 저지할 수 있는 기회를 부여하는 취지라 할 것인데, 거절결정 불복심판의 심결에 대한 취소소송 절차에서 특허청장이 거절이유통지에 기재되어 있지 아니한 새로운 공지기술을 들면서 이에 의하면 거절결정 및 심결이 정당하다고 주장할 수 있다면, 출원인은 위 새로운 거절이유에 대하여 의견서나 보정서를 지출할 수 있는 기회를 박탈당하는 결과가 되므로, 거절결정 불복심판의 심결에 대한 취소소송 절차에서는 새로운 거절이유의 주장 및 그 증거 제출이 허용되지 아니한다"고 판시하였다.[219] 즉 거절이유에 기재되어 있지 아니한 새로운 인용발명을 들면서 출원발명이 진보성이 없다고 하는 특허청장의 주장은 심결취소소송에서 심리할 수 없다고 하였던 것이다.[220]

(4) 결론

결론적으로 말하자면, 특허법원은 무제한설을 원칙으로 하고 있지만 결정계 사건에서 특허청장이 주장, 제출할 수 있는 것은 심사 또는 심판단계에서 거절이유 또는 심결이유로 주장되거나 판단된 사실, 증거에 한하고, 소송단계에서 거절이유로서 새로운 사실을 주장하거나 새로운 증거를 제출할 수 없다고 하여 제한설적인 태도를 취하고 있다고 할 수 있다. 그러한 이유는 심결취소소송 단계에서는 의견서 또는 보정서 제출의 기회가 주어지지 않기 때문이라고 한다.

대법원 역시 "심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적 절차적 위법성 여부라 할 것이므로 당사자는 심결에서 판단되지 아니한 처분의 위법사유 등 심결취소소송단계에서 주장 입증할 수 있다. 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초를 삼을 수 있는 것이며, 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것은 아니다"라고 하여 무제한설을 지지하였다.

3. 주요국의 현황

1) 미국

---

219) 1999. 7. 1. 선고, 98 허 9871 판결.

220) 이와 같은 취지의 판결로는 1999. 7. 15. 선고 99 허 1331 판결; 1999. 4. 1. 선고 98 허 10239 판결; 1999. 10. 7. 선고 98 허 7592 판결.

미국에서의 심결취소소송 심리범위에 대하여는 컬럼비아지구 연방지방법원의 심리범위와 연방항소법원(CAFC)의 심리범위로 구분하여 설명하고자 한다.[221]

(1) 컬럼비아지구 연방지방법원

PTO내의 항고부에 대한 컬럼비아지구 연방지방법원의 심리범위는 원칙적으로 우리나라에서 특허심판원에 대한 특허법원의 심리범위와 동일한 관계에 있다고 하겠다. 물론 특허의 무효는 별도의 심판제도 없이 특허침해소송에서 항변사유로 제출된다는 점에서 결정계 소송만을 그 기준으로 한다. 사후심인 CAFC에서는 새로운 소송자료제출이 허용되지 않아 사실심리가 이루어지지 않는 반면에 컬럼비아지구 연방지방법원에서의 절차는 사실심으로서의 성격을 갖기 때문에 양 당사자는 새로운 증거에 기하여 판결을 할 수 있다. 이 경우 법원이 새로운 증거에 기하여 특허처분을 재검토하도록 PTO에 환송할 수 있다는 점도 우리나라 특허법 제189조에 상응한다.[222] 이와 같은 컬럼비아 연방지방법원에서의 절차는 원칙적으로 속심구조로 운영되고 있으나 전문성과 풍부한 경험을 갖춘 특허청에서 절차의 집중이 이루어질 수 있도록 심리범위에 대하여 몇 가지 제한을 두고 있다.[223]

결론적으로 말한다면, 미국 콜롬비아 특별구 연방지방법원은 사실심으로서 특허청 항고심판부에 제출하지 않았던 새로운 증거의 제출을 허용함을 원칙으로 하나 일정한 제한을 가하고 있다고 하겠다.

(2) 연방항소법원

반면에 CAFC는 출범 초기부터 전신법원인 CCPA가 내린 판결에 대하여 구속력을 갖는 선례로 인정하여 왔다.[224] 사후심제는 항소심구조의 한 형태로 항소심에서는 원칙적으로 새로운 소송자료의 제출을 제한하고 제1심에서 제출된 소송자료만을 기초로 제1심 판결의 내용의 당부를 재심사하는 구조인 바, 미국, 오스트리아, 스웨덴 등의 국가의 민사소송법에서 채택하고

---

221) 이러한 설명방법으로는 황한식, 전게논문, 56면 이하; 이두형, 전게논문, 29면 이하.

222) 특허법 제189조 (심결 또는 결정의 취소) 제1항 법원은 제186조 제1항의 규정에 의하여 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유있다고 인정한 때에는 판결로써 당해 심결 또는 결정을 취소하여야 한다. 제2항 심판관은 제1항의 규정에 의하여 심결 또는 결정의 취소판결이 확정된 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다. 제3항 제1항의 규정에 의한 판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.

223) 그 제한에 대하여는 황한식, 전개논문, 57면, 첫째, 특허신청인은 PTO절차에서 제출되지 않았던 새로운 증거는 제출할 수 있으나 새로운 주장에 대해서는 PTO절차에서 주장하지 못하였던 것에 정당한 이유가 없는 한 허용되지 아니한다. 둘째, 새로운 증거의 경우에도 특허신청인의 부주의와 태만으로 인하여 PTO절차에서 제출하지 못한 경우에는 심리를 하지 아니한다. 셋째, PTO심결이 명백하게 잘못되었다고 보여 지지 않는 한 컬럼비아지구 연방지방법원은 PTO심결이 올바른 것으로 추정한다. 이 범위에서 새로운 주장 및 그 증거는 제출의미가 퇴색되고 만다.

224) South Corp. v. United States, 690 F. 2d 1368 (Fed. Cir. 1982).

있다.[225] CAFC는 미국의 일반 항소법원과 마찬가지로 특정한 심리표준을 내세움으로써 항소심이 속심화 되려는 유혹 또는 노력을 방지하고 있는데 그 중 대표적인 것이 “clearly erroneous standard of review"로서 이는 하급심의 소송기록 자체에 의하여 명백하게 잘못된 것이 없는 한 하급심의 판단은 존중된다는 것이다. 법률문제에 관하여 CAFC는 합리적인 이유가 있으면 PTO 항고부의 심결을 존중하여 달라는 PTO의 주장을 받아들이지 않는다.[226] 단지 심결의 과정에서 정확한 법적용이 있었는지 여부를 심사하고 있다. CAFC는 PTO에서 이미 제출된 증거만을 기초로 사실인정에 관한 판단을 하여야 하고 항소이유에 의하여 제기된 문제점만을 판단한다.[227] 양 당사자는 CAFC소송단계에서 새로운 증거를 제출할 수 없으며 PTO측 소송수행자가 내세우는 거절결정에 대한 새로운 이유나 항소인으로부터 PTO단계에서 주장하지 않았던 새로운 주장도 심리하지 아니한다.

결국 컬럼비아 연방지방법원과 달리, 연방순회항소법원(CAFC)은 사후심의 역할만 하여 심판단계에서 이미 이루어진 주장과 이에 제출된 증거만을 기초로 사실인정에 관한 판단을 하며 새로운 주장이나 증거는 심리하지 않는다고 하겠다.

2) 일본

심결취소소송의 경우에서 사실심리의 제한은 없고 일반 행정처분에 대한 처분소송과 마찬가지로 처분에 수반하는 일체의 하자를 다툴 수 있다는 무제한설과 심결취소소송에 심판전치구조가 채용되어 있다는 점에 의미를 부여하여 사실심리의 범위를 제한하려고 하는 제한설이 있다.

(1) 무제한설

특허심결취소소송의 소송물은 심결에 존재하는 위법성 일반으로 파악하여 행정처분에 대한 항고소송과 마찬가지로 사실심리의 범위에 대한 제한이 없고 당사자는 심결례 포함되지 않았던 일체의 위법사유를 주장·입증 할 수 있고, 법원도 이를 채용하여 판결의 기초로 할 수 있으며, 새로운 증거를 포함한 일체의 증거를 제출할 수 있다는 견해이다.[228] 이 견해에 의하면 심결취소소송에 있어서 소송물은 심결에 존재하는 위법성 일반으로 파악하여 법원에서의 사실상의 제1심인 특허심결취소소송에서의 사실심의 심리에 제한이 없고, 일반 행정소송과 마찬가지

---

225) 전경애, 특허쟁송제도의 연구 -심결취소소송의 심리범위를 중심으로-, 한남대학교대학원석사학위논문, 71면.

226) McCarthy, 763 F.2d 411 (Fed. Cir. 1985).

227) 35 U. S. C. A. § 144.

228) 무제한설에 대한 일본의 소개로는 전병서, 일본의 특허심결취소소송의 심리범위에 대한 고찰, 인권과 정의 (1997. 10), 78면 이하.

로 처분에 수반하는 일체의 하자를 다툴 수 있다는 입장을 의미한다.

제한설에 의하여 비판되어지는 심결의 성질, 법관의 부담, 심판제도의 구조와 운영상의 문제, 전심판단의 경유할 이익 등의 비판에 대하여, 어떠한 이유도 법원에 의한 행정처분의 전면심사라는 헌법상의 대원칙에 대한 예외를 인정할 충분한 근거가 되지 못한다고 주장한다.[229]

(2) 제한설

심결취소소송에 심판전치구조를 취하고 있는 점에 특별한 의미를 두어 심리판단의 대상을 제한하려는 견해로 제한의 범위, 제한의 근거 등에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.

첫째, 실질적 증거법칙 유추적용설을 들 수 있다. 실질적 증거의 법칙이란 특수한 전문기술이 필요한 행정분야에 대하여 행정기관의 사실인정에 관한 판단이, 그 절차에서 제출된 자료에 기하여 이성적인 인간이 합리적으로 판단하여 도달할 수 있는 것이라고 인정되면 법원이 이에 구속된다는 것이다.[230] 영미법계에서 발전된 이론으로, 1930년대 이후 자본주의 경제의 급속한 발전으로 행정권이 확대되고 행정청의 전문화가 이루어지자 법원이 전문적인 영역에서 사법기능을 제대로 수행하지 못하게 되므로, 기술적인 사항에 대하여 행정청이 준사법권을 행사하게 된 것이다. 그러므로 행정기관에 의하여 실질적 증거에 의한 사실인정이라고 판단되는 한, 법원은 심결의 사실인정에 구속되고 그 결과 법원은 원칙적으로 소송절차에서 새로운 증거를 제출하는 것은 허용되지 않게 된다.[231]

둘째, 동일법조설이 그것이다. 심판절차에서 제출된 주장과 증거, 즉 심결이 판단의 기초로 한 사항에 한하여 법원이 심리할 수 있다는 견해이다.[232] 심결취소소송에서 동일권리에 대하여 동일한 요건을 이유로 하는 특정한 사실 즉, 법조에 규정되어 있는 특정한 거절이유 또는 무효원인의 범위를 넘어서 심판에서 쟁점으로 되지 않았던 다른 법조에 규정되어 있는 거절이유 또는 무효원인에 대하여 심리할 수 없지만, 동일한 법조의 범위 내라면 새로운 주장도 증거제출로 허용된다는 입장이다.

셋째, 동일사실·동일증거설을 들 수 있다. 심결의 이유에서 판단이 된 주장과 증거에 한하여 법원이 심리할 수 있다는 견해이다. 이 견해는 심결취소소송을 심판에 대한 사후심으로 보는

---

229) 本間 崇, 심판과 심결취소소송의 관계, 일본공업소유권법학회연보 제6호(1983), 126면 이하.

230) 兼子一, 심결의 사법심사, 소송과 재판, 457면 이하.

231) 이러한 입장에 대하여, 瀧川叡一, 特許訴訟における事實審理の制限, 법조시보 제26권 3호 (1974. 3), 387면 이하, 심판절차가 사법적 절차에 준한다고 하나 행정관료에 의한 행정청의 판단이라는 점에서 다른 사법절차에 준할 정도로 공정한 것으로 볼 수 있는지에 의문을 제기하기 점이 있고, 또한 명문의 규정도 없이 심결취소소송에서 이를 유추적용하여 법원에 의한 새로운 증거조사를 전면적으로 제한하는 것은 타당하지 않다고 비판을 제기한다.

232) 失野邦雄, 최고재판소판례해설 민사편(상), 일본법조회(1968), 335면.

견해로서, 심판의 준사법적 절차성 및 심판전치와 심급생략제도에 비추어 심결에서 판단되지 아니한 특허요건을 법원에서 판단하는 것은 심결서에 이유를 붙이게 한 취지를 무의미하게 한다고 비판한다.[233] 더 나아가 당사자의 전심경유의 이익을 박탈하는 결과를 야기한다고 주장한다.[234] 결국 이 견해는 특허청과 법원의 권한분배의 사상을 기초로 하고 있다고 볼 수 있는데, 특허부여의 여부 및 특허효력의 유무의 종국적 판단은 특허청의 권한이고 법원은 단지 특허청이 이미 심판을 행한 특허부여의 당부 및 특허효력의 유무만을 판단하여야 한다는 입장으로 일본의 다수설이다.

(3) 판례의 추이

초기 일본 최고재판소는 "원심이 사실심인 이상 심판시에 주장되지 않았던 사실, 특허청이 심결의 기초로 하지 않았던 사실을 당사자가 취소소송에서 주장하는 것은 위법이 아니고, 이러한 사실을 판결의 기초로 채용하는 것도 위법이 아니다"라는 입장인 무제한설을 취하였다.[235]

그 후 최고재판소는 등록상표무효심판 심결취소소송에서, "본건 무효심판에서의 쟁점은 상고인의 상표가 구 상표법 제2조 제1항 제9호, 제11호에 위반하여 등록되었는지 여부이고 위 쟁점에 관계되는 한 소송의 단계에서도 공격방어방법으로서 새로운 사실상의 주장이 허용되지 아니하는 것은 아니다"라고 판시하여 동일법조의 범위 내라면 새로운 주장과 입증이 허용된다는 제한설 중의 동일법조설의 입장을 취하였다.[236]

1976년 3월 10일 선고된 최고재판소의 판결에 의하여 심리범위에 대한 논쟁에 종지부를 찍었다.[237] 이 대법정판결은 종전의 판례를 변경하고 동경고등재판소의 실무를 추인함으로서, 심결취소소송의 심리대상을 심판절차에서 심리판단된 특정의 무효원인에 제한한다고 판시하였다.[238]

이후 최고재판소 판결은 모두 위 1976. 3. 10. 대법정 판결의 입장을 따르고 있다. 다만 보완적인 증거로서 새로운 증거 제출을 인정하거나[239] 주지의 기술임을 입증하기 위하여 특허청의 심판단계에서 철회된 증거를 법원에서 새로 제출하는 것을 인정한 예[240]가 있다. 이러한

---

233) 高林克巳, 특허소송- 그 이론과 실무, 사단법인 발명협회 (1991), 147면.

234) 瀧川叡一, 特許訴訟における事實審理の制限(하), 법조시보 제26권 제4호 (1974. 4), 595면 이하.

235) 최고재판소 1953. 10. 16. 판결. 최고재판소 민사판례집 10호, 189면 참조.

236) 최고재판소 1960. 12. 10. 판결, 최고재판소 민사판례집 14권 14호, 3103면; 같은 입장으로는 최고재판소 1968. 4. 4. 판결, 최고재판소 민사판례집 22권 4호, 816면.

237) 1976(소화 51). 3. 10. 대법정 판결.

238) 이는 제한설 가운데서 심리사실·동일증거설의 입장에 속한다.

239) 최고재판소 1976. 4. 30. 판결.

240) 최고재판소 1979. 6. 21. 판결.

최고재판소의 입장에 따라 새로운 주장·입증의 가부에 관하여 판단한 사례로는

① 무효심판절차에서 인용되지 아니하고, 명시적 또는 묵시적으로도 심결의 판단기초로 되지 아니한 기술사항은 그것이 주지의 것이라도 취소소송에서 주장할 수 없고,[241]

② 심결절차에서 현출되지 아니한 증거에 의해 용이창작성을 주장·입증하는 것은 허락되지 아니하며,[242]

③ 심판절차에서 현출되지 아니한 증거는 새로운 증거로 제출하는 것은 원칙적으로 허락되지 않지만, 당업 기술자에게 당연한 주지관용사항에 관하여 취소소송단계에서 보충적으로 새로운 자료를 제출하여 입증하는 것은 허락된다고 판례[243]는 존재하는바, 일본 판례는 제한설의 입장에 있다고 하겠다.

3) 독일

연방특허법원은 특허청의 결정을 사실인정의 면에서나 법률적인 면에서나 심사할 수 있는데, 당사자의 주장 또는 증거신청, 자료에 구애되지 아니하고 당해 사항을 직권으로 조사하게 된다.[244] 특허청 소송수행인이 심결이 이유로 한 사실이나 법률과 다른 사실이나 법적인 근거를 제시한다면, 법원은 심결에서 언급되지 아니한 다른 이유를 들어 심결취소소송을 기각할 수 있고, 특허신청인도 특허청의 소송 수행자 역시 특허청이 이유로 든 사실이나 법률과 다른 사실이나 법적 근거를 제시할 수 있다.[245]

특허에 대한 무효심판을 인정하고 있는 우리 법제와 달리 독일의 특허청은 무효신청에 대하여 관할권이 없다. 원고는 무효사유와 증거를 들어 연방특허법원에 소를 제기하여 순수한 사법적 심사를 받는다. 여기서는 특허청의 행정처분에 대한 취소나 변경을 구하는 것이 아니라 특허권자를 상대로 하여 특허청이 창설한 배타적 사권의 존부를 다투는 것이다. 연방특허법원 항고부에 항고를 제기하는 것과 달리 무효부에서는 특허권자의 특허권리자로 등록된 자를 상대로 하여 완전히 독립적인 소가 제기되는 것이다.[246] 이에 따라 항고부에서의 소는 특허허여절차의 속행절차와 전혀 독립된 것이며, 그 결과 원고의 소제기 여부나 여타의 무효사유와 증거

---

241) 동경고등재판소 1981. 9. 30. 판결.

242) 동경고등재판소 1984. 7. 26. 판결.

243) 동경고등재판소 1986. 3. 12. 판결.

244) 독일 특허법 제87조와 제88조 참조할 것.

245) Georg Benkard, Beck`sche Kurz Kommentare Patentgesetz, C.H.Beck(1993), 1024면 이하를 번역하여 소개한 것으로 황한식, 전게논문, 59면을 참고하기 바람,

246) 독일 특허법 제81조 제1항.

의 제출이 제한되는 일은 있을 수 없다. 다만 독일 특허법은 무효소송의 제소기간에 제한을 두지 않으면서도, 이의 절차가 가능하거나 또는 계속 중일 때에는 무효소송을 제기할 수 없게 하여 특허청의 전문성을 존중하는 조치를 강구하였다.[247] 특허무효소송 경우에도 직권탐지주의가 적용됨은 항고부와 마찬가지이다. 이에 따라 법원은 무효소송절차에서의 피고의 자백에 구속되지 아니한다. 연방특허법원 무효부의 판결에 대해서는 연방대법원에 항소할 수 있다.[248] 독일특허청의 결정에 대한 항고인 경우는 연방특허법원에서 특허신청인이나 특허청 모두 새롭게 주장과 입증을 할 수 있고, 위 연방특허법원의 판결에 대한 불복은 연방대법원에 항소할 수 있으며 당사자는 위 연방대법원에서 새롭게 주장과 입증을 할 수 있다.

4. 개선방향

특허심판원의 특허심판이 특허법원의 심결취소소송에 대한 관계에서 이를 원 행정처분으로 보는 입장도 있지만, 전심으로 보는 것이 타당하다. 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 특허심판절차는 이른바 준사법절차로서 소송절차에 준하는 엄격한 절차에 따르게 된다.[249] 일반 행정심판이 일반행정소송에 대하여 임의적 전치절차임에 반하여 특허심판은 심결취소소송에 대하여 필요적 전치절차에 해당하는 것이다.

둘째, 제도의 연혁상 특허심판원이 사실상 고등법원급인 특허법원에 대해 제1심 역할을 있다는 점이다.

셋째, 특허심판은 산업재산권 분야에 관한 전문성이 요구되는 특수한 행정심판으로서 당사자의 심급의 이익을 박탈한 이유가 없다는 점이다.

요컨대, 특허심판은 비록 행정청이 하는 처분의 성질을 갖고 있지만, 헌법 제107조 제3항의 명령에 따라 소송절차에 준하는 엄격한 절차에 따라 수행된다. 또한 특허심판은 일반 행정심판과 달리 특허법원에서 다루어지기 전에 반드시 거쳐야만 하는 필요적 전치절차라는 점을 간과해서는 아니 될 것이다. 특허법원이 사실심을 할 능력이 된다고 해서 이것이 곧 당사자의 심급의 이익을 박탈할 이유가 될 수 없으며, 심판과 항고심판이 심판으로 통합되고 고등법원급인 특허법원이 신설되게 된 연혁적인 이유와도 부합되지 않는다. 특허심판을 실질적으로 무의미하게 만들어서 당사자들로 하여금 특허심판을 소홀히 하게 하고 특허법원으로 몰리게 하여 실질적으로 행정부의 권한을 침해하고 법원의 부담을 가중시키는 결과를 초래하는 것은 바람직하

247) 독일 특허법 제81조 제 2항.

248) 특허법 제110조 1항 1호 참조.

249) 헌법 제107조 제3항: 재판의 전심절차로서 행정심판을 할 수 있다. 행정심판의 절차는 법률로 정하되, 사법절차가 준용되어야 한다.

지 못하다.

상당한 기술적 전문가인 심판관제도를 포함한 심판절차가 법정되어 있으며, 심결에 이유를 설시하도록 하는 법문의 취지, 특허법만이 가지고 있는 독특한 심사제도와 심판제도 및 그 절차를 규정하게 된 배경과 특허전문 집단으로부터 심판받을 전심경우의 이익에 비추어 특허심판원의 심결에 준사법적 기능을 부여하고 사실상 특허법원의 전심으로서 역할을 하고 있는 현실을 받아들여야만 할 할 것이다. 특히 특허처분에 관한 소송의 심리범위에 있어서 각국의 학설, 판례가 서로 상이한 모습을 띠고 있지만 대략적으로 무제한설에서 제한설로 변화하고 있다는 사실을 주목해야 한다. 이는 법률시장의 개방으로 인하여 우리에게 주는 중요한 시사점이라 하겠다. 심결취소소송의 심리범위를 제한하는 각국의 태도는 발명에 대한 기술적 판단의 곤란과 특허의 특수성을 감안하여 전문기관의 심판이라는 독특한 구조를 마련하여 과학의 발전에 대응하려는 노력이라고 할 수 있다. 고도의 기술적 판단이 요구되는 특허영역에서 심결취소소송의 심리범위를 제한하여야 한다는 것은 시대적 요구라 사료된다. 대부분의 나라가 심결취소소송의 전심절차로서 특허심판을 인정하여 사후심구조를 유지하고 있는 이유로서 특허심판의 전문성, 심결취소소송의 특수성, 심결취소소송절차 문제 등을 다루고 있다는 점에서 우리나라 역시 심결취소소송을 사후심구조로 파악하는 것이 국제화시대에 부응하다고 할 것이다.

제 4 장

법률개방화로 인한 지재권 분야의 기타문제

Ⅰ. 변리사와 변호사의 공동대리

1. 논의 배경

각 국가마다 고유의 사법제도를 운용하고 있고, 또한 대리인제도 역시 이에 따라 다양한 형태로 존재한다. 예를 들어 미국은 영미법계 국가로서 법원에서의 판결이 법원(法源)이 되고 또한 연방제 국가이므로 주 단위마다 그 특성에 맞는 주법과 사법기관이 연방 단위의 그것과 함께 공존한다. 반면 독일·일본 및 우리나라와 같은 대륙법계 국가에서는 성문법주의를 취하고 법원의 판결은 법원(法源)이 되지 아니한다는 것이 일반적인 견해이다.

특히, 지적재산권 분야 대리인의 예를 비교해 보면 미국은 로스쿨을 졸업하고 변호사 시험(Bar-exam)에 합격한 자가 "변호사"(Attorney)로서 활동하게 되는데 이들은 상표 출원업무를 대리하는 이외에는 법원에 대하여만 대리권이 있으며, 이공계 학위자 등 일정 자격자로서 미국 특허청(USPTO)에서 시행하는 시험에 합격한 자 및 심사관으로서 4년 이상 종사한 자는 "특허변리사"(Patent Agent) 자격을 취득하고 특허청에 대하여만 특허 및 디자인에 대하여 대리할 수 있다.[250] 한편 양 자격을 모두 가진 "특허변호사"(Patent Attorney)만이 지식재산권에 관한 모든 법률행위와 관련한 대리 등을 할 수 있는 것이다. 반면에 우리나라의 경우 "변호사"(辯護士)는 지식재산권 전반에 걸쳐 법원에 대한 대리행위가 인정됨은 물론, 소위 자동자격부여 규정에 의거 변리사 등록을 하면 특허청에 대한 출원, 특허심판원에의 심판수행 대리 등 "변리사"(辨理士)의 직무까지 모두 행할 수 있는 상황이다.[251]

국제거래의 활성화에 따라 지재권 등 여러 분야에서 법률수요가 증가하고 있어 다양한 법률서비스 공급이 필요한 상황이나, 국가별로 인정되는 대리인의 종류 및 직무범위가 다르므로 개방이 이루어져 다양한 형태의 각국 대리인이 국내에 진입하는 경우 각 국가에서 인정하는 직무범위에 기해 활동영역의 광협(廣狹)이 결정될 수 있는 등 개방과 관련하여서 검토해 볼 여지가 있다.

---

250) 정상조, 특허법원의 운영방안, 지적재산권 논문집 (대한변리사회 제5집 1998), 163면.

251) 변리사법 제3조 제1항 제2호.

2. 단독소송대리에서 공동소송대리의 방향으로

1) 실정법의 고찰

변리사법 제2조에 의하면 “변리사는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관하여 특허청 또는 법원에 대하여 하여야 할 사항의 대리 및 그 사항에 관한 감정 기타의 사무를 행함을 업으로 한다”라고 규정하고 있고, 동법 제8조에서는 “변리사는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항에 관하여 소송대리인이 될 수 있다”고 규정하고 있다. 또한 변호사법 제3조에 의하면, “변호사는 당사자 기타 관계인의 위임 또는 국가·지방자치단체 기타 공공기관의 위촉 등에 의하여 소송에 관한 행위 및 행정처분의 청구에 관한 대리행위와 일반 법률사무를 행함을 그 직무로 한다”고 규정하고 있다. 1998년 3월 특허법원이 생기면서 변리사의 소송대리영역에서 다툼이 있어왔다. 특허법원이 생기기 이전에는 특허청 상고심판소에서 현재 특허법원이 심리하는 심결취소에 관한 분쟁을 대리하였기 때문에 문제되지 않았다. 항고심판에 불복하여 대법원에 상고되는 사건도 변리사가 직접 수행하였으나 사건 수가 미미한 관계로 다툼으로 비화되지는 않았다. 이 밖에도 특허청장이 행한 행정처분에 대한 불복을 다투는 행정소송도 변리사가 직접 대리한 바 있다.[252]

특허법원이 생긴 이후에도 특허법원에서 심리하는 심결취소소송 및 이에 불복하여 대법원에 상고되는 사건에 있어서는 크게 다툼이 없으나, 특허침해소송에 있어서는 위 변리사법 제8조를 둘러싸고 논쟁이 있다. 변리사는 주지하다시피 특허와 관련된 국가행정을 담당하고 있는 특허청과 특허법원을 중심으로 하여 발생하는 법률문제를 대리하는 것을 직무로 하는 법률전문가이다.

변리사법 제8조에 의하면 변리사는 특허 등에 관한 사항에 대하여 소송대리인이 될 수 있게 되어 있다. 동 규정에 의하여 변리사는 특허와 관련된 사안에 대해 소송대리권이 갖고 있기 때문에, 변리사는 특허와 관련된 사안에 대해 소송대리권이 인정된 법률전문가인 것이다. 결국 변호사의 직무영역이 일반적이고 포괄적인 법률사무를 담당하는데 비하여, 변리사의 직무영역은 특허와 관련된 기술분야를 전문적으로 담당하는 법률전문가라고 볼 수 있다.[253] 우리 변리사법은 특허 등에 관하여 변리사는 소송대리를 할 수 있다고 포괄적 규정을 두고 있다. 하지만 현행 민사소송법 제87조는 소송대리인의 자격을 규정하고 있는바, 동조에 의하면 법률에 따라 재판상 행위를 할 수 있는 대리인 외에는 변호사가 아니면 소송대리인이 될 수 없게 된다. 실무상 심결취소소송의 경우에는 변호사와 변리사가 모든 소송대리를 하고 있으나, 특허침해소송

252) 이용우, 지적재산권의 중요성에 비추어 본 지적재산권소송제도의 문제점, 법조 (2004. 1), 136면 이하를 참조할 것.

253) 이승우, 특허침해소송에 있어서 변리사의 소송대리권 불인정의 부당성, 법학논총 제6호, 15면.

에 대한 소송대리는 변호사가 하고 있기 때문에 학자들의 견해가 나누어지고 있다.[254]

2) 반대하는 입장

변리사가 특허분야의 전문가라는 것을 인정하면서도 특허침해소송에서 소송대리를 인정하지 않으려는 입장은 다음과 같다.

우선적으로 침해소송과 심결취소소송을 분리하여, 침해소송은 심결취소소송과는 달리 민사소송에 해당하므로 변호사만이 할 수 있다는 것이다.[255] 즉 변리사가 특허법원의 심결취소소송 대리권을 인정받았다는 이유로 특허침해소송에 대하여도 소송대리권을 주장하는 것은 무리라는 것이다.[256] 변리사에게 민사소송에서의 소송대리권을 인정하는 것은 자격시험제도를 두어서 자격시험에 합격하고 소정의 연수를 마쳐야만 당해 분야에서 업무를 수행할 수 있도록 하는 자격제도의 취지에 비추어 보아도 부당하다는 것이다. 변리사는 구두변론주의가 적용되는 민사법정에서 구두변론 소송절차에 관한 법적 지식과 증거법에 대한 전문지식 등 일반소송을 대리하기 위한 전문적인 법률교육과 연수를 받은 소송전문가는 아니므로 소송대리권을 인정할 수 없다고 한다. 특허침해소송과 같이 민사소송법에 따라 처리되는 소송에서 전문적 법률지식이 취약한 변리사에게 소송대리권을 부여하면 소송당사자의 권익침해와 함께 소송지연이 초래된다는 것이다.

민사소송법 제87조에서 “법률에 의하여 재판상의 행위를 할 수 있는 대리인”이라 함은 법률상 대리인을 의미하는 것이고, 변리사와 같이 그 때 그 때 사건을 수임하여 처리하는 대리인을 말하는 것이 아니라는 주장이 있다. 또한 변호사도 관련 발명에 대한 지식을 갖고 있는 전문가 또는 변리사의 도움을 받으면 사실판단, 발명의 신규성, 진보성 여부 및 특허침해여부를 판단할 수 있는 능력을 가질 수 있다고 주장한다. 독일의 입법례에서도 특허 등 심결취소소송이 아닌 특허침해소송에서는 변리사에게 소송대리권을 부여하지 않고 있는 점을 들면서, 비교법적인 관점에서 변리사의 소송대리권을 인정하지 않으려 한다.

3) 찬성하는 입장

특허침해소송에서 변리사의 소송대리인이 인정되어야 한다고 주장하는 논거는 다음과 같다.

첫째, 민사소송법 제87조가 소송대리인의 자격에 대하여 “법률에 의하여 재판상 행위를 할 수 있는 대리인”이라 하고, 변리사법 제8조에서 “변리사는 특허·실용신안·디자인 또는 상표에

254) 특허청, 특허침해소송 공동대리 설명자료, 2005. 7, 2-3면.

255) 이점을 설명하고 비판한 것으로는 이용우, 전게논문, 136면.

256) 비판적인 입장으로는, 전상우, 특허침해소송대리제도의 개선방안, 지식재산권법연구회, 554면,

관한 사항에 관하여 소송대리인이 될 수 있다"고 규정하고 있으므로 해석상 당연히 특허침해소송에서도 소송대리를 할 수 있다는 것이다[257]. 기술을 잘 아는 변호사는 흔치 않으므로 기술을 쉽게 이해하지 못하는 변호사를 소송대리인으로 선임할 가능성이 큰데, 특허침해소송의 대상은 기술이므로 사실의 확정과정에서 소송당사자가 설명을 해 주더라도 쉽게 이해할 수 없으며, 또한 재판부에 소송당사자가 전달하고자 하는 사실 설명도 대리인에 의해 원활하게 이루어지지 않을 수도 있다는 점을 간과해서는 안 될 것[258]이라고 한다.

둘째, 재판청구권은 소송절차에서 도와 줄 사람의 선택 자유권을 포함한다. 특허소송 수요자가 변리사의 도움을 선택하려 해도 법으로 변호사만의 선택을 강요하고 있는 이상 이것은 국민의 재판청구권을 제한하는 것이어서 위헌적 발상이라는 것이다.[259] 현행 변리사법의 해석상으로도 변호사를 배제하고 변리사만이 소송대리를 하자는 것이 아니라 침해소송에 관하여 변리사도 소송대리를 할 수 있게 하여, 국민이 선택의 자유를 가져야 한다는 것이다. 국민의 선택 자유권을 제한하려면 그 제한에 어떤 공익적 이유가 뚜렷해야 함에도 불구하고 "특허소송의 대리에 관하여 전문성을 갖추고 있는 변리사"의 선택을 금지하고 변호사만을 선택하게 하는 제도는 국민의 권리에 대한 부당한 제한이 아닐 수 없다는 것이다. 특허침해소송에서 제기된 사안이라면 소제기를 전후하여 권리범위확인심판이나 무효심판을 청구하게 되고, 이들 심판의 심결에 불복하면 심결취소소송으로 이어지게 되는 것이 상례이다. 이들 심판이나 심결취소소송은 절대다수를 변리사가 대리를 하며 특허권 등의 권리형성과정에서도 변리사가 관여하게 되어 있다. 그런데 유독 특허침해소송에서만은 변리사의 관여가 배제되고 변호사만 소송대리를 하게 되어 있다. 이 경우 변호사에게 다시 특허발명의 내용이나 상대방이 침해기술 등을 이해시켜야 하고, 그래도 부족한 경우에는 변리사가 재판의 뒷전에서 변호사를 도와야 하는데 이것은 소송당사자에게 대단한 불편과 부담을 주는 제도라는 것을 잊어서는 아니 된다.[260] 오히려 특허침해소송에서 변리사의 소송대리를 필요로 하는 것은 특허전문가이자, 특허권의 형성과정에 참여하여 보다 많은 내용을 알고 있는 변리사에게 연속하여 대리하게 하는 것이 당사자를 더욱 두텁게 보호할 수 있다는 취지인 것이지, 기득권의 유지나 확대를 위한 방편이 아니라는 주장이다.[261] 누구에게 소송을 위임할 것인가는 전적으로 이해관계가 가장 큰 당사자의 판단에 맡겨두어야 할 것이다.

셋째, 관할의 일원화를 주장하면서 소송대리권을 부인하는 논리적 모순을 지적하지 않을 수 없다.[262] 지식기반 사회로 급속히 변모해 가는 21세기를 눈앞에 두고 시의 적절하게 설립된

257) 전상우, 전게논문, 553면.

258) 김성기, 특허쟁송제도의 개선방안, 특허심판원 개원 5주년 기념 세미나 자료집, 특허심판원 (2003), 136면.

259) 이영필, 특허법원의 관할 집중과 변리사 소송대리권, 산업재산권 (1999년 5월), 90면.

260) 같은 의견으로는 이상정, 특허쟁송제도의 개선방안, 106면.

261) 이용우, 전게논문, 137면.

262) 이인정, 특허쟁송제도 개선방안에 대한 고찰, 특허심판원 개원 5주년 기념 세미나 자료집, 특허심판원(200

특허법원이 특허재판 전문법원으로 자리 잡게 된 이유는 재판부의 전문화, 특히 기술심리관의 재판에의 참여와 변리사의 소송대리에 힘입은 바가 크다. 특허소송이 과학기술과 법률이 결합된 특수한 형태의 전문소송으로 정착·발전되어 가고 있는 이때에, 특허법원에서의 소송대리의 압도적 다수를 차지하고 있는 변리사로 하여금 특허침해소송에 있어서 소송대리인이 될 자격을 박탈하는 내용의 민사소송법 개정시도는 특허법원의 설립취지를 정면으로 부인하는 것이며, 특허침해소송사건을 특허법원에 관할집중하는 주장과도 논리적 모순이라는 것이다.

이와 같은 근거로 변리사의 기술지식과 변호사의 소송수행능력을 조화시킬 수 있으며 소송당사자의 선택권을 보장해 준다는 측면, 그리고 특허법원의 설립취지를 보더라도 변호사와 공동으로 특허침해소송을 대리할 수 있도록 하는 것이 바람직하다고 주장한다.

3. 주요국에서의 논의

1) 미국

변리사의 업무영역과 관련하여, 미국에서는 특허변리사(Patent Agent)와 일반변호사(Attorney), 그리고 특허변호사(Patent Attorney)로 구분된다.[263]

미국에서는 변리사 시험에 합격하거나 특허청에서 심사업무에 4년 이상 종사한 자에게 특허변리사(Patent Agent)의 자격을 부여한다. 변리사시험에 응시하기 위해서는 대학에서 자연과학 또는 공학을 전공해야 한다는 응시자격의 제한이 있다. 변리사 시험과목은 특허법 및 실무·청구범위작성·청구범위해석 등이다. 특허변리사는 특허청에 대한 전반적인 절차에 대하여 대신할 권리를 가지나 법원에서 소송을 대리할 수는 없다. 일반변호사 자격을 갖지 않은 특허변리사는 특허청에 대한 특허 및 디자인에 관한 모든 업무를 대신할 수 있다. 다만, 상표에 관한 업무는 대리할 수 없고, 실시권 계약서도 작성할 권한이 없다. 특허변리사는 법원에 대항 특허에 관련된 소송을 대리할 수 없지만, 법원에서 전문가로서 증언을 할 수는 있다. 특허변리사는 특허청에 대하여 특허에 관한 출원, 항고심판 등을 대리할 수 있으며 법원에 대하여 대리할 수 없다[264].

한편 일반변호사(Attorney)는 로스쿨을 졸업하고 변호사 시험에 합격한 자를 말한다. 대부분의 주에서는 3년제 대학원 과정의 법과대학을 졸업한 후 각 주에서 시행하는 변호사 시험에 합격하면 변호사 자격을 취득할 수 있다. 일반변호사는 특허와 관련하여 법원에 대하여 소송을 대리할 권한은 가지나, 특허청에 대한 특허와 디자인에 관한 대리권은 부여되어 있지 않으나,

---

3), 125면 이하.

263) 정상조, 특허법원의 운영방안, 지적재산권 논문집 제5집, 대한변리사회,163-164면.

264) 전상우, 특허침해소송대리제도의 개선방안, 지식재산권법의 제문제, 지식재산권법연구회, 549면.

상표 출원업무는 일반변호사에 의해서도 가능하다.

이와는 달리 특허변리사의 자격과 일반변호사의 자격을 갖춘 자를 특허변호사(Patent Attorney)라고 한다. 그는 이공계 대학을 졸업해서 변리사 시험에 합격하거나 특허청에서 4년 이상 근무하여 특허변리사 자격이 있으면서, Law School을 졸업하여 변호사 시험에도 합격한 자를 말한다.[265]

일반변호사는 특허와 관련하여 모든 법원에 대하여 소송을 대리할 권한을 갖지만, 특허청에 대하여는 특허업무를 대리할 수는 없다. 하지만 특허변호사는 상기한 모든 업무를 대리할 수 있는 권한을 갖는다. 실질적으로 특허소송의 선기술적 실체파악과 후법률관계의 적용이라는 측면에서 특허소송은 기술적 지식과 법률적 지식을 모두 겸비한 특허변리사에 의해 소송대리가 행해지고 있는 것이 일반적인 추세라고 한다.[266]

<표-> 미국 특허변호사와 특허변리사의 비교

구 분	자 격 요 건	직 무 영 역
Patent Attorney	○ Attorney 자격 + Patent Agent자격	○ 지식재산에 관하여 모든 법률 서비스 가능
Patent Agent	○ 일정한 시험응시 자격자로서 PTO의 시험 합격 ○ PTO 심사관으로 4년 이상 종사자	○ PTO에 대하여 특허·의장에 관한 사항 대리
Attorney	○ 일반적으로 로스쿨을 졸업하고 변호사 시험에 합격한 자	○ PTO에 대하여 상표에 관한 사항 대리 ○ 법원에 소송대리

2) 일본

일본에서는 변리사시험에 합격한 자, 특허청 공무원으로서 일정한 경력을 갖춘 자 및 변호사에 대하여 변리사의 자격을 인정하고 있다. 변리사는 심결취소소송에서는 단독으로 소송대리인이 될 수 있으며, 특허침해소송에 있어서는 변호사와 함께 공동소송대리인이 될 수 있다. 원래 일본에서는 특허, 실용신안, 의장 또는 상표, 국제등록출원, 회로배치 또는 특정부정경쟁에 관한 사항에 대하여 재판소의 보좌인으로서 당사자 또는 소송대리인이 스스로 한 것으로 간주하

265) 이상정, 특허쟁송제도의 개선방안, 106면.

266) 전상우, 전게논문, 549면.

였다. 즉 일본 변리사는 산업재산권 관련 심결취소소송에서의 소송대리, 산업재산권과 관련하여 특허청을 상대로 한 절차, 이의제기 등의 대리 및 이와 관련한 사항에 대한 감정 및 기타 사무의 수행을 할 수 있으며, 아울러 산업재산권과 관련된 사항에 대하여 법원을 상대로 '보좌인'으로서 당사자 또는 소송대리인과 함께 출두하여 진술 또는 심문할 수도 있었다.[267] 변리사는 특허법 제178조 제1항, 실용신안법 제47조 제1항, 의장법 제59조 제1항, 상표법 제63조 제1항에 규정된 소송에 관하여 소송대리인이 될 수 있는 것으로 규정하고 있었기 때문에 심결취소소송에서의 소송대리권은 인정하고 있었다. 하지만 침해소송에서는 보좌인의 자격만 인정하고 소송대리인의 자격은 인정하지 않았다.[268]

그런데 일본에서 침해소송의 실태를 조사한 결과 변호사가 대리하는 거의 모든 사건이 변리사에게도 의뢰하여 기술적인 부분의 조언을 받고 있는 것으로 나타남에 따라, 침해소송에 있어서 변호사의 기술적 대응의 부족이 심리 지연의 큰 원인 중 하나로 지적되었다.[269] 이에 변리사가 기술부분을 변호사에게 설명하고 이 설명을 들은 변호사가 재판부에 진술하는 것보다 변리사가 직접 법정에 나와 재판부에 진술하는 편이 재판의 신속화, 충실화에 도움이 될 것이라고 결론을 내렸다.

이에 따라 2002년 4월 17일 일본 변리사법을 개정·공포하여 변리사도 특허, 실용신안, 의장, 상표 또는 회로배치에 관한 권리의 침해 또는 특정부정경쟁에 의한 영업상의 이익의 침해에 관계된 소송인 특정침해소송에 대하여는 일정한 조건 하에 변호사와 공동으로 소송대리를 할 수 있도록 하여 2003년 1월 1일부터 시행되고 있다.[270]

특정침해소송 대리 업무를 할 수 있는 자격은 첫째, 일정한 연수과정의 수료가 필요한데, 이

---

267) 2002년 개정 전 일본 변리사법 제5조 제1항·2항에서는 "변리사는 특허, 실용신안, 의장 또는 상표, 국제출원 또는 국제등록출원, 회로배치 또는 특정부정경쟁에 관한 사항에 대하여, 재판소에서 '보좌인'으로서 당사자 또는 소송대리인과 함께 출석하여 진술 또는 심문할 수 있고, 이 진술 또는 심문은 당사자 또는 소송대리인이 스스로 한 것으로 간주한다"고 규정하여 침해소송에서는 보좌인의 자격만 인정하고 있었다.

268) 전상우, 전게논문, 30면 이하를 참조할 것.

269) 일본 변리사법 제2조(정의) ⑤ 이 법률에서 '특정침해소송'이란 특허, 실용신안, 의장, 상표 또는 회로배치에 관한 권리의 침해 또는 특정 부정경쟁에 의한 영업상의 이익의 침해에 관계된 소송을 말한다.

270) 일본 변리사법 제6조의2(업무) ① 변리사는 제15조의2 제1항에 규정한 특정침해소송대리업무시험에 합격하고, 제27조의3 제1항의 규정에 따라 그 취지의 부기를 받은 때는, 특정침해소송에 관하여 변호사가 동일 의뢰인으로부터 수임하고 있는 사건에 한하여 그 소송대리인이 될 수 있다. ② 전항의 규정에 의하여 소송대리인이 된 변리사가 기일에 출석하는 때는 변호사와 함께 출석하지 않으면 안 된다. ③ 전항의 규정에 불구하고 변리사는 재판소가 상당하다고 인정하는 때는 단독으로 출석할 수 있다.
동법 제27조의2(특정침해소송대리업무의 부기신청) ① 변리사는 그 등록에 제15조의2 제1항에 규정하는 특정침해소송대리업무시험에 합격한 취지의 부기를 받고자 하는 때에는 일본변리사협회에 부기신청서를 제출하여야 한다. ② 전항의 부기신청서에는 이름 기타 경제산업성령에서 정한 사항을 기재하고 특정침해소송대리업무시험에 합격한 것을 증명하는 증서를 첨부하여야 한다.
동법 제27조의3(특정침해소송대리업무의 부기) ① 일본변리사회는 전조의 규정에 의한 신청을 받은 때는 지체 없이 당해 변리사의 등록에 특정침해소송대리업무의 부기를 하여야 한다.

는 일본변리사회 주관의 강의 및 실습방식의 교육으로 45시간 이상 실시된다.[271] 그 내용으로는 특정침해소송에 관한 법령 및 실무, 특정침해소송의 절차 및 서면의 작성, 소송대리인으로서의 윤리 및 기타 특정침해소송에 관하여 필요한 사항 등이다. 둘째, 소정의 시험에 합격해야 하는 바 특정침해소송에 관한 소송대리인이 되는데 필요한 학식 및 실무능력검정을 위해 민법, 민사소송법, 기타 특정침해소송에 관한 법령 및 실무에 관한 사항에 대해 논문형으로 시행하며 그 주관기관은 공업소유권심의회이다.[272] 따라서 변리사도 특허 등에 관한 권리의 침해 또는 특정부정경쟁에 의한 영업상의 이익에 대한 침해에 관계된 소송, 즉 특정침해소송에 대하여 일정한 조건하에 소송대리를 할 수 있도록 개정하게 되었던 것이다.

<표-> 일본 변리사의 자격 및 직무

구 분	자 격 요 건	직 무 영 역
변리사	○ 변리사시험 합격자 ○ 변호사 자격자 ○ 특허청의 심사·심판관으로 7년 이상 근무자	○ 산업재산권 출원에서 등록까지의 모든 절차대리 ○ 산업재산권 분쟁사건대리

3) 영국

영국의 경우는 특허 및 디자인 분야와 상표 분야를 나누고 다음과 같이 자격을 구분하여 운용하고 있다.[273] 특히 소송 수행과 관련하여서는 영국 특허변리사협회(CIPA)로부터 '소송인가장'을 받은 변리사의 소송수행을 허용하고 있다. 이 소송인가장을 받기 위해서는 3년 이상 특허변리사협회의 정식회원으로 등록된 특허변리사로써 동 협회가 주관하는 소송교육과정을 이수하고 아울러 정식 소송자격을 갖는 자의 지도하에 6개월 이상의 실무수습을 거치면 소송인가장이 부여된다.[274]

소송인가장을 받은 모든 특허변리사에게 특허지방법원, 지방법원, 특허법원 및 항소법원에서

271) 일본변리사회가 2003년 5월부터 9월까지 개최한 제1회 능력담보연수에는 850명의 변리사가 수강하였다. 특정침해소송대리업무시험은 2003년 10월 26일 처음 실시되었는데, 804명의 변리사가 응시하여 그 중 553명이 합격하였고, 제2회 시험은 2004년 10월 24일 실시되어 응시자 970명 가운데 613명이 합격하였다고 한다, 森崎博之, 付記辨理士と企業訴訟, 知財管理 Vol.55, No.3, 2005. 3, 352면. 설범식, 일본 지적재산권 소송제도의 개혁동향, 특허소송연구(제3집), 특허법원, 2005. 12, 409-411면에서 재인용.

272) 일본 변리사법 제15조의2 (특정침해소송대리업무시험) ① 특정침해소송대리업무시험은 특정침해소송에 관한 소송대리인이 되는 것에 필요한 학식 및 능력에 관한 연수로서 경제산업성령으로 정하는 바를 수료한 변리사에 대하여, 당해 학식 및 실무능력을 가지는가를 판정하기 위하여 논문식의 필기시험 방법으로 행한다.

273) 특허청, 특허침해소송 공동대리 설명자료, 2005. 7, 6면. 참고로 프랑스의 경우를 살펴보기로 한다.

<표-> 프랑스 PA·TA의 자격 및 직무

의 특허, 디자인, 기술정보에 관련되는 저작권, 상표사건 등에 대한 소송 수행권(rights to conduct litigation) 부여하고, 또한 지재권 소송에 부수되는 가처분과 관련된 예비심리시 변론권을 행사할 수 있다. 특허관련 소송에 관한 한 사무변호사(Solicitor)와 동일한 자격이 인정되어, 사무변호사와의 공동대리는 필요하지 않으나, 특허법원 이상의 소송시 법정변론권은 없으므로 법정변호사(Barrister)와의 공동대리는 여전히 필수적이다.

<표-> 영국 PA·TA의 자격 및 직무

구 분	자 격 요 건	직 무 영 역
Patent Agent	○ 대학졸업자 또는 동등학력자로써 Patent Agent시험 합격자	○ 특허·디자인에 관해 특허청 및 특허법원에 대한 대리
Trademark Agent	○ 대학졸업자 또는 동등학력자로써 Trademark Agent시험 합격자	○ 상표에 관하여 특허청 및 특허법원에 대한 대리

4) 독일

특허침해소송과 같은 특허분쟁에 관한 제1심은 각 주의 민사법원이며, 이러한 민사법원만이 특허사건을 전담한다.[275] 원칙적으로 하나의 주에 하나의 민사법원에서 특허분쟁사건을 담당한다. 민사법원이 전속 심판권으로 되어 있는 경우에는 민사법원에 등록된 소송담당변호사만이 대리할 수 있으나, 특허분쟁의 경우에는 특허법 제143조 제3항에 의해 심판권법원 이외의 지역 법원에 등록된 소송담당 변호사도 대리할 수 있으며 변리사는 대리권은 없으나 법원에서 진술할 수 있다.[276] 침해소송의 민사소송에 있어 지방법원이상 합의사건부터는 변호사강제주의가 채택되어 있다.[277] 그러므로 특허침해소송을 제기하려는 자는 반드시 변호사에 의해 대

구 분	자 격 요 건	직 무 영 역
Patent Attorney	○ 법대나 공대졸업자, 스트라스부르대학 산업재산권센타(CEIPI) 수료자, 3년간 변리사사무소, 기업체 특허부서 종사자, P·A시험 합격자	○ 특허에 관하여 특허청 대리
Trademark Attorney	○ 법대나 공대졸업자, 스트라스부르대학 CEIPI 수료자, 변리사사무소, 기업체 특허부서 3년간 종사자, T·A 시험 합격자. 전과기록 등 Morality심사	○ 상표·디자인에 관하여 특허청 대리

274) 상기 교육과정은 대학 등 외부 교육기관에 위탁하며, 소송절차, 증거법등 소송관련 실무지식을 습득할 수 있는 과목으로 구성된다.

275) 특허법 제143조 제2항.

276) 독일 민사소송법 제78조 제1항 1호; 독일 변리사법 제4조.

277) 구법원(Amtsgericht) 관할법원사건에는 변호사강제주의가 채택되어 있지 않다.

리되어야 한다. 실무상 대부분의 특허침해소송에서 변호사와 변리사는 한 팀으로 활동하여 변호사는 법률문제를 취급하고, 변리사는 기술문제를 취급하고 있다.

무효소송은 제1심인 연방특허법원에 있어서 독일 국민은 본인소송이 가능하나 외국인은 변호사나 변리사에 의해 대리되어야 한다.[278] 무효소송과 관련하여 독일의 연방특허법원에서의 소송대리는 변호사와 변리사 모두 수행할 권한을 가진다.[279] 하지만 상소심인 연방대법원에 있어서는 독일 국민도 변호사 또는 변리사에게 소송을 위임하여야 한다. 이 경우에는 연방대법원에 등록된 변호사로 하여금 대리하게 하여야 한다.[280] 그러나 변리사는 연방대법원의 구두심리에서는 신청에 의하여 진술할 수 있다. 결국 특허청 및 특허법원에서는 변호사 및 변리사의 대리가 강제조항이 아니므로 발명가가 독자적으로 행할 수 있고, 특허청 및 특허법원에서의 대리는 변리사의 독점권한이 아니며 독일법원에 등록된 변호사로 하여금 대리하게 할 수 있다.

4. 개선방향

변호사와 변리사간 직무영역에 관하여 종래 다투어져 온 것은 주로 특허침해소송에 있어 변리사의 소송대리권을 인정할 것이냐에 그 중심이 맞추어져 왔다. 특허침해소송에서의 변리사 소송대리권에 관하여 현재 전체 심결취소소송의 70% 이상을 소송대리하고 있는 변리사가, 특허침해소송에 관해서는 법원에 따라 가처분사건에 대한 대리권을 인정하고 있는 경우를 제외하고는 소송대리를 하지 못하고 있는 현실이다.

지금까지의 변리사와 변호사간 소송대리권 인정범위와 관련한 견해를 아주 간단히 설명하면 “변리사는 소송절차에 대한 전문가가 아니어서 당사자를 대리해 소송수행을 하기에 부족하다” 거나 “변호사는 기술 분야에 대한 이해가 부족하여 오히려 당사자의 보호에 미흡할 수 있다”라고 표현해도 크게 잘못된 것은 아닌 듯하다.

그런데 변리사는 모두 소송에 대하여 문외한이라는 주장은 받아들이기 어렵다. 민사소송법이 2차 필수과목으로 자리 잡았고 실무수습에서도 교육하고 있으며 이미 특허법원에서의 심결취소소송 대리를 통해 실무적으로도 소송수행을 하고 있다.

그렇다고 “변호사는 모두 기술에 대한 이해가 부족하다”라는 주장 또한 타당하지 않다고 본다. 이공계 출신 변호사가 배출되고 있고 지식재산권 분야로 전문화하기 위해 별도로 이공계 학위과정을 이수하는 경우도 적지 않다.[281]

---

278) 독일 특허법 제25조.

279) 독일 변리사법 제3조 제5항.

280) 독일 연방특허법원에서의 소송대리에 대하여는 정상조, 전게논문, 173면.

281) 현행 사법시험이 향후 법학전문대학원(로스쿨) 체제로 개편되는 것을 전제로, 대한변협이 이공계 출신 변호사가 향후 많이 양성될 것이므로 변리사 제도(법무사, 세무사, 노무사, 관세사 등도 포함)는 폐지되어야 한

그럼에도 불구하고 이는 일부에 불과한 것이라고 주장한다면, 결국 변리사나 변호사 대다수가 기술 및 소송실무 양측 모두에 정통하지는 못하다는 얘기가 될 것이다. 또한 이러한 상황에서는 어느 쪽도 소송대리를 하지 않는 것이 당사자 이익에 부합하게 된다는 비논리적인 방향으로 흐르게 될 것이다. 그런데 실제 기업 입장에서는 특허사건이 기술에 관한 소송임을 감안해 변호사와 변리사를 공동선임하는 경우가 대부분이므로 변리사에게 소송대리권을 함께 공동으로 부여하는 것이 현실에 부합된다고 사료된다. 다만, 여기서 주의해야 할 점은 공동소송을 강제하는 의미가 아니라는 점이다. 이렇게 되면 오히려 분쟁의 당사자에게 큰 부담을 지우는 것이 되고 선택권을 제약하는 것이 되기 때문이다. 결국, 지금과 같이 변호사 단독으로 대리하는 소송형태와 변호사와 변리사가 공동으로 대리하는 소송 형태가 존재하게 될 것이고 이는 당사자의 선택에 따르게 된다는 의미이다.

시간이 가면 갈수록 지식재산권과 관련한 분쟁이 더욱 복잡화·전문화·국제화될 것이고, 더욱이 지적재산권 분쟁의 결과는 기업 등 법률소비자의 성쇠(盛衰)를 가져올 뿐만 아니라 국가경쟁력에도 지대한 영향을 미치게 될 것이다. 이러한 판단 하에 일본을 비롯한 주요 국가들도 공동소송을 다음과 같이 인정하는 추세이다.

<표-> 주요국의 공동소송 인정현황

구분	심결취소소송 대리	특허침해소송 대리	비 고
일본	○	○(변호사와 공동)	특정침해소송 대리업무 자격 : 연수 + 시험과정
영국	○	○(법정변호사와 공동)	소송인가장 취득요건 : 교육 + 실무수습
중국	○	○(실무상 단독)	관련규정 없음 실무적으로 소송대리 인정
미국	변리사 : × 변호사 : △ 특허변호사 : ○	변리사 : × 변호사 : △ 특허변호사 : ○	특허변호사 : 특허변리사 + 일반변호사
독일	○	×	소송당사자의 신청에 의하여 법정진술 가능

대다수의 민사소송법학자들에 의하면, 변리사법 제23조와 제8조의 규정에 의해 민사소송법

다는 의견을 사법제도개혁추진위원회에 제출한 바가 있고, 아니면 마찬가지 이유로 특허침해소송에서 변리사의 대리권을 굳이 인정할 필요가 없다는 견해도 제기된 바 있다.

생각건대, 각 분야가 복잡하게 전문화되는 추세에 이러한 입장이 바람직한 것인지 의문이며, 또한 로스쿨 정원을 1,200명 선으로 제한해야 한다는 등의 주장을 계속하는 한 선진국의 변호사 1인당 국민의 수 등을 살펴보면 설득력이 약하다.

제87조가 규정하고 있는 변호사대리 원칙에 대한 예외로 산업재산권에 관한 소송에서는 변리사도 소송대리인이 될 수 있다는 해석론을 제시하고 있다. 또한 우리의 경쟁국이자 벤치마킹대상인 일본이 최근 변호사·변리사 공동소송대리인제도를 도입한 점, 그리고 법률개방화로 인한 세계수준에 합당한 소송대리제도로써 우리나라 역시 특허침해소송에서 변호사와 공동으로 변리사의 소송대리권을 인정할 수 있도록 하는 것이 바람직할 것으로 사료된다. 무엇보다도 분쟁에 휘말린 기업 등 당사자의 입장에서는 "기술 분야에 대한 정확한 사실판단" 및 이에 근거한 "적절한 소송 진행"이 절실히 요구되어 지고 있다고 하겠다.[282] 법률소비자는 두 가지가 대리인에 의하여 균형 있게 보장되기를 바라고 있는 것은 자명하다고 하겠다. 또한 이를 위해 누구를 대리인으로 선택할 것이냐 역시 다른 누구도 아닌 당사자가 결정할 문제인 것이다.

282) 이러한 점은 종래 특허심판이 특허심판소·항고심판소 체제로 운용될 당시 제기된 "헌법재판소 1995. 9. 28, 92헌가11, 93헌가8·9·10(병합) 특허법 제186조 제1항 등 위헌제청"에서 대한상공회의소측이 제기한 의견 즉, "특허법 제186조 제1항이 위헌이라고 선언하는 것은 법 이론적 측면에서는 수긍할 수 있는 긍정적인 면이 있으나, 특허사건의 사실판단을 기술을 모르는 일반 법률가 출신의 법관에게 맡긴다면 적정한 판단을 기대하기 어렵고…"에서 유추해 볼 수 있다.

Ⅱ. 변리사 시험제도

1. 논의 배경

변리사 시험제도를 검토하기에 앞서 주요 국가들의 변호사 선발제도를 살펴보고자 한다. 변호사 선발제도는 각국의 역사·사회구조에 따라 다양한 형태이나, 크게 보면 '선발 후 양성제도'와 '양성 후 선발제도'로 구분된다.

<표-> 주요국의 변호사 선발제도

국가	단계		응시자격	응시제한
한국	사법시험 (로스쿨 도입 추진 중)		자격제한 없음 2006년부터는 법학학점 35학점 이수자	없음
일본	종래	사법시험 1차	자격제한 없음	없음
		사법시험 2차	1차 합격자 또는 교양학점 32학점 취득자	
	2006 년부터	법과대학원 입학	학부 4년 졸업자	5년간 3회
		예비시험	자격제한 없음	
		신 사법시험	예비시험 합격자 또는 법과대학원 졸업자	
미국	로스쿨 입학(LSAT)		학부 4년 졸업자	2년간 3회
	변호사시험		로스쿨 졸업자	주별로 2~5회
독일	국가시험		법과대학 4년(8학기) 이수자	2회
프랑스	변호사연수원 입소시험		법학석사	3회
	국립사법관학교 입학시험		제1시험: 학부 4년 졸업하고 법학석사학위를 취득한 27세 이하의 자 제2시험: 4년 이상 경력의 공무원, 공기업 직원, 공공병원 근무자 등으로서 46세 5월 이하의 자 제3시험: 국회 및 지방의회 의원, 법관 아닌 상사재판관이나 노동재판관, 8년 이상 경력자로서 40세 이하의 자	
영국	Barrister과정 (Inns of Court 입회)		대학 법학사(3년) 취득자 또는 공통자격시험(CPE) 합격자	1회
	Solicitor과정 (Solicitor협회 입회)		대학 법학사(3년) 취득자, 공통자격시험(CPE) 합격자 또는 변호사사무실 사무직원으로서 변호사사무직원협회(ILEX) 시험 합격자	

향후 법률시장이 개방되는 경우 위와 같은 선발과정을 거친 각국의 법률전문가들이 국내에 유입될 것이다.[283] 아울러 우리나라에서 추진 중인 법학전문대학원(일종의 로스쿨) 제도에 관련하여서도 변리사의 국제 경쟁력 확보, 변호사와의 직역 문제의 해결, 그리고 소송대리권의 범위와 관련한 변리사 선발 및 양성제도에 대하여 심층적인 검토가 요청된다고 할 것이다.

2. 우리나라의 변리사 시험제도

1) 응시자격 및 결격사유

현행 변리사법에 의하면 변리사 시험에 응시할 수 있는 자격에 특별한 제한을 두고 있지 않고 있다.[284] 응시자격 변천의 연혁을 살펴보면 다음과 같다.[285]

<표-> 우리나라 변리사시험 응시자격의 변천

근거규정	응시자격
1962. 3. 22 각령 제556호	제6조 다음 각호의 1에 해당하는 자는 시험에 응시할 수 있다. 1. 교육법에 정한 대학에서 제3학년의 과정을 수료한 자 2. 특허국에 재직한 3급 이상 공무원으로서 1년 이상 심사 및 심판사무에 종사한 자 3. 특허국에 재직한 4급 이하 공무원으로서 3년 이상 심사 및 심판사무에 종사한 자 (*당시 4급=현재 7급)
1973. 11. 26 대통령령 제6939호	제6조 다음 각호의 1에 해당하는 자는 시험에 응시할 수 있다. 1. 교육법에 정한 대학에서 제3학년의 과정을 수료한 자 2. 3급 이상의 일반직공무원으로 특허국에서 계속하여 1년 이상 근무한 자 3. 4급 이하의 일반직공무원으로 특허국에서 계속하여 3년 이상 근무한 자
1980. 12. 24 대통령령 제10113호	응시자격 규정의 삭제 (대한민국 국민으로서 만20세 이상이면 누구나 응시가능)
1999. 6. 8 대통령령 제16381호	국적요건 삭제(외국인도 응시가능)

2) 시험일정 및 시험방식

283) 일본의 사법제도 개혁에 관하여 보다 자세한 것은, 사법제도개혁추진위원회, 일본의 법과대학원 운영실태 등 사법제도 개혁에 대한 출장보고, 2005. 5 참조. 미국의 법률가 양성에 관하여 보다 자세한 것은, 사법제도개혁추진위원회, 미국 로스쿨 실무교육 실태 파악을 위한 출장결과 보고, 2005. 11 참조.

284) 다만, 변리사법 제4조에서 정하고 있는 결격사유 가운데 하나라도 해당하는 자는 변리사가 되지 못한다.

285) 정영환·배상철, 변리사제도 개선방안연구, 한국발명진흥회 지식재산권연구센터, 2001. 3, 117면.

(1) 현행 제1차 시험

매년 3월 첫째 주 일요일로 시험 시기를 정례화 하여 수험생의 편의를 도모하였으며, 시험방식은 객관식 선택형이고 시험과목은 다음과 같다.

<표-> 현행 변리사 1차 시험

구분	시간
오전	산업재산권법 (10:00 - 11:00)
	휴식시간 (11:00 - 11:30)
	민법개론 (11:30 - 12:40)
오후	자연과학개론 (14:00 - 15:00)

한편, 기존의 1차 영어시험은 다음과 같이 민간영어능력검정시험으로 대체하여 Pass / Non-Pass의 방식을 취하고 있으며, 지적재산권 제도 및 변리사 업무가 국제화되고 있는 추세를 반영하기 위해 기준 점수를 상향 조정할 예정이다.

<표-> 변리사 1차 민간영어능력검정시험

시험 종류	현행		2008년 이후	
토플(TOEFL)	PBT 530점 이상	CBT 197점 이상	PBT 560점 이상	CBT 220점 이상
토익(TOEIC)	700점 이상		775점 이상	
텝스(TEPS)	625점 이상		700점 이상	
지텔프(G-TELP)	Level 2의 65점 이상		Level 2의 77점 이상	
플렉스(FLEX)	625점 이상		700점 이상	

(2) 현행 제2차 시험

2차 시험의 응시자격과 관련하여서는 제1차 시험 합격자와 면제자에 한해 2차 시험에 응시할 수 있다.[286] 변리사 2차 시험의 시행 시기는 1차 시험과 마찬가지로 정례화해 매년 8월 둘째 주 수요일·목요일 이틀간에 걸쳐 치른다. 시험과목은 다음과 같고, 각 과목당 120분이 주어져 주관식 논술형으로 치른다.

286) 즉, 당해연도 1차 합격자가 2차 시험에 응시할 수 있음은 물론 전년도 제1차 시험 합격자로써 응시원서 접수기간 내에 그 뜻을 기재한 응시원서를 제출한 자 그리고 특허청 경력자로서 7급 이상 10년 경력자는 제1차 시험이 면제되며, 5급 이상 5년 경력자는 제1차 시험과 제2차 시험의 일부가 면제되며, 이 경우 경력증명서로 그 사실을 확인한다.

<표-> 현행 변리사 2차 시험

수요일	오전	특허법
	오후	상표법
목요일	오전	민사소송법
	오후	선택과목[287]

3) 시험 합격기준

제1차 시험의 합격기준을 살펴보면 각 과목 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상을 득점한 자 중에서 고득점 순으로, 최소합격인원을 공고한 수의 일정 배수 범위 내에서 합격자를 결정한다.[288] 그리고 제2차 시험 합격기준은 절대평가제(각 과목 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상 득점)로 하되, 최소합격인원을 공고한 경우에는 그 범위 내에서 60점 미만자도 합격 처리하고, 다만 제2차 시험 점수에 있어 동점자가 발생하여 공고된 최소합격인원을 초과하는 경우에는 동점자 모두를 합격자로 처리한다.

3. 주요국의 변리사 시험제도

먼저 미국의 변리사 시험제도에 대하여 살펴보기로 한다.[289]

1) 미국의 Patent Agent 시험

(1) 응시자격

□ Category A(공학 분야 학위자)

□ Category B(공학 분야 일정학점 취득자)

---

287) 의장법(조약 포함)·행정법·저작권법·경제원론·산업디자인·기계공작법·기계설계·열역학·제련공학·금속재료·광물처리공학·선박설계·유기화학·무기공업화학·화학반응공학·재배학원론·전기자기학·회로이론·반도체공학·제어공학·통신이론·데이터구조론·고체물리학·발효공학·분자생물학·약제학·약품제조화학·섬유재료학·방적공학·건축구조학·콘크리트 및 철근콘크리트공학 중 1과목

288) 2005년 통상 5배수, 2006년 4배수 예정, 2007년 3배수로 예정하고 있음.

289) 특허청 변리사제도 연구회 자료실(http://www.kipo.go.kr/wiz/user/pattorney/), "외국의 법조인 양성 및 변리사제도"자료에서 인용.

▢ Category C(실무경력 + 공학기초시험) : A, B에 해당하지 않는 과학, 공학 분야 실무경력자 중 공학기초시험 합격 후 응시자격을 부여한다.

※ 외국인은 원칙상 응시가 불가하나, 미국거주 영주권자나 미국 내 취업 가능한 VISA 소지자(시험응시확인서를 이민국으로부터 받은 자)는 응시가 가능하다.

(2) 시험의 종류 및 방법

<표-> 미국의 Patent Agent 시험과목 및 방법

구 분	방 법	시 험 과 목	비 고
SECTION 1	○ 오전 3시간 실시 ○ 다지선다형 50문항	○ 특허심사지침 -특허법령 및 절차 -출원서 및 청구범위 작성, 해석능력 ○ 윤리, 직업 규범	○ 70점 이상 득점하면 합격 ○ 통과된 section 다음 회에 면제 ○ 매년 2회 실시
SECTION 2	○ 오후 3시간 실시 ○ 다지선다형 50문항		

2) 일본의 변리사시험

(1) 응시자격

<표-> 일본의 변리사 자격요건

구 분	자 격 요 건	직 무 영 역
변리사	○ 변리사시험 합격자, 변호사 자격자, 특허청의 심사·심판관으로 7년 이상 근무자 ※ 2001년부터 응시자격에서 학력제한 철폐	○ 산업재산권 출원에서 등록까지의 모든 절차대리 ○ 산업재산권 분쟁사건대리

(2) 시험과목 및 시험방법

▢ 1차 시험과목

① 특허법·실용신안법

② 의장법

③ 상표법

④ 공업소유권에 관한 조약

⑤ 저작권법・부정경쟁방지법을 시험범위로 1과목

□ 2차 시험과목(논문식)

① 필수과목 : 특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법

② 선택과목(공통문제 외에 선택문제-복수문제 중 1문제 선택)

<표-> 일본 변리사시험 2차 선택과목 (법률계 과목, 1과목)

과목명	공통문제	선택문제
법률	민법개론 (총칙, 물권, 채권)	민사소송법, 저작권법, 지적재산관련 경쟁법, 국제사법, 행정법

<표-> 일본 변리사시험 2차 선택과목 (기술계 과목, 6과목)

과 목 명	공통문제	선택문제
지구공학	기초구조역학	건축구조, 토질공학, 환경공학
기계공학	기초재료역학	유체역학, 열역학
		제어공학
물리공학	물리학	계측공학, 광학, 전자디바이스공학, 전자기학, 회로이론, 에네르기공학
		통신공학
정보통신공학	정보이론	계산기공학, 정보공학
응용화학	화학	유기화학, 무기화학, 재료공학
		약학, 환경화학, 생물화학
바이오 테크놀러지	생물학	생명공학
		자원생물학

3) 영국의 Patent Agent 및 Trademark Agent 시험

(1) 응시자격

▢ 대학졸업자, 동등수준 이상 학력자 또는 자격증소지자

(2) 시험의 종류 및 방법

<표-> 영국의 PA 및 TA exam

구 분		시 험 과 목	비 고
P A, T A 공통 1차 시험		○기초상표법. 기초해외상표법 및 절차, 의장 및 저작권법, 기본영국법	○법학학위소지자, 변호사는 영국법 면제
P A exam	1차 시험	○기초특허법, 기초해외특허법 및 절차	○TA자격자 면제
	2차 시험	○특허실무, 특허명세서 작성 및 보정, 특허침해와 유효성	
T A exam	1차 시험	○기초상표실무	○ PA자격자 면제
	2차 시험	○고급상표법, 고급상표실무	

※ 변리사회가 변리사시험을 매년 시행

4) 프랑스의 Patent Attorney 및 Trademark Attorney 시험

(1) 응시자격

▢ 법대나 공대졸업자(PA) 또는 일반대학졸업자(TA)

▢ 스트라스부르대학의 산업재산권센타(CEIPI) 수료

▢ 3년간 변리사사무소나 기업체의 특허부서에 종사

※ 3가지 조건을 모두 충족해야 함

(2) 시험의 종류 및 방법

<표-> 프랑스의 PA 및 TA exam

구 분		시 험 과 목	비 고
P A exam	필기시험	○특허출원서 작성, 답변서작성, 침해에 대한 의견서 작성	○기계, 전자, 화학분야로 구분 시험실시 ○선발인원 제한 없음
	구두시험	○특허법일반, 외국특허법	
T A exam	필기시험	○상표 유효여부 및 이의신청서 작성, 상표법, 상표·의장 침해 의견서작성	
	구두시험	○상표·의장법 일반, 국제법, 부정경쟁방지법, 저작권법	

※ 외국인은 자격취득 및 변리업무 수행불가(EU회원국민은 응시가능)

※ 특허청에 등록된 PA, TA는 변리사회(CNCPI)에 의무가입

5) 독일의 변리사 시험

(1) 응시자격

▢ 이공대 또는 동등이상 학력소지자, 3년간 변리사수습 이수자

(2) 시험의 종류 및 방법

<표-> 독일의 변리사시험

구 분	시 험 과 목	시 험 면 제
필기 시험	○산업재산권법, 관련분야 법령 실무	○특허관련 분야 장기간 종사자
구두 시험	○사례에 대한 설명, 5명의 시험관 질문	

<표-> 독일의 변리사수습 방법 및 기간

구 분	주관기관	기 간	수습방법	수습면제
변리사사무소 수 습	변리사회	2년	○현장실습, 변리사회의 수련과정 이수	○특허청 또는 특허법원 10년 경력자
특허청 수습	특허청	4개월	○심사실무, 이론교육, 평가시험	
특허법원수습	특허법원	8개월	○재판실무, 산업재산권법 교육	

※ 변리사수습, 변리사시험 및 자격관리 : 변리사회에서 주관

※ 등록변리사는 변리사회에 강제가입

6) 종합 비교

<표-> 각국의 변리사 시험제도 비교

구 분	시 험 구 분	합 격 기 준	시 험 과 목
한 국	1차 : 다지선다형 2차 : 논술형	1차 : 상대평가제 2차 : 절대평가제 원칙 최소합격인원보장	이론위주
미 국	오전: 다지선다형(50항) 오후: 다지선다형(50항)	절대평가(70점)	실무위주
일 본	1차 : 다지선다형 2차 : 논문식 3차 : 구술시험	1차 : 상대평가 2차 : 절대평가 3차 : 절대평가	이론위주
영 국	공통1차 PA·TA구분 1차·2차	절대평가	실무위주
독 일	필기, 구두	절대평가	실무위주
프랑스	PA·TA구분, 필기, 구두	절대평가	실무위주

4. 변호사의 변리사 자동자격부여규정에 대하여

변리사법 제3조 제1항 제2호에서 “변호사법에 의하여 변호사의 자격을 가진 자로서 ‘변리사 등록’을 한 자는 변리사의 자격이 있다”고 규정하고 있다.[290] 다만, 다른 법무관련 직역 가운

290) 변호사법 제4조(변호사의 자격) 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 변호사의 자격이 있다.
1. 사법시험에 합격하여 사법연수원의 소정과정을 마친 자
2. 판사 또는 검사의 자격이 있는 자

데 변리사만이 '등록'을 하여야 자격이 부여된다는 점이 특히 다른 점이지만 한편으로는 그 등록이 매우 수월하여 기술 분야에 있어 전문성이 부족한 변호사라도 변리사등록을 통해 변리사로써의 모든 직무수행이 가능하다는 점에서 또 다른 문제제기가 되고 있다. 이와 관련하여 최근 변호사가 공인중개사 업무를 할 수 있는지를 다툰 판결이 나왔으며 판결이유에서 각 자격별 제도의 도입취지, 선발 및 양성제도 등의 차이에 주목하고 있어 이하에서 이를 소개한다.[291]

대법원 특별1부(주심 강신욱 대법관)는 L 변호사가 "부동산중개사무소 개설등록신청을 거부한 것은 부당하다"며 서울 서초구청장을 상대로 낸 거부처분취소소송 상고심(2003두14888)에서 L 변호사의 상고를 기각하고 원고패소 판결을 내린 원심을 확정했다. 재판부는 판결문에서 "변호사법 제3조와 제109조 1호 등 관련 규정에 의하면 변호사의 직무는 법률상 전문지식에 기해 제공되는 소송 및 행정처분의 청구에 관한 대리행위와 기타 법적 서비스를 처리하는 것이므로 거래당사자의 행위를 사실상 보조하는 업무를 수행하는데 그치는 구 부동산중개업법 제2조 1호 소정의 중개행위와는 구별되는 만큼 변호사법 제3조의 '일반 법률사무'에 중개행위가 당연히 포함되는 것이라고 해석할 수 없다"고 밝혔다.[292] 재판부는 또 "변호사에게 부동산중개업이 허용된다고 한다면 변호사 직무의 독립성을 해할 염려가 있을 뿐만 아니라 비밀유지의무, 이익충돌회피의무 등 변호사의 신분상·직무상 의무를 규정한 변호사법의 입법취지와 상충될 여지가 있는 점, 변호사와 공인중개사의 자격제도를 두게 된 취지, 각각의 자격요건, 시험방법 및 과목, 양성제도의 각 상이점 등을 종합하면 변호사의 직무와 부동산중개업이 합치되지도 않는다"고 덧붙였다. 재판부는 이어 "변호사의 직무에 부동산중개행위가 당연히 포함된다고 해석할 수도 없고, 변호사법에서 변호사의 직무가 구 부동산중개업법 시행령 제5조 단서 소정의 '다른 법률의 규정'에 해당한다고 명시한 바도 없으므로, 변호사는 구 부동산중개업법 제4조

---

291) L 변호사는 2002년 7월 서초구청에 부동산중개사무소 등록을 신청했다가 거부당하자 서울행정법원에 소송을 제기했으나 1·2심에서 모두 패소했었다.
한편 대한변협은 2001년 서울의 한 법무법인에서 근무하고 있는 H 변호사가 낸 질의에 대해 "변호사도 부동산중개 행위를 할 수 있다"고 답변하면서 논란이 시작됐다. 변협은 당시 "부동산중개업법 등을 종합하면 '알선'은 의뢰인의 부탁을 받아 중개대상물과 이에 관한 거래에 관한 '상의·물색·소개·조력·약정서 작성 등 일련의 행위를 포괄한 행위'를 뜻하는 것으로 해석된다"며 "따라서 그것은 변호사법 제3조가 변호사의 직무로 정한 '일반법률사무'에 속하는 법률사무 내지 이에 부수된 행위에 속하는 것이므로 변호사는 직무의 일환으로 당연히 부동산중개업이 규정한 중개행위를 할 수 있다"고 설명했었다.

292) 변호사법 제3조 (변호사의 업무) 변호사는 당사자 기타 관계인의 위임 또는 국가·지방자치단체 기타 공공기관(이하 "공공기관"이라 한다)의 위촉 등에 의하여 소송에 관한 행위 및 행정처분의 청구에 관한 대리행위와 일반 법률사무를 행함을 그 직무로 한다. 제109조 (벌칙) 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 7년 이하의 징역 또는 5천만 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있다. 1. 변호사가 아니면서 금품·향응 기타 이익을 받거나 받을 것을 약속하고 또는 제3자에게 이를 공여하게 하거나 공여하게 할 것을 약속하고 소송사건·비송사건·가사사건·가사조정 또는 심판사건·행정심판 또는 심사의 청구나 이의신청 기타 행정기관에 대한 불응신청사건, 수사기관에서 취급중인 수사사건 또는 법령에 의하여 설치된 조사기관에서 취급중인 조사사건 기타 일반의 법률사건에 관하여 감정·대리·중재·화해·청탁 법률상담 또는 법률관계 문서작성 기타 법률사무를 취급하거나 이러한 행위를 알선한 자 2호는 생략함.

1항과 4항, 같은 법 시행령 제5조에 규정된 중개사무소개설등록의 기준을 적용받지 않는다고 할 수는 없다"고 설명했다.[293] 결국 변리사법이나 세무사법과는 달리 부동산중개업법이 변호사의 자동자격부여에 관해 명시적으로 규정하지 않아 시작된 이번 법정싸움은 변호사가 부동산중개업을 하려면 공인중개사 자격증을 추가로 취득해야 한다고 결론지어 졌다.

5. 개선방안

우리나라 변리사 시험제도의 개선방안을 도출함에 있어 다음의 두 가지 측면을 고려하여야 할 것으로 판단된다.

첫째, 현재 추진 중인 법학전문대학원(일종의 로스쿨 제도)의 도입과 관련하여 변리사 선발 및 양성방향을 검토하여야 할 것이다. 대한변협은 현행 사법시험이 향후 법학전문대학원(로스쿨) 체제로 개편되는 경우 이공계 출신 변호사가 향후 많이 양성될 것이므로 변리사 제도(법무사, 세무사, 노무사, 관세사 등 포함)는 폐지되어야 한다는 의견을 사법제도개혁추진위원회에 제출한 바가 있고, 또한 특허침해소송에서 이공계 출신 변호사에 의해 특허침해소송대리가 이루어지게 될 것이므로 변리사의 대리권을 굳이 인정하지 않아도 된다는 견해도 제기한 바 있다.

일면 수긍할 수 있으나 생각건대, 지적재산권 분야가 전문화되고 분쟁이 복잡화되고 있는 추세에 있고 이런 경우 발생하게 되는 기업 등 법률소비자의 다양한 법률수요에도 불구하고 이러한 입장이 바람직한 것인지 의문이다. 또한 최근 대한변협 회장이 “전문 변호사는 변호사가 된 후에 전문화하는 것이지 학교(로스쿨)에서 만들어지는 것이 아니다”라고 주장한 바 있다.[294] 하지만 이는 결국 로스쿨을 통해 배출되는 이공계 출신 변호사가 바로 변리사의 전문성을 대체할 수는 없다는 의미로 해석된다. 더구나 로스쿨 정원을 1,200명 선으로 제한해야 한다는 등의 주장을 계속하는 한 선진국의 변호사 1인당 국민의 수(예를 들어 뉴질랜드는 인구가 402만 명에 불과한데 로스쿨을 통해 매년 1,000명의 신규 변호사를 배출하고 있고, 이 중 치열한 시장 경쟁을 통해 20% 가량이 경쟁력 있는 변호사로 살아남아 양질의 법률서비스를 제공하고 있음) 등을 살펴보면 설득력이 약하다.[295] 결국 실무경험과 기술 분야의 전문성 및 당사자의 선택권 존중의 측면에서 로스쿨 도입 이후에도 변리사 제도가 계속 유지·발전되

293) 법률신문, 대법원 “변호사는 공인중개사 자격증 없이 부동산중개업 못해”, 2006. 5. 15.

294) 법률신문, 로스쿨은 고비용·저효율 시스템, 2006. 6. 15.

295) 로스쿨 정원 제한의 또 다른 논거는 일부 국가를 제외하고는 없는 변리사, 법무사 등 법무관련 직역까지 합치면 적지 않는 수의 법무서비스 종사자가 있다는 것이다. 그러나 오직 변리사만이 지재권 분야에서 일부 소송대리를 하고 있다는 점에서 분쟁해결절차에서의 대리서비스는 변호사가 독점적인 지위를 유지하여 왔음을 부인할 수는 없을 것이고, 결국 분쟁해결절차에서 공급이 부족하여 왔으며 또한 수요자의 대리인 선택권이 제약되어 왔다고 볼 수 있는 것이다.

어야 하되, 법률소비자의 서비스의 입장에서 변호사와 변리사의 공동대리의 인정여부를 검토해야 할 것이다.

둘째, 법률시장 개방에 따른 경쟁력 강화 필요성 측면이다.

현재에도 변리사의 업무는 매우 국제화되어 있으나 법률시장 개방 이후에는 외국의 관련 법조인과 더욱 경쟁하게 될 것이고 이러한 측면에서 우수한 인재를 변리사로 선발하고 양성하여 국제경쟁력을 갖추게 하는 것이 시급히 요청된다. 이에 다음과 같은 개선을 제안한다.

<표-> 변리사 선발·양성제도의 개선방안 및 기대효과

구분	개선방안	기대효과
PA 및 TA 구분	○ 현행 - 구분하고 있지 않음 ○ 개선안 - Patent Attorney와 Trademark Attorney를 구분하여 선발하는 것이 업무의 차별성, 변리사 업계의 수요(예를 들어 비율을 9 : 1로), 전문성 제고의 측면에서 검토해볼 여지가 있다고 봄	분야별 전문성 확보 및 수험준비 합리화
응시자격	○ 현행 : 제한 없음 ○ 개선안 : 원칙적으로 제한을 두지 않되, PA의 경우 이공계 학사학위 이상자 그리고 TA의 경우 인문계 학사학위 이상자의 경우 일정한 Merit(ex: 자연과학개론 면제) 부여 ※ 다만, 규제 완화의 측면에서 문제가 될 수 있으나 현재에도 합격자의 거의 대부분이 학사학위 이상자라는 점에서는 실질적으로 문제가 되지 않을 것으로 봄	응시자격 요건의 강화로 우수한 인적자원 확보 및 기술 분야 전문성이 담보
시험과목	○ 현행 : (1차) 산업재산권법, 민법개론, 자연과학개론, 민간영어시험 (2차) 특허법, 상표법, 민사소송법, 선택과목 ○ 개선안 : PA 와 TA로 구분하여 과목 재구성하되 실무적인 사항의 평가를 강화	이론 위주의 시험을 지양하여 실무 위주의 수험준비로 실무적응력 제고
시험방식	○ 현행 : 1차(객관식)·2차(논술식) 구분하여 1차 합격자 및 면제자에 한해 2차 응시가능, 1년에 각1회 실시 ○ 개선안 : 과목별로 다음 회차에서 면제 가능하도록 하되, 응시횟수 제한을 둠	불필요한 장기의 수험기간 소요를 지양
보수교육	○ 현행 : 일회성 교육이 대부분이며, 강제성 없음 ○ 개선안 : 특히 민사소송 등 소송과 관련된 실무교육에 대한 강제성 요망	소송수행능력 강화

제 5 장

결 론(법률시장개방에 따른 지재권 분야의 대응책)

참고문헌

김정자, 우리나라 특허심판제도의 발전방안에 관한 연구, 한남대학교행정대학원석사학위논문(2004).
전문성, 특허심판구조의 제도적 개선방안에 대한 연구 -비교법적 고찰을 통하여-, 충남대학교특허협동과정(2001).
권혁중, 현행특허쟁송제도의 과제와 발전방안에 관한 연구, 한양대학교대학원석사학위논문(1999).
전경애, 특허쟁송제도의 연구 -심결취소소송의 심리범위를 중심으로-, 한남대학교행정정책대학원(2004).
김대웅, 특허소송의 당사자적격과 심리범위에 관한 연구, 연세대학교법무대학원(2005).
신왕철, 법률시장개방에 관한 연구, 부산외국어대학교대학원석사학위논문(200).
한정환, 특허심결취소소송의 심리범위에 관한 연구, 충남대학교대학원석사학위논문(2001).
성낙인·이상정·하홍준, 특허심판원의 운영방식에 관한 연구, 한국발명진흥회(지적재산권센터, 1997).
안대진, 특허심결취소소송의 심리범위에 관한 고찰,
일본의 지적재산권 소송제도 개혁동향
김순석, 법무서비스 시장개방의 주요 쟁점, 법조 (2004. 12).
박성득, 법원조직법중개정법률안, 법제사법위원회 (2004. 12).
김형준, 법률시장 개방협상 현황과 과제, 인권과 정의 (2005. 2).
일본특허청 심사관해외훈련 결과보고 (2002. 11).
특허침해소송 공동대리 설명자료, 특허청(2005. 7).
유럽특허청 세미나 참석결과 보고 -유럽특허청의 심판절차-, 특허심판원 심판 13부.
최재천, 대형화·전문화 이상의 노력이 필요하다, Jurist (2003. 4).
이승우, 특허침해소송에 있어서 변리사의 소송대리권 불인정의 부당성, 법학논총 제6집.
이용우, 지적재산권의 중요성에 비추어 본 지적재산권소송제도의 문제점 -관할 및 소송대리권 확대의 문제를 중심으로-, 법조 (2004. 1).
백태승, 지적재산라운드 대응방안, 21C 지식국가 발전을 위한 지적재산라운드 대응방안에 관한 토론회 (1999. 3. 31, 국회가상정보가치회·국회정보통신포럼 정책토론회) 토론자료.

단행본

김철용, 행정법, 박영사 (2005)
이한상·김학준, 지적재산권법, 제일법규(2000)
송영식·이상정·황종환, 지적소유권법 (상), (하), 육법사(2005).
이상경, 지적재산권소송법, 육법사(1998).
하홍준, 심결취소소송 관련 특허심판원과 특허법원간의 업무협력방안 연구 -심리범위를 중심으로-, 한국발명진흥회(지식재산권연구센타 2001).
특허심판원, 특허심판원 개원 5주년 기념 세미나 자료집, .